Aiken Renkel Afonso

Apontamentos de Direito penal

Questões fundamentais
Doutrina geral do crime

3.º edição

Lubango
2021/2022

Aiken Renkel Afonso

Apontamentos de
Direito penal
Questões fundamentais
Doutrina Geral do Crime

3ª Edição

2021/2022

Lubango, 05 de Agosto de 2021

AIKEN RENKEL AFONSO, licenciado em Direito, pela Universidade Mandume Ya Ndemufayo, Huíla - Lubango

Especialidade: Jurídico-Civis.

Jurisconsulto e pesquisador em Direito Penal, desde 2018.

Lubango, 05 de Agosto de 2021

Ficha Técnica

FD/UMN

Universidade Mandume Ya Ndemufayo

Unidade Curricular de Direito Penal I - UMN

Autor:

AIKEN RENKEL AFONSO

Prefácio:

DR. CELESTINO BANGULA QUEMBA

Título:

Apontamentos de Direito Penal Questões Fundamentais

Doutrina Geral do Crime

3.º Edição – Agosto, Lubango 2021

Contactos:

Correio electrónico*:* aikenrenkel6@gmail.com

Tel. +244 924 668 419

***Facebook*: Aiken Renkel Luvualu Júnior**

Índice

Prefácio.....19

GUIÃO NORMATIVO

CÓDIGO PENAL ANGOLANO

Lei n.º 38/20 de 11 de Novembro

PARTE I

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

DIREITO PENAL NO SISTEMA JURÍDICO ANGOLANO

TÍTULO

INTRODUÇÃO

CAPÍTULO I

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

I. Conceitos basilares em direito penal.....45

1. Noção de direito penal e de crime.....45

1.1. Crime (sentidos em pode ser definido a palavra crime).....46

2. Designação de direito penal.....47

3. Objecto de estudo do direito penal.....48

4. Natureza jurídica do direito penal.....48

5. Parte geral e parte especial do direito penal e suas componentes.....49

6. Expressões recorrentes em direito penal.....50

6.1. Direito penal objectivo ou *ius poenale*.....50

6.2. Direito penal subjectivo ou *ius puniendi*.....50

6.3. Natureza jurídica do ius *puniendi*.....50

6.4. Direito penal formal ou adjectivo.....50

6.5. Direito penal material ou substantivo.....51

6.6. Direito penal comum e direito penal especial ou particular.....51

6.7. Direito penal especial, complementar e particular.....51

6.8. Direito penal de justiça e direito penal secundário.....51

6.9. Direito penal angolano e direito penal estrangeiro.....52

6.10. Direito penal internacional.....52

6.11. Direito internacional penal.....52

6.12. Direito Penal do Inimigo e direito penal do cidadão.....53

6.13. Direito penal do facto.....53

7. **Âmbito ou extensão do direito penal**.....54

7.1. Direito penal substantivo.....54

7.2. Direito penal adjectivo ou direito processual penal.....54

7.3. Direito penal executivo.....54

CAPÍTULO III

CIÊNCIA CONJUNTA DO DIREITO PENAL (ENCICLOPÉDICA DO DIREITO PENAL)

I. Evolução histórica do direito penal.....60

1. Vingança Privada.....61

2. Vingança Divina.....62

3. Vingança Pública.....63

4. Período Humanitário.....64

5. Período Criminológico ou Científico.....65

6. Direito Penal Romano, Canónico e Germânico.....67

II. CIÊNCIAS PENAIS. DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL

1. A política criminal.....69

2. Criminologia.....70

III. OUTRAS CIÊNCIAS DO DIREITO PENAL

1. **Vitimológia**.....71

2. **Penologia**.....71

3. **Sociologia criminal**.....72

4. **Antropologia criminal**.....72

IV. CIÊNCIAS AUXILIARES DO DIREITO PENAL

1. Medicina Legal.....72

2. Psicologia Judiciária.....72

3. Criminalística.....72

4. Ciência Penitenciária.....73

CAPÍTULO IV

FONTE DE DIREITO PENAL

I. Algumas reflexões introdutórias.....73

1. Fontes substanciais ou materiais.....73

2. Fontes Formais.....73

1.1. Fonte formal imediata ou directa.....73

1.1.1. A lei (lei do Estado é a única fonte do direito penal).....73

1.2. Fonte formal indirecta ou mediata.....74

1.2.1. Costume.....74

1.2.2. Doutrina.....75

1.2.3. **Jurisprudência**.....76

1.2.4. Usos.....76

3.3.5**. Princípios gerais do direito**.....76

CAPÍTULO V

INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICO-PENAIS

I. Interpretação em direito penal.....77

1. Noção.....77

3. Relevância da interpretação em matéria jurídico-penal.....78

II. Analogia.....78

1. Noção.....78

3. Pressupostos.....79

4. Relevância da analogia em matéria jurídico-penal.....79

CAPÍTULO VI

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO PENAL

1. Noção.....80

2. Classificação.....80

2.1. Princípio legalidade.....80

2.2. Princípio proporcionalidade.....81

2.4. Princípio da insignificância e bem de valor diminuto.....82

2.5. Princípio da fragmentariedade.....83

2.6. Princípio culpabilidade.....83

2.7. Princípio humanidade.....84

2.8. Princípio da representação ou da bandeira.....84

CAPÍTULO VII

FUNÇÃO DO DIREITO PENAL

SECÇÃO I

FINS DO DIREITO PENAL E DAS SANÇÕES PENAIS

SECÇÃO II

FINS DO DIREITO PENAL

I. Algumas reflexões introdutórias.....85

1. Fins do direito penal.....86

2. Distinção entre fins do direito penal e fins das penas.....86

3. Diversidade de fins do direito penal.....87

II. TEORIA DO BEM JURÍDICO-PENAL

1. Algumas reflexões introdutórias.....89

2. **Concepções de bem jurídico-penal**.....89

2.1. Concepção positivistas-legalista.....89

2.2. Concepção jusnaturalista.....89

2.3. Concepção moralista.....90

2.4. Concepção sistémico funcional.....90

2.5. Concepções ético-social.....91

2.6. Concepção jurídico-constitucional.....91

2.7. Noção de bem jurídico-penal.....92

SECÇÃO III

FINS DAS PENAS

1. Noção de pena.....93

2. O problema dos fins das penas.....94

2.1. Teorias absolutas: pena como instrumento de retribuição.....94

2.2. Teorias relativas: pena como instrumentos de prevenção.....94

2.3. Teorias mistas ou unificadoras.....97

SECÇÃO IV

FINS DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. Noção de medida de segurança.....100

2. O problema das medidas de segurança.....101

2.1. Finalidade primária: prevenção especial em função de um facto ilícito-típico.....101

2.2. Finalidade secundária: a prevenção geral.....101

3. Relacionamento da pena com medida de segurança.....101

4. Questão do dualismo ou monismo do sistema penal.....101

5. Medida de segurança vs pena.....102

CAPÍTULO VIII

OS LIMITES DO DIREITO PENAL

SECÇÃO I

DIREITO PENAL E OUTROS RAMOS DO DIREITO

I. Algumas reflexões introdutórias.....104

1. Direito penal e outros ramos do direito.....104

1.1. Direito penal e direito constitucional.....104

1.2. Direito penal e direito civil.....105

1.3. Direito penal e direito administrativo.....106

1.4. Direito penal e direito disciplinar.....107

1.5. Direito penal e direito penal internacional.....108

1.6. Direito penal e o direito internacional penal.....109

CAPÍTULO XIX

A LEI PENAL E A SUA APLICAÇÃO

SECÇÃO I

APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO

I. Algumas reflexões introdutórias.....111

1. Princípio geral da aplicação da lei penal no tempo.....111

1.1. O princípio da irretroactividade da lei penal.....111

2. Excepção do princípio da irretroactividade da lei pena no tempo.....112

2.1. Princípio da aplicação da lei mais favorável.....112

3. O *tempus delicti*: Momento da prática do facto.....114

4. Instituto da prescrição.....115

SECÇÃO II

APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO ESPAÇO

I. Algumas reflexões introdutórias.....116

1. Princípio geral da aplicação da lei no espaço.....116

1.1. Princípio da territorialidade.....116
2. Excepções ou desvios do princípio da territorialidade.....118
2.1. Princípio da nacionalidade.....118
2.1.1. Princípio da protecção dos interesses nacionais.....118
2.1.2. Princípio da universalidade.....119
3. *lucus delicti:* Lugar da prática do facto.....119
4. A extradição.....120

SECÇÃO III
APLICAÇÃO DA LEI PENAL QUANTO AS PESSOAS

I. O princípio da igualdade dos cidadãos.....122
1. Casos de excepção do princípio da igualdade.....123
1.1. Imunidades.....123
1.2. Imunidades diplomáticas.....123
1.3. Titulares de órgãos públicos.....124
1.4. Instituição essencial à administração da justiça.....125

PARTE II
DOUTRINA GERAL DO CRIME
TÍPÍTULO I
CONSTRUÇÃO DA DOUTRINA GERAL DO CRIME: TEORIA DA INFRACÇÃO
CAPÍTULO I
DO FACTO PUNIVEL

I. Algumas reflexões introdutórias.....127
1. Classificação tripartida do facto punível (infracções).....127

SECÇÃO I
CONTRAVENÇÃO

I. Reflexões introdutórias.....128
1. Figuras afins.....129
2. Distinção entre coima e multa.....132
3. Distinção entre contravenção e Crime.....132

SECÇÃO II
CRIME

I. Evolução histórica da teoria do crime.....133

1. A concepção "clássica" (positivista-naturalista) ou simplesmente escola clássica de Lizst e Biling.....134

2. A concepção neoclássica (normativista) ou simplesmente escola neoclássica de Mezger, Eduardo Correia e Cavaleiro Ferreira.....135

3. A concepção finalista (ontico-fenomenologica) ou Escola finalista de Welzel.....136

4. Concepção pós-finalistas de Roxin, Jakobs.....137

CAPÍTULO II

OS FACTOS PUNÍVEIS DOLOSOS DE ACÇÃO

I. Conceito do facto punível (infracção penal).....138

1. Noção formal de crime.....138

2. Noção material de crime.....138

3. Noção analítica de crime.....138

4. Pressupostos do facto punível penal.....138

5. Elementos do facto punível (infracção penal ou crime).....140

SECÇÃO I

ACÇÃO

I. Algumas reflexões introdutórias.....140

1. Funções do conceito de acção.....141

2. Diferentes concepções de acção.....142

2.1. Conceito final de acção.....142

2.2. Conceito social de acção.....143

2.3. Conceito "negativo" de acção.....143

2.4. Conceito pessoal de acção.....143

2.5. Conceito causal da acção.....143

2.6. Acção relevante para o direito penal.....143

SECÇÃO II

TIPICIDADE

I. Algumas reflexões introdutórias.....145

1. Acção típica.....145

2. Sentido e conteúdo do tipo.....145

3. Elementos do tipo.....146

3.1. Elementos objectivos.....146

3.1.1. Elementos descritivos.....146
3.1.2. Elementos normativos.....146
3.2. Elementos subjectivos ou tipo subjectivo de ilícito.....146
3.2.1. Dolo.....147
3.2.1.1. Noção.....147
3.2.1.2. Elementos do dolo.....147
3.2.1.2.1. Elemento intelectual ou cognitivo.....147
3.2.1.2.2. Requisitos.....148
II. OS ERROS EM DIREITO PENAL.....148
1. Classificação dos erros sobre os elementos do facto típico.....149
1.1. O erro sobre a factualidade típica.....149
1.2. O erro sobre o processo causal.....149
1.3. O chamado *dolus generalis*.....150
1.4. O *error in persona vel objecto*.....150
1.5. A *aberratio ictus vel impetus*.....151
1.6. O conhecimento da proibição legal.....152
3.2.1.2.2. **Elemento volitivo do dolo**.....153
3.2.1.3. Modalidades do dolo.....153
a) Dolo directo.....153
b) Dolo necessário.....153
c) Dolo eventual.....154
3.2.1.4. Dolo eventual vs Negligência consciente.....154
a) Teorias intelectualistas ou da probabilidade.....154
b) **Teorias da vontade ou da aceitação**.....154
c) Teoria da conformação.....155
d) Critério da Profª. FERNANDA PALMA.....155
3.2.2. Negligência.....157
3.2.2.1. Noção.....157
3.2.2.2. Modalidades ou forma da negligência.....157
a) Negligência consciente.....157
b) Negligência inconsciente.....157
c) Negligência grosseira.....157

III. CONSTRUÇÃO OU CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS INCRIMINADORES OU TIPO DE TIPICIDADE

1. Quanto ao autor.....158

2.1. A questão da responsabilidade penal dos entes colectivos.....158

1.2. Autor individual.....159

2. Quando a conduta.....160

3. Quanto ao bem jurídico......161

4. Quanto à natureza dos crimes militares.....163

IV. IMPUTABILIDADE

1. Noção e classificação.....165

1.2. Imputabilidade subjectiva.....165

1.2. Imputabilidade objectiva.....166

1.2.1. **Sentido do problema**.....166

1.2.1.1. **Primeiro degrau: a categoria da causalidade ou teoria da *conditio sine quo non***.....166

1.2.1.2. Segundo degrau: causalidade jurídica sob forma da teoria da adequação.....167

1.2.1.3. Terceiro degrau: a conexão do risco ou teoria do risco.....169

3. A questão da "causalidade virtual.....170

4. Casos de comportamento lícito alternativo.....170

SECÇÃO III

ILICITUDE

1. Noção de ilicitude.....172

1. Causas da exclusão da ilicitude.....172

1.1. Princípio geral das causas de justificação da ilicitude (princípio da unidade da ordem jurídica).....172

2. **Elementos da causa da exclusão da ilicitude**.....172

2.1. Legítima defesa.....173

2.2. Exercício de um direito ou direito de necessidade.....176

2.3. Cumprimento de um dever imposto por lei ou por ordem legítima de autoridade.....179

2.4. Consentimento do lesado.....179

SECÇÃO IV

CULPA

1. Noção.....182

2. Elementos da culpa.....182

2.1. Capacidade da culpa.....182

2.2. Consciência da ilicitude.....183

3. Causas de exclusão da culpa em sentido amplo.....183

4. Causas de exclusão da culpa em sentido estrito.....185

SECÇÃO V

PUNIBILIDADE

I. Algumas reflexões introdutórias.....187

1. Condições objectivas de punibilidade.....187

2. O Causas de isenção da pena.....187

CAPÍTULO III

A PREPARAÇÃO E A TENTATIVA

SECÇÃO I

OS ESTÁDIOS DE REALIZAÇÃO DO CRIME (*ITER CRIMINIS*)

I. Algumas reflexões introdutórias.....188

1. Noção.....188

2. **Fases da realização do crime (*iter criminis*)**.....188

2.1. A resolução criminosa.....188

2.2. Os actos predatórios.....189

2.3. Fase dos actos de execução (tentativa).....190

2.4. A consumação e a terminação (exaurimento).....190

SECÇÃO II

A TENTATIVA

I. Fundamento da punibilidade da tentativa.....191

1. As teorias objectivas.....191

2. As teorias subjectivas.....191

3. As teorias da impressão ou mista.....192

II. **Os elementos da tentativa**.....192

1. A decisão de cometer o facto.....192

2. Os actos de execução.....193

3. A não – consumação (do crime que o agente decidiu cometer).....193

III. Formas da tentativa

1. Tentativa, tentativa acabada e a frustração.....194
2. A chamada tentativa impossível.....194
2.1. Consequências.....194
2.1.1. A impunibilidade da tentativa dita irreal ou supersticiosa.....194
2.1.2. Ineptidão do meio empregado pelo agente.....194
2.1.3. A inexistência do objecto essencial à consumação do crime.....195
3. Tentativa impossível e crime putativo.....195

SECÇÃO III

A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA TENTATIVA

1. A desistência da tentativa inacabada: o abandono da prossecução do crime.....195
2. A desistência da tentativa acabada: o impedimento da consumação.....196
3. A "desistência" em caso de consumação.....196
4. A desistência em casos especiais.....196
5. A voluntariedade da desistência.....197

SECÇÃO IV

A COMPARTICIPAÇÃO NOS CRIMES DOLOSOS DE ACÇÃO

I. A delimitação entre autoria e participação.....198
1. Os modelos e as concepções básicas.....198
1.1. A teoria formal objectiva.....198
1.2. A teoria subjectiva.....198
1.3. A teoria do "domínio do facto.....199
2. As concretas formas da autoria.....199
2.1. A autoria imediata.....199
2.2. A autoria mediata.....199
2.3. Autoria paralela.....199
2.4. O instrumento (homem-da-frente) actua atipicamente "O aliciamento".....200
3. A co-autoria.....202
3.1. Conceito e âmbito da co-autoria.....202
3.1.1. A decisão conjunta.....202
3.1.2. A execução conjunta do facto.....203
3.2. **A punição da co-autoria**.....203

II. COMPARTICIPAÇÃO CRIMINOSA

1. Formas de comparticipação.....203

1.2. A instigação.....204

1.2. Cumplicidade.....205

I. ENCOBRIMENTO.....207

1. O encobrimento no novo código penal.....207

CATÍTULO III

CRIMES NEGLIGENTES DE ACÇÃO

I. Algumas reflexões introdutórias.....207

1. Noção.....208

I. Elementos do ilícito negligente.....208

1. **O tipo de ilícito negligente**.....209

2. O tipo de culpa negligente.....210

3. Os tipos justificadores.....212

4. Problema da negligência grosseira.....212

CATÍTULO IV

CRIMES DOLOSOS DE OMISSÃO

I. Algumas reflexões introdutórias.....213

1. Noção.....213

2. Diferença entre crimes comissivos e crimes omissivos.....214

3. Pressupostos.....214

4. Objecto dos crimes dolosos de omissão.....215

5. Fontes do dever de agir.....215

a) A lei.....215

b) Contrato.....215

c) Situação de ingerência.....216

6. Tipos de incriminadores de crime de omissão por comissão.....216

6.1. Noção.....216

6.2. Classificação dos crimes Comissivos.....216

CATÍTULO V

CRIMES AGRAVADOS PELO RESULTADO

1. Noção.....217

2. Características.....217

3. **Requisitos**.....217

Crimes agravados pelo resultado *vs.* Crimes preterintencionais.....218

CATÍTULO VI

CONCURSO DE CRIMES

Questões prévias.....219

1. Noção e o problema da unidade ou pluralidade jurídica.....219

2. Modalidades do curso de crimes.....220

2.1. O concurso de crimes efectivo, real ou ideal.....220

2.2. O concurso de crimes aparente ou ideal impuro ou impróprio.....221

3. Concurso de crimes e o crime continuado.....221

3.1. Elementos do crime continuado.....222

1. Realização plúrima do mesmo tipo de crime ou de vários tipos de crime.....222

2. Identidade do bem jurídico protegido.....223

3. Homogeneidade de execução.....223

4. **A existência de uma circunstância externa capaz de diminuir sensivelmente a culpa do agente** 223

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....225

Abreviaturas

al. – alíneas
art. - Artigo
artˢ. – Artigos
AN – Assembleia Nacional
CRA – Constituição da República de Angola
CP – Código Penal
CC. – Código Civil
EOA – Ordem dos Advogados de Angola
Exˢ – Exemplos
da República
UMN – Universidade Mandume Ya Ndemufayo
n.ˢ - Números
n.º - Números
Prof. - Professor
Prof.ª - Professora
RFA - República Federal da Alemanha
RDA - República Democrática Alemã
RGCO – Regime Geral das Contra-Ordenações
LTA – Lei das Transgressões Administrativas
Vide. - Ver

Prefácio

GUIÃO NORMATIVO

CÓDIGO PENAL ANGOLANO

Lei n.º 38/20 de 11 de Novembro

1. ESTRUTURA DO CÓDIGO

ARTIGOS: 473.º

TÍTULOS: 16

CAPÍTULOS: 50

SECÇÕES: 42

Estrutura do código	Parte Geral	Parte Especial
Artigos = 473.º	146.º	327.º
Títulos = 16	7	9
Capítulo = 50	17	33
Secções = 42	17	25

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTULO I

Lei Criminal

CAPÍTULO ÚNICO

Princípios Gerais

ARTIGO 1.º (Princípio da legalidade)

ARTIGO 2.º (Aplicação da lei no tempo)

ARTIGO 3.º (Momento da prática do facto)

ARTIGO 4.º (Aplicação da lei no espaço)

ARTIGO 5.º (Aplicação da Lei Penal Angolana a factos ocorridos fora do território nacional)

ARTIGO 6.º (Lugar da prática do facto)

ARTIGO 7.º (Aplicação subsidiária do Código Penal)

TÍTULO II

Facto Punível

CAPÍTULO I

Pressupostos da Punição

ARTIGO 8.º (Acção e omissão)

ARTIGO 9.º (Responsabilidade penal das pessoas colectivas)

ARTIGO 10.º (Actuação em nome de outrem)

ARTIGO 11.º (Imputação subjectiva)

ARTIGO 12.º (Dolo)

ARTIGO 13.º (Negligência)

ARTIGO 14.º (Erro sobre as circunstâncias do facto)

ARTIGO 15.º (Erro sobre a ilicitude)

ARTIGO 16.º (Agravação da pena pelo resultado)

ARTIGO 17.º (Imputabilidade em razão da idade)

ARTIGO 18.º (Inimputabilidade em razão de anomalia psíquica)

CAPÍTULO II

Formas Especiais do Facto Punível

ARTIGO 19.º (Actos preparatórios)

ARTIGO 20.º (Tentativa)

ARTIGO 21.º (Punibilidade da tentativa)

ARTIGO 22.º (Desistência)

ARTIGO 23.º (Desistência em caso de comparticipação)

ARTIGO 24.º (Autoria)

ARTIGO 25.º (Cumplicidade)

ARTIGO 26.º (Ilicitude na comparticipação)

ARTIGO 27.º (Culpa na comparticipação)

ARTIGO 28.º (Concurso de crimes)

ARTIGO 29.º (Crime continuado)

CAPÍTULO III

Causas que Excluem a Ilicitude

ARTIGO 30.º (Exclusão da ilicitude)

ARTIGO 31.º (Legítima defesa)

ARTIGO 32.º (Estado de necessidade)

ARTIGO 33.º (Conflito de deveres)

ARTIGO 34.º (Consentimento do ofendido)

ARTIGO 35.º (Consentimento presumido)

CAPÍTULO IV

Causas que Excluem a Culpa

ARTIGO 36.º (Excesso de legítima defesa desculpante)

ARTIGO 37.º (Estado de necessidade desculpante)

ARTIGO 38.º (Conflito de deveres desculpantes)

TÍTULO III

Consequências Jurídicas do Facto

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

ARTIGO 39.º (Sanções)

ARTIGO 40.º (Finalidades das penas e das medidas de segurança)

ARTIGO 41.º (Regras gerais)

ARTIGO 42.º (Pressupostos e limites das penas e das medidas de segurança)

ARTIGO 43.º (Penas aplicáveis às pessoas colectivas)

CAPÍTULO II

Penas Principais e de Substituição

SECÇÃO I

Penas de Prisão e de Multa

ARTIGO 44.º (Duração da pena de prisão)

ARTIGO 45.º (Substituição da prisão por multa)

ARTIGO 46.º (Prisão em fins-de-semana)

ARTIGO 47.º (Pena de multa)

ARTIGO 48.º (Substituição da multa por trabalho)

ARTIGO 49.º (Conversão da multa não paga em prisão subsidiária)

SECÇÃO II

Suspensão da Execução da Prisão

ARTIGO 50.º (Pressupostos e duração)

ARTIGO 51.º (Deveres)

ARTIGO 52.º (Regras de conduta)

ARTIGO 53.º (Falta de cumprimento das condições da suspensão)

ARTIGO 54.º (Revogação da suspensão)

ARTIGO 55.º (Extinção da pena)

SECÇÃO III

Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade e Admoestação

ARTIGO 56.º (Prestação de trabalho a favor da comunidade)

ARTIGO 57.º (Suspensão, revogação, extinção e substituição)
ARTIGO 58.º (Admoestação judicial)

SECÇÃO IV

Liberdade Condicional

ARTIGO 59.º (Pressupostos e duração)
ARTIGO 60.º (Liberdade condicional em caso de execução sucessiva de várias penas)
ARTIGO 61.º (Regime)
ARTIGO 62.º (Revogação e extinção da liberdade condicional)
ARTIGO 63.º (Inadmissibilidade de liberdade condicional)

CAPÍTULO III

Penas Acessórias

ARTIGO 64.º (Proibição do exercício de cargo ou função)
ARTIGO 65.º (Suspensão do exercício de função)
ARTIGO 66.º (Efeitos da proibição e da suspensão do exercício de função)
ARTIGO 67.º (Proibição de conduzir veículos motorizados)
ARTIGO 68.º (Expulsão do território nacional)

CAPÍTULO IV

Escolha e Medida da Pena

SECÇÃO I

Regras Gerais

ARTIGO 69.º (Critério de escolha da pena)
ARTIGO 70.º (Determinação da medida da pena)
ARTIGO 71.º (Circunstâncias relevantes para a determinação da medida da pena)
ARTIGO 72.º (Circunstâncias modificativas e concurso)
ARTIGO 73.º (Atenuação especial da pena)
ARTIGO 74.º (Termos da atenuação especial)
ARTIGO 75.º (Dispensa de pena)
ARTIGO 76.º (Pressupostos da reincidência)
ARTIGO 77.º (Efeitos da reincidência)

SECÇÃO III

Punição do Concurso de Crimes e do Crime Continuado

ARTIGO 78.º (Regras da punição do concurso)

ARTIGO 79.º (Conhecimento superveniente do concurso)

ARTIGO 80.º (Punição do crime continuado)

SECÇÃO IV

Desconto

ARTIGO 81.º (Medidas processuais)

ARTIGO 82.º (Pena anterior)

ARTIGO 83.º (Medida processual ou pena aplicada no estrangeiro)

CAPÍTULO V

Prorrogação da Pena

SECÇÃO I

Delinquentes por Tendência

ARTIGO 84.º (Prorrogação da pena)

ARTIGO 85.º (Outros casos de prorrogação da pena)

ARTIGO 86.º (Restrições)

SECÇÃO II

Alcoólicos e Equiparados

ARTIGO 87.º (Pressupostos e efeitos)

ARTIGO 88.º (Abuso de estupefacientes)

SECÇÃO III

Disposição Comum

RTIGO 89.º (Liberdade condicional)

CAPÍTULO VI

Penas Aplicáveis a Pessoas Colectivas

SECÇÃO I

Penas Principais

ARTIGO 90.º (Admoestação judicial)

ARTIGO 91.º (Pena de multa para as pessoas colectivas)

ARTIGO 92.º (Pena de dissolução)

SECÇÃO II

Penas Acessórias

ARTIGO 93.º (Publicidade da decisão condenatória)

ARTIGO 94.º (Caução de boa conduta)

ARTIGO 95.º (Injunção judicial)

ARTIGO 96.º (Proibição de celebrar contratos)

ARTIGO 97.º (Privação do direito a subsídios, subvenções ou incentivos)

ARTIGO 98.º (Perda dos bens e das vantagens do crime)

ARTIGO 99.º (Interdição do exercício de actividade)

ARTIGO 100.º (Encerramento de estabelecimento)

CAPÍTULO VII

Medidas de Segurança

SECÇÃO I

Internamento de Inimputáveis

ARTIGO 101.º (Pressupostos e duração mínima)

ARTIGO 102.º (Cessação e prorrogação do internamento)

ARTIGO 103.º (Revisão da situação do internado)

ARTIGO 104.º (Liberdade para prova)

ARTIGO 105.º (Revogação da liberdade para prova)

ARTIGO 106.º (Reexame da medida de internamento)

ARTIGO 107.º (Inimputáveis estrangeiros)

ARTIGO 108.º (Pressupostos e regime)

SECÇÃO III

Execução da Pena e da Medida de Segurança Privativa da Liberdade

ARTIGO 109.º (Regime)

SECÇÃO IV

Medidas de Segurança não Privativas da Liberdade

ARTIGO 110.º (Interdição de actividades)

ARTIGO 111.º (Cassação da licença de condução de veículo motorizado)

ARTIGO 112.º (Interdição de concessão de licença)

ARTIGO 113.º (Cassação de licença de uso e porte de arma de fogo e interdição de concessão)

ARTIGO 114.º (Extinção das medidas)

CAPÍTULO VIII

Internamento de Imputáveis Portadores de Anomalia Psíquica

ARTIGO 115.º (Anomalia psíquica anterior)

ARTIGO 116.º (Anomalia psíquica posterior)

ARTIGO 117.º (Anomalia psíquica posterior sem perigosidade)

ARTIGO 118.º (Revisão da situação)

ARTIGO 119.º (Simulação de anomalia psíquica)

CAPÍTULO IX

Perda de Instrumentos, Produtos e Vantagens

ARTIGO 120.º (Perda de instrumentos e produtos)

ARTIGO 121.º (Objectos pertencentes a terceiro)

ARTIGO 122.º (Perda de vantagens)

ARTIGO 123.º (Pagamento diferido ou a prestações e atenuação)

TÍTULO IV

Queixa e Acusação Particular

ARTIGO 124.º (Titulares do direito de queixa)

ARTIGO 125.º (Extensão dos efeitos da queixa)

ARTIGO 126.º (Extinção do direito de queixa)

ARTIGO 127.º (Renúncia e desistência da queixa)

ARTIGO 128.º (Acusação particular)

TÍTULO V

Extinção da Responsabilidade Criminal

CAPÍTULO I

Prescrição do Procedimento Criminal

ARTIGO 129.º (Prazos de prescrição)

ARTIGO 130.º (Início do prazo)

ARTIGO 131.º (Suspensão da prescrição)

ARTIGO 132.º (Interrupção da prescrição)

CAPÍTULO II

Prescrição das Penas e das Medidas de Segurança

ARTIGO 133.º (Prazos de prescrição das penas)

ARTIGO 134.º (Efeitos da prescrição da pena principal)

ARTIGO 135.º (Prazos de prescrição das medidas de segurança)

ARTIGO 136.º (Suspensão da prescrição)

ARTIGO 137.º (Interrupção da prescrição)

CAPÍTULO III

Outras Causas de Extinção

ARTIGO 138.º (Outras causas de extinção)

ARTIGO 139.º (Efeitos)

TÍTULO VI

Indemnização de Perdas e danos por Crime

ARTIGO 140.º (Responsabilidade civil emergente de crime)

ARTIGO 141.º (Indemnização do lesado)

TÍTULO VII

Contravenções

ARTIGO 142.º (Disposições gerais)

ARTIGO 143.º (Negligência nas contravenções)

ARTIGO 144.º (Convertibilidade da pena de multa)

ARTIGO 145.º (Concurso de infracções)

ARTIGO 146.º (Reincidência e prorrogação da pena)

LIVRO II

Parte Especial

TÍTULO I

Crimes Contra as Pessoas

CAPÍTULO I

Crimes Contra a Vida

SECÇÃO I

Homicídio

ARTIGO 147.º (Homicídio simples)

ARTIGO 148.º (Homicídio qualificado em razão dos meios)

ARTIGO 149.º (Homicídio qualificado em razão dos motivos)

ARTIGO 150.º (Homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima)

ARTIGO 151.º (Infanticídio)

ARTIGO 152.º (Homicídio negligente)

ARTIGO 153.º (Incitação ou auxílio ao suicídio)

SECÇÃO II

Crimes Contra a Vida Intra-Uterina

ARTIGO 154.º (Interrupção de gravidez)

ARTIGO 155.º (Interrupção de gravidez agravada)

ARTIGO 156.º (Extinção da responsabilidade e atenuação especial da pena)

ARTIGO 157.º (Propaganda favorável à interrupção de gravidez)

ARTIGO 158.º (Circulação de meios para interrupção de gravidez)

CAPÍTULO II

Crimes Contra a Integridade Física e Psíquica

ARTIGO 159.º (Ofensa simples à integridade física)

ARTIGO 160.º (Ofensa grave à integridade física)

ARTIGO 161.º (Agravação pelo resultado)

ARTIGO 162.º (Qualificação)

ARTIGO 163.º (Ofensa à integridade física privilegiada)

ARTIGO 164.º (Ofensa à integridade física por negligência)

ARTIGO 165.º (Consentimento)

ARTIGO 166.º (Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos)

ARTIGO 167.º (Representação de violência)

ARTIGO 168.º (Maus-tratos a menores, incapazes ou familiares)

ARTIGO 169.º (Participação em rixa)

CAPÍTULO III

Crimes Contra a Liberdade das Pessoas

ARTIGO 170.º (Ameaça)

ARTIGO 171.º (Coacção)

ARTIGO 172.º (Coacção grave)

ARTIGO 173.º (Perseguição)

ARTIGO 174.º (Sequestro)

ARTIGO 175.º (Rapto)

ARTIGO 176.º (Tomada de reféns)

ARTIGO 177.º (Escravidão)

ARTIGO 178.º (Tráfico de pessoas)

ARTIGO 179.º (Intervenção médico-cirúrgica sem consentimento)

ARTIGO 180.º (Atenuação especial da pena)

CAPÍTULO IV

Crimes Sexuais

SECÇÃO I

Definições

ARTIGO 181.º (Definições)

SECÇÃO II

Crimes Contra a Liberdade Sexual

ARTIGO 182.º (Agressão sexual)

ARTIGO 183.º (Agressão sexual com penetração)

ARTIGO 184.º (Abuso sexual de pessoa inconsciente ou incapaz de resistir)

ARTIGO 185.º (Abuso sexual de pessoa internada)

ARTIGO 186.º (Assédio sexual)

ARTIGO 187.º (Fraude sexual)

ARTIGO 188.º (Procriação artificial não consentida)

ARTIGO 189.º (Lenocínio)

ARTIGO 190.º (Tráfico sexual de pessoas)

ARTIGO 191.º (Importunação sexual)

SECÇÃO III

Crimes Contra a Autodeterminação Sexual

ARTIGO 192.º (Abuso sexual de menor de 14 anos)

ARTIGO 193.º (Abuso sexual de menor de 16 anos)

ARTIGO 194.º (Abuso sexual de menor dependente)

ARTIGO 195.º (Lenocínio de menores)

ARTIGO 196.º (Tráfico sexual de menores)

ARTIGO 197.º (Recurso a prostituição de menores)

ARTIGO 198.º (Pornografia infantil)

SECÇÃO IV

Disposições Comuns

ARTIGO 199.º (Agravação)
ARTIGO 200.º (Queixa)
ARTIGO 201.º (Pena acessória)

CAPÍTULO V
Colocação de Pessoas em Perigo
ARTIGO 202.º (Uso indevido de armas)
ARTIGO 203.º (Abandono de pessoa)
ARTIGO 204.º (Abandono de recém-nascido)
ARTIGO 205.º (Contágio de doença sexualmente transmissível)
ARTIGO 206.º (Contágio de doença grave)
ARTIGO 207.º (Impedimento a prestação de socorro)
ARTIGO 208.º (Omissão de auxílio)
ARTIGO 209.º (Recusa de assistência por profissional de saúde)
ARTIGO 210.º (Exercício ilegal de profissão)
ARTIGO 211.º (Atenuação especial ou dispensa de pena)

CAPÍTULO VI
Crimes Contra a Dignidade das Pessoas
SECÇÃO I
Discriminação
ARTIGO 212.º (Discriminação)

SECÇÃO II
Crimes Contra a Honra
ARTIGO 213.º (Injúria)
ARTIGO 214.º (Difamação)
ARTIGO 215.º (Calúnia)
ARTIGO 216.º (Publicidade)
ARTIGO 217.º (Ofensa a memória de pessoa falecida)
ARTIGO 218.º (Procedimento criminal)
ARTIGO 219.º (Dispensa da pena)
ARTIGO 220.º (Conhecimento público da sentença)

SECÇÃO III

Crimes Contra o Respeito Devido aos Mortos

ARTIGO 221.º (Atentado contra a integridade de restos mortais)

ARTIGO 222.º (Profanação de lugar fúnebre)

ARTIGO 223.º (Agravação)

CAPÍTULO VII

Crimes Cometidos Através da Imprensa e Crimes Contra a Liberdade de Imprensa

ARTIGO 224.º (Crime de abuso de liberdade de imprensa)

ARTIGO 225.º (Desobediência)

ARTIGO 226.º (Atentado à liberdade de imprensa)

ARTIGO 227.º (Autoria e comparticipação)

CAPÍTULO VIII

Crimes Contra a Reserva da Vida Privada

ARTIGO 228.º (Introdução em casa alheia)

ARTIGO 229.º (Introdução em lugar vedado ao público)

ARTIGO 230.º (Perturbação e devassa da vida privada)

ARTIGO 231.º (Violação de correspondência)

ARTIGO 232.º (Violação de segredo)

ARTIGO 233.º (Violação de sigilo profissional imposto por lei)

ARTIGO 234.º (Agravação)

ARTIGO 235.º (Procedimento criminal)

CAPÍTULO IX

Outros Crimes Contra Bens Jurídicos Pessoais

ARTIGO 236.º (Gravações, fotografias e filmes ilícitos)

ARTIGO 237.º (Subtracção às garantias do Estado Angolano)

TÍTULO II

Crimes Contra a Família

CAPÍTULO I

Crimes Contra o Casamento, o Estado Civil e a Filiação

ARTIGO 238.º (Casamento fraudulento)

ARTIGO 239.º (Indução em erro sobre impedimento)

ARTIGO 240.º (Conhecimento e ocultação de impedimento)

ARTIGO 241.º (Simulação de competência para celebrar casamento)
ARTIGO 242.º (Falsas declarações sobre o estado civil)
ARTIGO 243.º (Registo de nascimento inexistente)
ARTIGO 244.º (Parto suposto)
ARTIGO 245.º (Substituição ou subtracção de recém-nascido)
ARTIGO 246.º (Sonegação do estado da filiação)
CAPÍTULO II
Crimes Contra Outros Bens Jurídicos Familiares
ARTIGO 247.º (Abandono de assistência)
ARTIGO 248.º (Subtracção ou recusa de entrega de menor)
ARTIGO 249.º (Divulgação de falsa paternidade)

TÍTULO III
Crimes Contra a Fé Pública
CAPÍTULO I
Falsificação de Documentos e Registos Técnicos
ARTIGO 250.º (Definições)
ARTIGO 251.º (Falsificação de documento)
ARTIGO 252.º (Falsificação de registos e aparelhos técnicos)
ARTIGO 253.º (Destruição, inutilização ou subtracção de documento e registo técnico)
ARTIGO 254.º (Tentativa)

CAPÍTULO II
Crimes de Falsificação de Moeda, Valores Selados e Títulos de Crédito
SECÇÃO I
Falsificação de Moeda
ARTIGO 255.º (Definição de moeda)
ARTIGO 256.º (Contrafacção de moeda)
ARTIGO 257.º (Falsificação ou alteração da moeda com curso legal)
ARTIGO 258.º (Passagem e colocação em circulação de moeda falsa ou falsificada)

SECÇÃO II
Falsificação de Valores Selados
ARTIGO 259.º (Fabrico e falsificação ou alteração de valores selados)

ARTIGO 260.º (Utilização de valores selados falsos ou falsificados)

SECÇÃO III

Falsificação de Títulos de Crédito

ARTIGO 261.º (Fabrico e falsificação de títulos de crédito)

ARTIGO 262.º (Utilização de títulos de crédito falsos ou falsificados)

SECÇÃO IV

Disposições Comuns

ARTIGO 263.º (Actos preparatórios)

ARTIGO 264.º (Aquisição, detenção ou tráfico de moeda, valores selados e títulos de crédito falsos ou falsificados)

ARTIGO 265.º (Tentativa)

CAPÍTULO III

Falsificação de Selos, Cunhos, Marcas, Pesos e Medidas

ARTIGO 266.º (Falsificação de selos, cunhos e marcas)

ARTIGO 267.º (Utilização e posse de selos, cunhos e marcas falsos ou falsificados)

ARTIGO 268.º (Utilização abusiva de selos, cunhos, marcas ou chancelas)

ARTIGO 269.º (Falsificação de pesos e medidas)

ARTIGO 270.º (Utilização de pesos e medidas falsos ou falsificados)

ARTIGO 271.º (Tentativa)

CAPÍTULO IV

Outras Falsificações

ARTIGO 272.º (Atestado ou certificado falso)

ARTIGO 273.º (Uso de atestados ou certificados falsos)

ARTIGO 274.º (Assunção ou atribuição de falsa identidade)

ARTIGO 275.º (Uso de documento de identificação alheio)

ARTIGO 276.º (Uso ilegítimo de designação, sinal ou uniforme)

TÍTULO IV

Crimes Contra a Segurança Colectiva

CAPÍTULO I

Crimes de Perigo Comum

ARTIGO 277.º (Incêndio, inundações, explosão e outras condutas particularmente perigosas)

ARTIGO 278.º (Fabrico, aquisição ou posse de substâncias explosivas, tóxicas e asfixiantes)

ARTIGO 279.º (Fabrico, tráfico, detenção e alteração de armas e munições proibidas)

ARTIGO 280.º (Armas não proibidas, sujeitas a regulamentação)

ARTIGO 281.º (Tráfico ilícito de migrantes)

ARTIGO 282.º (Agressão ao ambiente)

ARTIGO 283.º (Poluição)

ARTIGO 284.º (Propagação de doença, praga, animal nocivo ou planta daninha)

ARTIGO 285.º (Adulteração de alimentos ou forragens para animais)

ARTIGO 286.º (Adulteração de substâncias alimentares ou medicinais)

ARTIGO 287.º (Propagação de doença contagiosa)

ARTIGO 288.º (Alteração de análise e inobservância de receituário)

ARTIGO 289.º (Violação de regras de construção e danos em aparelhos destinados a prevenir acidentes)

ARTIGO 290.º (Dano em instalações e perturbação em serviços)

ARTIGO 291.º (Agravação da pena pelo resultado)

ARTIGO 292.º (Dispensa de pena ou atenuação especial)

CAPÍTULO II

Crimes Contra a Ordem e a Tranquilidade Públicas

ARTIGO 293.º (Instigação pública ao crime)

ARTIGO 294.º (Apologia pública de crime)

ARTIGO 295.º (Impedimento ou perturbação de culto ou cerimónia fúnebre e ofensa por causa de crença ou função religiosa)

ARTIGO 296.º (Associação criminosa)

ARTIGO 297.º (Terrorismo)

ARTIGO 298.º (Participação em motim)

ARTIGO 299.º (Participação em motim armado)

ARTIGO 300.º (Desobediência à ordem de dispersão de ajuntamento)

ARTIGO 301.º (Alarme causado pela ameaça de prática de crime e abuso de sinal de alarme ou de pedido de auxílio)

CAPÍTULO III

Crimes Contra a Segurança dos Transportes

ARTIGO 302.º (Desvio ou captura de transporte)

ARTIGO 303.º (Atentado contra a segurança dos transportes)

ARTIGO 304.º (Condução sem habilitação legal)

ARTIGO 305.º (Condução perigosa de meio de transporte)

ARTIGO 306.º (Condução de veículo rodoviário em estado de embriaguez)

ARTIGO 307.º (Lançamento de projéctil contra veículo)

ARTIGO 308.º (Agravação especial)

ARTIGO 309.º (Dispensa de pena ou atenuante especial)

TÍTULO V

Crimes Contra o Estado

CAPÍTULO I

Crimes Contra a Segurança do Estado

SECÇÃO I

Crimes Contra a Independência e a Integridade Nacionais

ARTIGO 310.º (Alta traição)

ARTIGO 311.º (Falsificação constitutiva de traição)

ARTIGO 312.º (Preparação de alta traição)

ARTIGO 313.º (Entendimentos com o estrangeiro para provocar a guerra)

ARTIGO 314.º (Provocação à guerra ou a represálias)

ARTIGO 315.º (Colaboração com o estrangeiro para constranger o Estado)

ARTIGO 316.º (Violação de segredo de Estado)

ARTIGO 317.º (Espionagem)

ARTIGO 318.º (Inutilização de meios de prova)

ARTIGO 319.º (Infidelidade diplomática)

SECÇÃO II

Crimes Contra a Defesa Nacional e as Forças Armadas

ARTIGO 320.º (Inutilização de meios de defesa)

ARTIGO 321.º (Destruição ou inutilização de estruturas ou meios militares)

ARTIGO 322.º (Propaganda contra a defesa nacional e as forças armadas)

ARTIGO 323.º (Recolha de informações de natureza militar)

ARTIGO 324.º (Ilustrações de objectivo ou evento de natureza militar)

SECÇÃO III

Crimes Contra Autoridades, Representantes e Símbolos de Estados Estrangeiros ou de Organizações Internacionais

ARTIGO 325.º (Ataque contra autoridades ou representantes de Estados Estrangeiros ou de organizações internacionais)

ARTIGO 326.º (Ofensa à honra de autoridades ou representantes de Estados Estrangeiros ou de organizações internacionais)

ARTIGO 327.º (Ultraje a símbolos de Estados Estrangeiros ou de organizações internacionais)

ARTIGO 328.º (Procedimento criminal)

SECÇÃO IV

Crimes Contra a Realização do Estado

ARTIGO 329.º (Rebelião)

ARTIGO 330.º (Sabotagem)

ARTIGO 331.º (Atentado contra o Presidente da República e contra outras entidades do Estado)

ARTIGO 332.º (Coacção do Presidente da República e de outras entidades do Estado)

ARTIGO 333.º (Ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos)

ARTIGO 334.º (Perturbação do funcionamento de Órgão de Soberania)

ARTIGO 335.º (Violação de recintos)

SECÇÃO V

Disposições Comuns

ARTIGO 336.º (Actos preparatórios)

ARTIGO 337.º (Atenuação especial)

ARTIGO 338.º (Pena acessória)

CAPÍTULO II

Crimes Contra a Autoridade Pública

ARTIGO 339.º (Usurpação de funções)

ARTIGO 340.º (Desobediência)

ARTIGO 341.º (Violação de proibições ou interdições)

ARTIGO 342.º (Resistência contra funcionário)

ARTIGO 343.º (Descaminho de objectos submetidos ao domínio de autoridade pública)

ARTIGO 344.º (Quebra de selos ou marcas)

ARTIGO 345.º (Arrancamento, destruição ou alteração de editais)

ARTIGO 346.º (Libertação de reclusos)

ARTIGO 347.º (Amotinação de reclusos)

CAPÍTULO III

Crimes Contra a Realização da Justiça

ARTIGO 348.º (Denegação de justiça)

ARTIGO 349.º (Procedimento criminal)

SECÇÃO IV

Crimes Contra a Realização do Estado

ARTIGO 329.º (Rebelião)

ARTIGO 330.º (Sabotagem)

ARTIGO 331.º (Atentado contra o Presidente da República e contra outras entidades do Estado)

ARTIGO 332.º (Coacção do Presidente da República e de outras entidades do Estado)

ARTIGO 333.º (Ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos)

ARTIGO 334.º (Perturbação do funcionamento de Órgão de Soberania)

ARTIGO 335.º (Violação de recintos)

Disposições Comuns

ARTIGO 336.**º (**Actos preparatórios)

ARTIGO 337.º (Atenuação especial)

ARTIGO 338.º (Pena acessória)

CAPÍTULO II

Crimes Contra a Autoridade Pública

ARTIGO 339.º (Usurpação de funções)

ARTIGO 340.º (Desobediência)

ARTIGO 341.º (Violação de proibições ou interdições)

ARTIGO 342.º (Resistência contra funcionário)

ARTIGO 343.º (Descaminho de objectos submetidos ao domínio de autoridade pública)

ARTIGO 344.º (Quebra de selos ou marcas)

ARTIGO 345.º (Arrancamento, destruição ou alteração de editais)

ARTIGO 346.º (Libertação de reclusos)

ARTIGO 347.º (Amotinação de reclusos)

CAPÍTULO III

Crimes Contra a Realização da Justiça

ARTIGO 348.º (Denegação de justiça)

ARTIGO 349.º (Prevaricação)

ARTIGO 350.º (Falsidade de depoimento, declaração, perícia ou tradução)

ARTIGO 351.º (Favorecimento pessoal)

ARTIGO 352.º (Denúncia caluniosa)

ARTIGO 353.º (Subtracção ou desvio de processo ou de documentos probatórios)
ARTIGO 354.º (Obstrução à justiça)
ARTIGO 355.º (Deslealdade profissional de advogado)
ARTIGO 356.º (Violação de segredo de justiça)

CAPÍTULO IV
Crimes Cometidos no Exercício de Funções Públicas e em Prejuízo de Funções Públicas
ARTIGO 357.º (Recebimento indevido de vantagem)
ARTIGO 358.º (Corrupção activa de funcionário)
ARTIGO 359.º (Corrupção passiva de funcionário)
ARTIGO 360.º (Corrupção activa de magistrado ou árbitro)
ARTIGO 361.º (Corrupção passiva de magistrado ou árbitro)
ARTIGO 362.º (Peculato)
ARTIGO 363.º (Peculato de uso)
ARTIGO 364.º (Participação económica em negócio)
ARTIGO 365.º (Cobrança ilegal de contribuições)
ARTIGO 366.º (Tráfico de influência)
ARTIGO 367.º (Violação de domicílio por funcionário)
ARTIGO 368.º (Emprego da força pública contra a execução da lei ou ordem legítima)
ARTIGO 369.º (Falta de colaboração)
ARTIGO 370.º (Tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes)
ARTIGO 371.º (Agravação)
ARTIGO 372.º (Responsabilidade do superior hierárquico)
ARTIGO 373.º (Perseguição de inocentes)
ARTIGO 374.º (Abuso de poder)
ARTIGO 375.º (Violação de segredo por funcionário)

CAPÍTULO V
Disposição Geral
ARTIGO 376.º (Funcionário público)

TÍTULO VI
Crimes Contra a Paz e a Comunidade Internacional

ARTIGO 377.º (Incitamento ao ódio contra um povo e apologia da guerra)
ARTIGO 378.º (Recrutamento de membros das forças armadas)
ARTIGO 379.º (Recrutamento de mercenários)
ARTIGO 380.º (Incitamento à discriminação)
ARTIGO 381.º (Genocídio)
ARTIGO 382.º (Crimes de lesa humanidade)
ARTIGO 383.º (Definições)
ARTIGO 384.º (Outros crimes de lesa humanidade)
ARTIGO 385.º (Crimes de guerra contra civis)
ARTIGO 386.º (Crimes de guerra contra bens que não sejam objectivos militares)
ARTIGO 387.º (Crimes de guerra contra pessoal combatente)
ARTIGO 388.º (Outros crimes de guerra)
ARTIGO 389.º (Destruição de navios, aeronaves ou outros transportes civis)
ARTIGO 390.º (Penas acessórias)

TÍTULO VII
Crimes Contra o Património
CAPÍTULO I
Disposição Preliminar
ARTIGO 391.º (Definições)

CAPÍTULO II
Crimes Contra a Propriedade
SECÇÃO I
Crimes de Furto
ARTIGO 392.º (Furto)
ARTIGO 393.º (Furto qualificado)
ARTIGO 394.º (Furto de coisa comum)
ARTIGO 395.º (Furto de uso de veículos)
ARTIGO 396.º (Furto de coisa própria)
ARTIGO 397.º (Furto de energia, água e outros fluidos)
ARTIGO 398.º (Punição da tentativa)
ARTIGO 399.º (Restituição ou reparação)
ARTIGO 400.º (Procedimento criminal)

SECÇÃO II

Crimes de Roubo

ARTIGO 401.º (Roubo)

ARTIGO 402.º (Roubo qualificado)

ARTIGO 403.º (Violência posterior à subtracção)

SECÇÃO III

Crimes de Apropriação Indevida

ARTIGO 404.º (Abuso de confiança)

ARTIGO 405.º (Abuso de confiança qualificado)

ARTIGO 406.º (Apropriação ilegítima de bens de empresas do sector público)

ARTIGO 407.º (Apropriação ilegítima de coisa achada ou em caso de acessão)

ARTIGO 408.º (Restituição ou reparação)

ARTIGO 409.º (Procedimento criminal)

SECÇÃO IV

Crimes de Dano

ARTIGO 410.º (Dano)

ARTIGO 411.º (Dano de coisas com valor e interesse públicos)

ARTIGO 412.º (Dano com violência)

ARTIGO 413.º (Reparação)

ARTIGO 414.º (Procedimento criminal)

SECÇÃO V

Outros Crimes Contra a Propriedade

ARTIGO 415.º (Usurpação de imóvel e de herança indivisa)

ARTIGO 416.º (Arrancamento, destruição e alteração de marcos)

CAPÍTULO III

Crimes Contra o Património em Geral

SECÇÃO I

Crimes de Burla

ARTIGO 417.º (Burla)

ARTIGO 418.º (Burla qualificada)

ARTIGO 419.º (Burla para obtenção de alimentos, bebidas, combustíveis ou serviços)
ARTIGO 420.º (Burla relativa a trabalho, emprego ou estudo)
ARTIGO 421.º (Abuso de incapazes)
ARTIGO 422.º (Punição da tentativa)
ARTIGO 423.º (Restituição ou reparação)
ARTIGO 424.º (Procedimento criminal)

SECÇÃO II
Outros Crimes Contra o Património em Geral
ARTIGO 425.º (Extorsão)
ARTIGO 426.º (Infidelidade)
ARTIGO 427.º (Uso e abuso de cartão de crédito, débito ou garantia)
ARTIGO 428.º (Uso de cartão subtraído com violência)
ARTIGO 429.º (Usura)

CAPÍTULO IV
Crimes Contra Direitos Patrimoniais
ARTIGO 430.º (Frustração de créditos exequendos)
ARTIGO 431.º (Falência dolosa)
ARTIGO 432.º (Falência negligente)
ARTIGO 433.º (Favorecimento de credores)
ARTIGO 434.º (Perturbação de arrematação e adulteração de concurso público)
ARTIGO 435.º (Receptação)
ARTIGO 436.º (Auxilio material)

TÍTULO VIII
Crimes Informáticos
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
ARTIGO 437.º (Definições)
CAPÍTULO II
Crimes Contra os Dados Informáticos
ARTIGO 438.º (Acesso ilegítimo a sistema de informação e devassa através de sistema de informação)

ARTIGO 439.º (Intercepção ilegítima em sistema de informação)

ARTIGO 440.º (Dano em dados informáticos)

CAPÍTULO

Crimes Contra as Comunicações e Sistemas Informáticos

ARTIGO 441.º (Sabotagem informática)

ARTIGO 442.º (Falsidade informática)

ARTIGO 443.º (Burla informática e nas comunicações)

ARTIGO 444.º (Reprodução ilegítima de programa de computador, bases de dados e topografia de produtos semicondutores)

TÍTULO IX

Crimes Contra o Consumidor e o Mercado

CAPÍTULO I

Crimes Contra o Consumidor

ARTIGO 445.º (Abate clandestino de animais destinados à comercialização)

ARTIGO 446.º (Açambarcamento)

ARTIGO 447.º (Especulação)

ARTIGO 448.º (Fraude sobre mercadorias)

ARTIGO 449.º (Adulteração ou falsificação de substâncias alimentares)

ARTIGO 450.º (Destruição ou aplicação indevida de matérias-primas e bens)

ARTIGO 451.º (Falsa indicação de qualidade ou falsa designação)

ARTIGO 452.º (Publicidade enganosa)

CAPÍTULO II

Crimes Contra o Mercado e a Economia

ARTIGO 453.º (Recusa de prestar informações)

ARTIGO 454.º (Exportação ilícita de bens)

ARTIGO 455.º (Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção)

ARTIGO 456.º (Fraude na obtenção de crédito)

ARTIGO 457.º (Desvio de subsídio ou subvenção e de crédito)

ARTIGO 458.º (Atenuação especial da pena)

ARTIGO 459.º (Corrupção passiva)

ARTIGO 460.º (Corrupção activa)

ARTIGO 461.º (Corrupção no domínio do comércio internacional)

ARTIGO 462.º (Actividades económicas proibidas)

ARTIGO 463.º (Descaminho de mercadorias subvencionadas ou adquiridas com recursos do Estado)

ARTIGO 464.º (Fraude no transporte ou transferência de moeda para o exterior)

ARTIGO 465.º (Introdução ilícita de moeda estrangeira no País)

ARTIGO 466.º (Comércio ilegal de moeda)

ARTIGO 467.º (Proibição de pagamentos em numerário)

ARTIGO 468.º (Retenção de moeda)

ARTIGO 469.º (Circulação não autorizada de moeda)

ARTIGO 470.º (Rejeição de moeda com curso legal)

ARTIGO 471.º (Movimentos e operações bancários ou financeiros ilegítimos)

ARTIGO 472.º (Fraude nos pagamentos electrónicos)

ARTIGO 473.º (Exploração e tráfico ilícito de minerais

PARTE I

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

DIREITO PENAL NO SISTEMA JURÍDICO ANGOLANO

TÍTULO

INTRODUÇÃO

CAPÍTULO I

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

I. Conceitos basilares em direito penal

1. Noção de direito penal e de crime

Chama-se direito penal ao conjunto de normas jurídicas que ligam a certos comportamentos humanos – os crimes – determinadas consequências jurídicas privativas deste ramo de direito. A mais importante destas consequências, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, é a pena, a qual só pode ser aplicada ao agente do crime que tenha actuado com culpa. Ao lado da pena prevê, porém, o direito penal consequências de outro tipo: são as medidas de segurança, as quais não supõem a culpa do agente, mas a sua perigosidade[1].

Nas lições do Prof. GERMANO M. SILVA, o direito penal é um sistema de normas jurídicas que atribuem aos agentes de certo comportamento como pressuposto uma pena ou uma medida de segurança criminais como consequência[2].

Ao nosso ver, o direito penal ou direito criminal é um **ramo do direito público**, composto por normas **imperativa**s (incriminadoras e não incriminadoras), criadas pelo **Estado (nos termos do art. 164.º alíneas b), c) e e) CRA de 2010)**, **punem** com penas, (principais, de substituição e acessórias) e com as medidas de segurança, certas condutas socialmente reprováveis cujo, o seu cumprimento é de carácter **obrigatório,** normas essas que visam, por um lado, limitar o exercício do **poder do Estado** e por outro, salvaguardar os **bens jurídicos fundamentais** penalmente protegidos.

[1] Jorge de Figueiredo Dias, *Direito Penal, Parte Geral,* J, 2.ª ed., Coimbra, 2007, p. 3.

[2] Germano Marques da Silva, *Direito Penal Português-Introdução a Teoria da Lei Penal, Ed. 3.º.*, Loures: 2010, p.30.

1.1. Crime (sentidos em pode ser definido a palavra crime)

Em termos gerais crime é um conjunto de pressupostos de que depende a aplicação ao agente de uma pena ou medida de segurança.

O crime pode ser definido em duas perspectivas, por um lado, do ponto de vista sociológico (esta perspectiva não é relevante para o direito penal) e por outro lado, na perspectiva do direito positivo.

a) Sentido Sociológico de crime

Em sentido sociológico, o crime pode ser definido ou considerado como um comportamento desviante, socialmente danoso capaz de provocar reacções emotivas a sociedade.

b) Do ponto de vista do direito positivo o crime divide-se em:

- ✓ Crime em sentido formal;
- ✓ Crime em sentido material;
- ✓ Crime em sentido analítico.

Crime em sentido formal

Formalmente crime é o que está descrito no art. 1.º, do CP *in fine*, estabelece que, o crime é "o facto descrito e declarado passível de pena por lei". Sendo o próprio Código, no art. 39.º, que diz quais são as penas.

Crime em sentido material

Materialmente crime é todo o facto ou comportamento humano que lesa ou ameaça de lesão (põe em perigo) bens jurídicos fundamentais.

Crime em sentido analítico

Analiticamente crime define-se como sendo - um conjunto de elementos (acção, tipo ou tipicidade, ilicitude, culpa e punibilidade), que devem ser minuciosamente analisados. Este é o conceito maioritariamente aceite pela doutrina. Será desenvolvido no âmbito da teoria da infracção. Ou seja, analiticamente crime é uma acção típica, ilícita e culposa.

Importância da definição de crime

A definição de crime tem importância na medida em que, impõe limitações. Além do conceito formal de crime, há um problema de política criminal: precisamos de saber, quando é que é legítimo, possível, aconselhável, que direito penal pegue num certo acto e o qualifique como crime?

Dado que, há uma tendência para restringir ao máximo o âmbito do direito penal, que se justifica pelo facto de o direito penal representar uma redução significativa dos direitos, liberdades e garantias individuais, ele funciona limitadamente.

Assim sendo, o direito penal funcionará para impedir que as pessoas façam algo considerado como nocivo pela sociedade. Perante a especial gravidade da ameaça, da sanção (*maxime* a pena de prisão), só valerá a pena pagar esse custo social nas situações em que não seja possível arranjar outro remédio.

Somos de opinião que a pena de prisão na maior parte dos casos, é irrelevante sua aplicação. É feliz o legislador ordinário ao incluir no código penal de 2020 o art. 69.º, ao estabelecer como regra a pena multa e a pena de prisão como excepção, tendo em conta o caso em concreto. Por força do referido artigo, pede-se ao **Estado que evite o máximo possível a aplicação da pena de prisão, pois ela é a mais onerosa para o Estado, em relação ao condenado.**

Clarificando:

• Em princípio, o direito penal só deve intervir quando seja essencial, ou seja, quando outro ramo do direito não seja suficiente para resolver certo tipo de problema;

• O Estado deve evitar colocar o direito penal em zonas respeitantes à moral privada das pessoas (homossexualidade, prostituição, adultério…);

• O Direito Penal deverá deixar de fora actos que possam causar eventuais prejuízos.

2. Designação de direito penal

Para efeitos de designação discute-se bastante a nível da doutrina, qual a terminologia que deve ser usada: Direito Penal ou Direito Criminal? A doutrina diverge e a própria lei também – nuns sítios chama-lhe Direito Penal, noutros Criminal.

Esta questão não tem grande importância – a única argumentação que se pode fazer é que se falamos em Direito Penal pode considerar-se que estão de fora as medidas de segurança, e, portanto, não abrangia esta zona importante deste ramo do Direito. Por outro lado, ao usarmos a terminologia Direito Criminal, há uma referência a um crime com sentido subjectivo, do qual a pessoa é culpada, o que exclui a aplicação do ramo do direito aos inimputáveis.

Não obstante a essa querela é ponto assente na doutrina que, o designativo deve ser e é, direito penal e não direito criminal. (*Vide*. F. DIAS-p. 3-6). Vai mais longe o Prof. F. DIAS ao sugerir que o designativo exacto para este ramo do direito seria: **direito das penas e das medidas de segurança criminais**[3]**.**

3. Objecto de estudo do direito penal

Direito penal tem como objecto de estudo o crime, estado de perigosidade criminal ou social, pena e as medidas de segurança, bem como o comportamento dos seus agentes.

4. Natureza jurídica do direito penal

A distinção entre direito privado e direito público é das mais controversas na doutrina[4], mas sejam quais forem os critérios adoptados para estabelecer a distinção, a maioria dos autores, entende geralmente que o direito penal é direito público, quer atendendo ao critério do interesse protegido, quer ao critério da posição dos sujeitos da relação jurídica[5], quer à natureza da tutela concedida aos seus preceitos.

A classificação do direito penal como direito público tem merecido, porém, reservas na doutrina. Assim, entre os autores portugueses, no caso o Prof. OLIVEIRA

[3] Jorge de Figueiredo Dias, *Direito Penal, Parte Geral,* J, 2.ª ed., Coimbra, 2007, p. 5.

[4] João de Castro Mendes, *Introdução ao Estudo do Direito, 1984, pp. 192 ss.; J. Baptista Machedo, Introdução ao Direito e ao Discurso Legiti1nador, 1985, pp. 65 ss.; Germano Marques da Silva, Introdução ao Estudo do Direito,·3.ª ed. Lisboa, 2009, pp. 145 ss.*

[5] *Cf.* Eduardo Correia, *Direito Criminal,* I, 1971, p. 10; Marcello Caetano, *Manual de Direito Administrativo,* I, 10.ª ed., pp. 49 ss.; *Lições de Direito Penal,* 1939, pp. 33-34.

ASCENSÃO[6] qualifica-o como direito dos particulares e, em França FRÉDERIC DESPORTES, considera que o direito penal tem carácter misto.

Nos ensinamentos do Prof. GERMANO M. DA SILVA, classifica-o como um direito público, porém, com uma valia reduzida, sendo certo que, cada vez mais os interesses dos particulares enquanto tais, isto é, das vítimas dos crimes, assumem especial relevância, sobrepondo-se mesmo em muitos casos ao interesse público na punição dos crimes e dos criminosos. Por isso, que tenda a firmar-se o carácter autónomo do direito penal com os seus objectivos próprios e também os seus próprios conceitos[7].

Em suma, na classificação tradicional entre direito público e direito privado o direito penal é direito público por excelência[8]. Ou seja, o direito penal tem uma natureza pública.

5. Parte geral e parte especial do direito penal e suas componentes[9]

É corrente a distinção entre **parte geral e parte especial do direito penal**, distinção que corresponde aos princípios comuns a todos os crimes e aos crimes em particular, respectivamente. É assim, também o Código Penal de 2020. Conforme já referimos, a **parte geral** começa do artigo 1.º ao 146.º, a **parte especial** começa do artigo 147.º ao 473.º.

Parte Geral – estabelecem regras comuns a todos os crimes, que são depois tipificados na parte especial.

---

[6] José de Oliveira Ascensão, O *Direito - Introdução e Teoria Geral,* 10.a ed., 1997, p. 348: A não se querer considerar o Direito Penal direito privado, caberia pelo menos num amplo «direito dos particulares», em que se abrangeriam todos os ramos destinados a delimitar o estatuto dos privados, por oposição àqueles que se referem à estruturação e à actividade dos entes públicos. Ou seja, não há nenhuma linha de fractura entre o interesse público e o interesse privado.

[7] Germano Marques da Silva, *Direito Penal Português-Introdução a Teoria da Lei Penal, Ed. 3.º.*, Loures: 2010, p. 113.

[8] Jorge de Figueiredo Dias, *Direito Penal, Parte Geral,* J, 2.ª ed., Coimbra, p. 115.

[9] **Parte geral** - definem: os pressupostos de aplicação da lei penal, os elementos constitutivos do conceito de crime e as consequências que derivam da realização de um crime (penas e medidas de segurança), é composta pelas normas penais não incriminadoras.

Parte especial – estabelecem: os crimes singulares e as consequências jurídicas que à prática de cada um deles concretamente se ligam (é composto pelas normas penais incriminadoras).

Parte Especial - Trata-se de uma questão simplesmente técnica de fixação das normas penais incriminadoras e nalguns dos casos das normas não incriminadoras (Ex.: 154.º n.º 1 al. c), 181.º, 250.º, 255.º, 376.º, 383.º, 391.º, 437.º, todos do CP).

Uma parte completa a outra, pois a parte geral sem a parte especial não faz sentido e as regras da parte especial, têm de ser completadas com as da parte geral, para se determinarem as normas de conduta. Também se usam as expressões direito penal geral para identificar a parte geral do código e direito penal especial para designar a parte especial do código.

6. Expressões recorrentes em direito penal

6.1. Direito penal objectivo ou *ius poenale*

O *ius poenale* – é conjunto de normas e regras que se ocupam da definição das infracções penais e da imposição de suas consequências (penas ou medidas de segurança).

6.2. Direito penal subjectivo ou *ius puniendi*

O ius puniendi - é o direito de punir do Estado, isto é, o direito que o Estado possui de exigir que as pessoas se abstenham de praticar uma conduta definida como crime. Por outras palavras, ***ius punidendi***, é poder punitivo do Estado, resultante da sua soberana competência, para considerar como crimes certos comportamentos humanos e ligar-lhes sanções específicas. Deste pondo de vista pode afirmar-se que o direito penal objectivo é expressão ou emanação do poder punitivo do Estado[10].

6.3. Natureza jurídica do ius *puniendi*

O poder punitivo do Estado, pode perspectivar-se de três modos:

a) Definição das normas incriminadoras (definir os crimes e as respectivas sanções);
b) Aplicação da norma por meio do processo (declarar a prática do crime, quem foi o criminoso e aplicar-lhe as respectivas sanções);
c) Execução da pena concretizada na sentença condenatória[11].

[10] Jorge Figueiredo Dias. *Ob., cit.*, p. 6
[11] Germano Marques da Silva. *Ob., Cit.*., p. 36.

6.4. Direito penal formal ou adjectivo

Formalmente o direito penal - é definido como um conjunto de normas jurídicas que regulam, os requisitos e as consequências de um comportamento punível ou sujeito a medidas de segurança.

6.5. Direito penal material ou substantivo

O direito penal material ou substantivo – estabelece por forma geral e abstracta, quais os factos que devem ser considerados crimes e quais as penas aplicar, saber porém, se um dado caso, um certo individuo praticou um facto e qual é a pena que se adequa a esse facto.

6.6. Direito penal comum e direito penal especial, complementar ou particular

O direito penal comum - é aquele que tem assento no texto fundamental, normalmente o Código Penal e, corresponde às disposições básicas do direito penal, aplicáveis também às demais leis penais que não constam desse texto base (ex.: art. 7.º do CP).

6.7. Direito penal especial, complementar e particular

O direito penal especial - não consagra uma disciplina directamente oposta à do direito penal comum; consagra simplesmente uma disciplina nova para certo número de crimes, agrupados em função de um determinado núcleo de interesses ou bens jurídicos, e, por isso, cabe-lhe bem também as designações de direito **penal complementar e de direito penal particular.**

O designativo direito penal particular e direito penal complementar - é o que se encontra nas leis penais que não constam daquele texto base (o Código Penal), denominado frequentemente como leis penais extravagante.

6.8. Direito penal clássico ou de justiça e direito penal secundário

Segundo esta distinção, o direito penal clássico ou de justiça - tutela os bens jurídicos fundamentais da vida comunitária ou da personalidade, aqueles que, directa ou indirectamente, estão ligados aos indivíduos. Mas sempre de maneira essencial, se relacionam com o livre desenvolvimento da personalidade de cada homem como tal e com interesses fundamentais da vida comunitária: (a vida humana, a integridade física, a liberdade sexual, a honra, o património das pessoas, bem como a constituição e desenvolvimento da família, a segurança interna e exterior do Estado)[12].

O **direito penal secundário** - tutela os bens jurídicos que se relacionam com a actuação da personalidade do homem como fenómeno social, aqueles bens de criação ou manutenção de uma certa ordem social e por consequência mais ou menos indiferentes à ordem moral[13].

6.9. Direito penal angolano e direito penal estrangeiro

Analisaremos detalhadamente no capítulo em que, trataremos da validade da lei penal no espaço, por agora importa dizer que, há casos em que, os tribunais angolanos devem aplicar a lei penal estrangeira. É o que sucede, desde logo por força do disposto nos n^{s}. 2, 3 e 4 do art. 5.º. Com efeito, o referido artigo no seu n.º 1, dispõe que a lei penal angolana é aplicável a factos cometidos fora do território angolano.

O art. 5.º n.º 2, restringe nesses casos a aplicação da lei penal angolana ao estabelecer que "o disposto no número anterior só tem aplicação quando o agente não tiver sido julgado no país em que cometeu o crime ou se, posteriormente se tiver subtraído ao cumprimento, total ou parcial, da sanção em que tenha sido condenado". Esta regra é uma consequência do princípio da subsidiariedade da aplicação da lei nacional a crimes praticados fora do território nacional.

6.10. Direito penal internacional

A expressão direito penal internacional, cuja paternidade é geralmente atribuída a Bentham, designa um conjunto de normas de direito nacionais relativas aos limites de aplicação da lei penal no espaço, tem sido controvertida. Não cabe nos limites desta

[12] Eduardo Correia, *Direito Criminal,* I, Coimbra, 1961, p. 28.

[13] Eduardo Correia, *ob. e loc. cit.*, Jorge de Figueiredo Dias, «O movimento da descriminalização e o ilícito de mera ordenação social», *Jornadas de Direito Criminal* - O *Novo Código Penal Português e Legislação Complementar,* p. 323.

obra participar na discussão sobre a designação mais adequada, mas tão-só esclarecer que direito penal internacional é um ramo do direito interno.

6.11. Direito internacional penal

Direito internacional penal é o ramo do direito público internacional que determina as infracções, estabelece as penas e fixa as condições da responsabilidade penal internacional dos Estados e dos indivíduos.

6.12. Direito Penal do Inimigo e direito penal do cidadão

O denominado direito penal do inimigo cujo, o principal exponente é JAKOBS, trata o delinquente como inimigo, inspirando-se nas leis da guerra, ou seja, limitando as garantias características do direito penal liberal que, por contraposição àquele, é denominado por direito penal do cidadão. No âmbito do sector da criminalidade mais grave, cuja manifestação extrema seria o terrorismo, a luta contra os criminosos, deverá processar-se como uma guerra.

O criminoso é considerado como alguém que pela sua posição, forma de vida ou pertença a organização criminosa se excluiu do Direito de forma duradoura e por isso não deve ser tratado como cidadão, mas como inimigo. **Seriam características deste sector do direito penal a antecipação da punição** para momentos antes do facto consumado sem qualquer redução da pena (punição dos actos preparatórios e construção dos tipos como de mero perigo) e a redução das garantias processuais já que se trata de uma guerra[14].

6.13. Direito penal do facto

Como já vimos, o crime é um facto, um comportamento humano. O art. 1.º do Código Penal dispõe que, só pode ser punido criminalmente o facto. O brocardo *«cogetationes poena nemo patitur»* (ninguém deve sofrer pena pelos seus pensamentos) exprime uma exigência de segurança sob o risco de se punir meras intenções.

[14] Germano Marques da Silva, *Direito Penal Português-Introdução a Teoria da Lei Penal, Ed. 3.º.*, Loures: 2010, p. 211.

A segurança jurídica e o fim de protecção de bens jurídicos fazem com que, apenas tenham relevo penal os actos que constituam concretamente um início de execução do facto-crime e não meros pensamentos ou estados de ânimo. Nem sequer os actos preparatórios devem ser puníveis, porque são equívocos, salvo quando representem por si sós um perigo grave para os bens jurídicos tutelados pelo direito penal. (**Ex.:** 336.º São punidos com pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 360 dias os actos preparatórios dos crimes previstos nos artigos 316.º a 318.º, 320.º e 321.º, 323.º, 325.º e 329.º a 331.º, todos do CP).

A punição da mera perigosidade sempre foi o recurso dos sistemas políticos totalitários, como se deu com o nazismo e o comunismo, em que alcançava relevo a predisposição de agir em ofensa ao «são sentimento do povo alemão» ou toda a acção socialmente perigosa dirigida contra a ordem jurídica socialista[15].

7. Âmbito ou extensão (direito penal em sentido amplo) do direito penal

7.1. Direito penal substantivo

O direito penal substantivo - é um conjunto de normas e regras que se ocupam da definição das infracções penais e da imposição de suas consequências (penas ou medidas de segurança), este encontra-se no código penal. Ou seja, esse é o direito penal propriamente dito.

7.2. Direito penal adjectivo ou direito processual penal

Cuida o direito processual penal ou adjectivo - a aplicação, à realização e concretização do direito penal ou do direito substantivo, este encontra-se no código processo penal.

7.3. Direito penal executivo

O direito penal executivo ou executório - é o direito constituído pelas normas que regulam, a execução das penas e medidas de segurança privativas de liberdade.

Por outras palavras, é o direito que visa a regulamentação jurídica dos modos de realização do poder punitivo estadual, nomeadamente através da investigação e da valoração jurídica do crime indiciado ou acusado.

[15] Germano Marques da Silva, *Ob., Cit.,* p. 96.

CAPÍTULO II

TEORIA DA LEI PENAL

1. Conceito de norma penal

Norma é sinónimo de regra e também de lei, significa a fórmula que exprime a ligação de uma estatuição à previsão de um facto ou situação[16].

Por outras palavras, normas jurídicas são regras de conduta sociais, gerais, abstractas e imperativas, adoptadas e impostas de forma coercitiva pelo Estado, através de órgãos ou autoridades competentes[17].

2. A estrutura das normas penais

A norma penal é uma norma jurídica, enquanto **norma** - orienta e disciplina os comportamentos humanas, enquanto **jurídica** - faz recair sobre os destinatários que a infrinjam uma sanção que consiste numa pena ou medida de seguranças criminais. Como em qualquer outra norma jurídica, a norma penal compõe-se de duas partes, **um antecedente** e **um consequente**, ou seja, preceito penal primário (previsão) e o preceito penal secundário (estatuição).

2.1. Preceito penal primário

Preceito penal primário é a previsão considerada como o facto proibido. A previsão da norma, também recebe o nome de hipótese, preceito, tipo legal e factispécie, refere o modelo de comportamento humano típico, o facto ou conjunto de factos cuja ocorrência histórica desencadeia a consequência jurídica fixada na estatuição[18].

[16] João de Castro Mendes, *Introdução ao Estudo do Direito,* Lisboa, 1984, p. 49.

[17] Bartolomeu L. Varela, *Manual de Introdução ao Direito,* 2ª ed., Praia, p. 33.

[18] Germano Marques da Silva, *Ob., Cit.,* p. 247.

2.2. Preceito penal secundário

Preceito penal secundário também designado de estatuição é a consequência jurídica. Por outras palavras, a estatuição corresponde à consequência da verificação da hipótese, ao efeito jurídico da violação do preceito da realização do comportamento conforme ao modelo que o tipo legal ou factispécie descreve. Na norma penal a estatuição corresponde à pena ou medida de segurança criminais.

3. Classificação das normas penais

Existem diversas classificações das normas penais, sendo que as mais importantes podem ser feitas da seguinte forma:

3.1. Normas penais incriminadoras

Normas penais incriminadoras - são aquelas que definem os crimes e estabelecem as penas, numa designação ampla abrangem também os pressupostos das medidas de segurança e as medidas aplicáveis. Por outras palavras, a normas penais incriminadoras são as que descrevem condutas puníveis e impõem as respectivas sanções[19]. Estão presentes na parte especial do Código Penal e na legislação extravagante. Não existem normas penais incriminadoras na parte geral do Código.

As normas incriminadoras comportam na sua estrutura dois preceitos: primário e secundário, conforme dito no parágrafo *supra* (o preceito primário – define o crime e o preceito secundário – comina a pena). **As normas penais incriminadoras, ensina o Prof. CAVALEIRO DE FERREIRA que podem ser**[20]:

3.1.1. Normas conjuntas ou cumulativas

Normas conjuntas ou cumulativas - são aquelas em que o mesmo preceito da lei contém uma pluralidade de incriminações[21]. (ex.: prisão e multa)

3.1.2. Normas alternativas

[19] Aiken Renkel Afonso, *Resumo de Direito*, 2.º Ed., Lubango, 2021, p. 38.

[20] Cavaleiro de Ferreira, *Lições de Direito Penal*, vol. I 1992, p. 63.

[21] Henriques Eiras e Guilherme Fortes, *Dicionário de Direito Penal e Processo Penal*, 3.º Ed., Lisboa, 2010, p. 507.

Normas alternativas - são aquelas em que as disposições legais diversas estão previstas em diferentes modalidades de execução do mesmo crime[22].

3.1.3. Normas penais em branco

O actual conteúdo do princípio legalidade exige que as leis penais sejam, por um lado, precisas (que o seu sentido seja delimitado ou facilmente delimitável). Este princípio exclui a constitucionalidade das leis penais vagas ou imprecisas e, designadamente, daquilo a que chamamos **leis penais em branco.**

Há várias definições possíveis para o que seja, uma lei penal em branco, embora no seu sentido técnico, mais próprio, será a que remete para uma fonte normativa de valor hierárquico inferior. Por exemplo: o art. 273.º do CP e o art. 257.º do CP.

Estas normas em princípio devem, ser condenadas ou afastadas, pois desdizem a necessidade de precisão exigida pelo princípio da legalidade e deixam no vago ou numa instância inferior os próprios pressupostos de aplicação. Tanto a imprecisão como a remissão do conteúdo são condenáveis, devido à reserva constitucional de lei (prevista nos termos do art. 164.º CRA de 2010).

Mas não são apenas as normas penais em branco que contrariam a desejável ou necessária precisão da lei penal. A imprecisão de expressões utilizadas pelas normas penais apesar de inevitável é de evitar.

Casos mais flagrantes de imprecisão:

- ✓ Normas que prevêem, a punição de crimes negligentes (ex.: 152.º, n.º 2, CP);
- ✓ Normas derivadas de certos preceitos da lei penal, que se diz punirem crimes omissivos impuros 8.º n.º 3, do CP;
- ✓ Normas que prevêem, as actividades económicas proibidas (art. 462.º do CP).

A necessária precisão penal e as dificuldades em consegui-la

[22] Ibidem

Uma das exigências do princípio da legalidade é que a lei deve ser precisa, na medida em que, uma lei vaga não assegura a protecção efectiva dos direitos individuais. Haver uma lei em relação à qual é difícil dizer que actos proíbe ou condena, será um pouco semelhante a não haver nenhuma.

SOUSA e BRITO: consideram que, a indeterminação das precisões legais é o calcanhar de Aquiles do princípio da legalidade. Por muitas consagrações constitucionais que se façam ao princípio, se as normas concretamente consideradas de um sistema jurídico-penal, não respeitam a exigência da precisão e de fácil delimitação, a garantia fica um pouco na sua própria formalidade e não adianta grandemente a ninguém.

A precisão é de facto difícil e podemos encontrar no CP muitas expressões cujo sentido é difícil delimitar, tendo os tribunais um papel importantíssimo neste âmbito.

As normas penais em branco e as expressões vagas utilizadas na lei penal

Por vezes, nos vários ramos do direito, é difícil usar expressões unívocas – no direito penal também há expressões sujo uso é difícil de evitar e que comprometem a precisão da lei criminal.

Por outro lado, a própria lei incriminadora remete, por vezes, para outra fonte normativa o preenchimento dos seus próprios pressupostos.

Isto quer dizer, que a lei penal em si não é clara, pois não dá imediatamente às pessoas a noção perfeita das situações e do risco que correm de sofrer uma pena consoante façam ou não certas coisas, quer dizer também que, em última análise, quem vai definir os pressupostos de aplicação desta lei já não é a AN, mas outra entidade que poderá ser uma autoridade administrativa.

Tanto, quanto à precisão da norma como quanto à reserva de competência, as normas penais em branco são normas que também põem em causa a efectividade do princípio da legalidade, a propósito do conteúdo da própria lei incriminadora.

O problema de indeterminação das normas é básico, geral e comprometedor do funcionamento do princípio da legalidade: este pode existir, pode estar consagrado na própria constituição, mas se as leis penais forem indeterminadas, vagas ou imprecisas, esse será o ponto fraco na efectividade prática do princípio.

A possibilidade do arbítrio do juiz será maior quando a expressão legal não seja clara (veja-se o exemplo do art. 187.º CP "identidade pessoal"). Um dos aspectos mais importantes da clareza das leis penais é este: têm de expressar conexão entre a infracção-previsão e a sanção-estatuição. Pois não basta a lei determinar - dado facto como proibido ou criminoso, sem ausência de especificação da pena aplicável – não haveria garantia de legalidade dada pelo art. 65.º CRA de 2010.

Concluindo:

Nas lições do Prof. GERMANO M. SILVA, a norma penal em branco, em sentido próprio, é aquela em que a descrição da conduta proibida requer um complemento extraído de um outro diploma oriundo de uma outra fonte legiferante de hierarquia inferior ou mero acto administrativo, para que possa efectivamente ser entendido o limite da proibição ou imposição feitos pela norma penal, uma vez que sem esse complemento torna-se impossível a sua aplicação[23].

3.2. Normas penais não incriminadoras (permissivas)

As normas penais não incriminadoras - são aquelas que disciplinam a aplicação e os limites das normas incriminadoras. Estas podem ser:

3.2.1. Normas de aplicação

Normas de aplicação – são as que estabelecem os limites de aplicabilidade das normas incriminadoras (ex.. arts. 2.º a 6.º do CP).

3.2.2. Normas declarativas ou explicativas

Normas declarativas ou explicativas – são aquelas que definem certos conceitos previstos na lei (ex.: arts. 12.º e 13.º, 19.º 29.º 181.º, 250.º 255.º, 376.º, 383.º 391.º, 437.º e etc. do CP).

3.2.3. Normas directivas

Normas directivas – são as que fixam os princípios a serem observados em determinadas matérias (ex.. arts. 8.º, 9.º, 10.º e 11.º do CP).

[23] Germano Marques da Silva, *Ob., Cit.,* p. 253.

3.2.4. Normas interpretativas

Normas interpretativas – são aquelas que servem à interpretação de outras normas (ex.: art. 1.º, n.º 3, do CP).

3.2.5. Normas permissivas

Normas permissivas – são aquelas que permitem a prática de determinados actos que normalmente seriam proibidos (ilícitos), mas que em razão de especiais circunstâncias são permitidos e lícitos (ex.. arts. 30.ºe ss 36 e ss.º, 156, n.º 1 al. c) do CP).

CAPÍTULO III

CIÊNCIA CONJUNTA DO DIREITO PENAL (ENCICLOPÉDICA DO DIREITO PENAL)

I. Evolução histórica do direito penal

A história do Direito Penal está visceralmente ligada à história da pena. Como será visto a seguir. O mesmo Estado que buscou monopolizar a distribuição da justiça, editando regras e normas comportamentais a serem regiamente obedecidas por seus destinatários, foi tirânico e desumano no que tange à intensidade da resposta oficial àqueles que se afastaram de seus comandos. Neste sentido, RENÉ ARIEL DOTTI transcreve texto do jurisconsulto português SILVA FERRÃO, cuja obra foi editada em 1856, onde foi realizado um breve apanhado do Direito Penal alusivo aos últimos quatorze.

É facto incontroverso que o desenvolvimento do Direito Penal variou de povo para povo, região a região, tendo em vista o nível de desenvolvimento de cada uma das culturas onde aflorou e se estabeleceu. Do mesmo modo, não há dúvida de que os contornos, postulados e princípios, hoje prevalecentes, no Direito Penal de grande número de países fora cunhados lentamente.

O Direito Penal pode ser analisado em períodos históricos, os quais não guardam absoluta independência entre si, ou seja, as fases a seguir descritas não formam compartimentos estanques, findando uma e imediatamente tendo início a próxima.

Antes, ao contrário, permeiam-se, misturam-se, porém, cada uma possui traços e características próprias, o que as faz possuírem certa identidade. Referidas fases são comummente denominadas **de vingança privada, vingança divina, vingança pública, período humanitário e período científico, este último, também denominado período criminológico.**

Passemos, de forma abreviada, a verificar as características de cada uma delas em âmbito mundial e, paralelamente, sua manifestação em terras angolanas. Verifiquemos-ainda, os traços mais característicos do Direito Penal romano, grego e germânico, em face de sua grande importância e influência.

1. Vingança Privada

Nos primórdios da civilização não havia qualquer espécie de administração pertinente à justiça. Caso alguém ofendesse um seu semelhante, nem sempre o revide guardava razão de intensidade à agressão sofrida.

Em muitas ocasiões sequer era dirigido ao agressor, mas sim aos membros de sua família ou tribo, gerando, não raro, resposta mais hostil. Quando a infracção era praticada por um membro do próprio grupo "a punição, em regra, era o banimento, conhecido como perda da paz, fazendo com que o infractor ficasse desprotegido, à mercê de tribos rivais.

Não havia senso de justiça. A reacção era puramente instintiva e, como mencionado, normalmente desmedida, não havendo proporcionalidade e nem pessoalidade quanto ao revide, "reinava a responsabilidade objectiva, e desconheciam-se princípios como o da proporcionalidade, humanidade e personalidade da pena.

O contra-ataque por vezes acabava por alcançar pessoas relacionadas ao ofensor, enfraquecendo famílias e grupos, dizimando tribos inteiras. Com a evolução do homem, surge uma medida que objectivava limitar o direito de desforra, dando origem a pena de Talião.

A pena de Talião implicava na ideia de compatibilidade: olho por olho, dente por dente. Surgiu no Código de Hamurabi, Rei da Babilónia, em XXIII a. C., posteriormente espraiando-se para outras legislações. Se por um lado, não afastou a violência da

repulsa, por outro, teve o mérito já mencionado de conferir-lhe a noção de dimensão, evitando o aumento incontido do conflito inicial.

Relativamente em Angola, há que se considerar que não havia, evidentemente, logo após sua descoberta pelos portugueses, qualquer organização legal. Seus habitantes, isto é, os povos Bantus, Khoisan e Bosquimanes, contavam com diferentes graus de evolução cultural, variavam conforme a localização das aldeias e, as regras prevalecentes eram calcados em costumes, crenças religiosas e tradições que mudavam de tribo à tribo, possuindo características próximas às constantes deste período.

As normas de conduta indígenas nenhuma influência exerceram sobre a legislação portuguesa. Porém, é necessário destacar, conforme relatam os historiadores, que nada obsta, nossos indígenas vivessem no estágio da pedra lascada, já aplicavam o talião.

Ainda durante este período, considerando o facto de que a pena de Talião, relacionado ao Kwata-Kwata, muitas vezes chegou a enfraquecer a tribo, pois, quando aplicada dentro do próprio grupo acabava por diminuir a força física de seus guerreiros em decorrência das mutilações provocadas e das deportações destes para as colónias, deixando a colectividade à mercê de bandos dominadores.

Outro instituto relevante criado entre os povos germânicos foi a composição (*compositio)* - consistia na possibilidade concedida ao ofensor de “comprar” o direito de revide do ofendido ou de sua família, mediante o pagamento em moeda, metais preciosos, armas, gado, utensílios, roupas etc. Em síntese: a punição, que até então era estritamente corporal, passou a admitir a possibilidade de sua substituição por valores ou bens. Tem-se na composição, segundo a doutrina, a origem remota da indemnização, prevista no Direito Civil, bem como, da pena de multa do Direito Penal.

2. Vingança Divina

Neste período, acreditava-se que os Deuses eram guardiões da paz e o eventual crime cometido era considerado uma afronta às divindades. Para que a tranquilidade fosse restaurada, sacrifícios humanos deveriam ser realizados. Deste modo, mediante a prática de um único acto, três medidas eram adoptadas:

Satisfazia-se o Deus maculado, punia-se o ofensor e intimidava-se a população para que não mais praticasse actos considerados criminosos.

Este período caracterizou-se, também, pela crueldade das penas: quanto maior a importância da divindade, agravada e mais atroz seria a punição.

Os sacerdotes eram os responsáveis pela administração da justiça, bem como pela aplicação das sanções. Tendo em vista essas características, o Direito Penal em vigor foi denominado Direito Penal Teocrático. A legislação egípcia, hebraica, chinesa e indiana, entre outras, foram exemplos desta fase.

3. Vingança Pública

Com o desenvolvimento e organização da sociedade, a tutela penal deixa de ter conteúdo eminentemente teocrático, desconsiderando situações particulares, passando a ser centralizada nas mãos dos soberanos.

Neste contexto, a reprimenda imposta ao transgressor da lei passa a ser a resposta oficial, apresentada pelo Estado, tendo como objectivo proteger a colectividade. Porém, na verdade, o que se viu foram situações despóticas, pois o senhor reinante, que então concentrava poderes quase absolutos, podia considerar criminosas, caso fosse conveniente as condutas que bem entendesse, deixando a população aterrorizada, pois que não tinha segurança jurídica.

A par desta abusiva utilização do poder, tem-se que a justiça tratava desigualmente os cidadãos. Os mais abastados eram normalmente poupados da severidade e crueldade das penas então vigentes, ao passo que a população menos privilegiada sofria em demasia.

A igreja notadamente a Católica, continuava exercendo grande influência na distribuição do Direito. Segundo a doutrina da justiça criminal, na maior parte do 2º milénio (mais precisamente até o Iluminismo, que eclodiu na segunda metade do século XVIII), encarregou-se a Igreja, os Senhores Feudais (prepotentes e arbitrários) e os Governos Absolutos ou Monárquicos (autoritários). Foi um Direito penal exageradamente cruel, desumano e não garantista, apesar da Great Charter de João Sem-Terra, de 15 de Junho de 1215, terem engajado bastantes esforços, no combate as desigualdades existentes na época (que somente valeu – quando valeu – para os nobres; dela pouco, ou muito pouco usufruíram os plebeus).

Para se ter ideia do que representou no passado o sistema de atrocidades judiciárias, não será necessário remontar a mais longe que há três séculos. Na França, por exemplo, ainda depois do ano de 1700, a pena capital era imposta de cinco maneiras: **esquartejamento, fogo, roda, forca e decapitação**.

O esquartejamento, infligido notadamente no crime de lesa-majestade, consistia em prender-se o condenado a quatro cavalos, ou quatro galeras, que se lançavam em momento em diferentes direcções. **A morte pelo fogo** - verificava-se após ser amarrado o condenado a um poste, em praça pública, onde era o corpo consumido pelas chamas. **O suplício da roda** - era dos mais cruéis: de início, o paciente, que jazia amarrado, era esbordoado pelo verdugo, até que lhe partirem os membros. Em seguida era colocado sobre uma roda, com a face voltada para o céu, até expirar[24].

Nessa época o direito penal também sofreu grande influência da Igreja: confundia-se o pecado com o delito (valeu-se também a Igreja do Direito penal para preservar o seu poder). Os crimes mais hediondos naquela época eram: lesa-majestade humana (crime contra o rei) e lesa-majestade divina (heresia, apostasia, blasfémia, feitiçaria etc.[25]).

4. Período Humanitário

O século XVIII, denominado “séculos das luzes”, trouxe profundas modificações para inúmeras áreas do saber: as ciências, as artes, a filosofia, não tendo o Direito permanecido indiferente nesta verdadeira revolução mundial do bem.

Os maiores expoentes da seara penal foram CESARE BONESSANA, também conhecido como MARQUÊS DE BECCARIA e JOHN HOWARD.

CESARE BONESSANA (1738–1794), filósofo, criado em família abastada, aos 27 anos publicou em Milão, em 1764, um opúsculo que mudaria os rumos do Direito Penal mundial intitulado *Dei delitti* e dele pene[26]. Basicamente combatia o sistema penal então vigente, criticando, dentre outros, os seguintes itens:

[24], Basileu Garcia. *Instituições de Direito Penal*, v. 1., 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1956, p. 15-16.

[25]Luiz Flavio Gomes; Pablo de Molina, Antonio García; AliceBianchini, *Direito Penal*. Coord. Luiz Flávio Gomes. v. 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.85.

[26]Cesare Beccaria Dos delitos e das penas. 3ª ed. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

1. A forma de aplicação e a linguagem utilizada pela lei, pois grande parte dos acusados, além de analfabetos, não tinha sequer noção dos dispositivos legais;

2. A desproporção entre os delitos cometidos e as sanções aplicadas;

3. A utilização indiscriminada da pena de morte;

4. A utilização da tortura como meio legal de obtenção de prova;

5. Criticou as condições das prisões.

Trouxe ideias a fim de combater o crime. Indiscutivelmente os postulados de BECCARIA, foram influenciados por MONTESQUIEU (1689–1755) e ROUSSEAU (1712–1778), tendo buscado muitos de seus fundamentos na obra "O Contrato Social", publicada em 1762. Importante destacar que MARQUÊS DE BECCARIA, não foi o primeiro a abordar o tema àquela época, porém, teve o mérito, em decorrência da forma como se expressou, despertar a atenção de grande parte da população.

Conforme explana NEY MOURA TELES, logo após a publicação da obra de Beccaria, surgem leis aderindo aos preceitos por ele defendidos. Em 1767, na Rússia, Catarina II promove profunda reforma legislativa. Na Toscana, em 1786, são abolidas a tortura e a pena de morte. Na mesma linha, na Áustria e na Prússia as ideias iluministas se concretizam em leis humanitárias[27].

É o que se convencionou denominar "despotismo ilustrado. Cerca de um século após, em 1777, na Inglaterra, JOHN HOWARD publica a obra "*The state of prisions in Ingland end Wales"*. Após ser designado *sheriff* de *Bedford*, JOHH HOWARD, ter-se-ia apaixonado pelo tema das prisões[28].

Nomeado alcaide daquele condado em 1773, teve contacto directo com a lastimável situação das prisões. Viajando por inúmeros países da Europa, verificou que as condições encontradas no condado se repetiam em outras nações: locais húmidos, sem ventilação, sem luz, infectados por vírus, piolhos, carrapatos, gerando toda sorte de doenças.

[27]Ney Moura Teles, *Direito Penal, Parte geral*. v. 1, 2ª ed. São Paulo, Atlas, 2006, p. 24.

[28] Cezar Roberto Bitencourt. *Falência da pena de prisão – Causas e alternativas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 44.

Em sua obra pugnou por um tratamento mais digno ao preso, bem como preconizou a construção de estabelecimentos penais mais adequados às funções carcerárias. Acabou morrendo em decorrência de febres carcerárias[29]. É considerado o pai da ciência penitenciária.

5. Período Criminológico ou Científico

Após o levante provocado pelos pensadores iluministas o Direito Penal passou a ser estudado de forma mais científica e metodológica. A partir de então, os estudiosos não mais se limitaram ao exame da legislação, passando a desenvolver conceitos e teorias jurídicas, sociais e antropológicas, divisando de forma abrangente o fenómeno criminal, bem como a verdadeira função de alguns institutos penais.

O criminoso bem como as causas que o levaram a cometer o delito, passaram a ser objecto de investigação. Um dos maiores expoentes desta etapa da evolução do Direito Penal foi CÉSAR LOMBROSO, médico italiano que escreveu, em 1876, a obra *L'uomo delinquente*, na qual, após exaustivo estudos, concebeu o crime como sendo uma manifestação de factores biológicos inerentes ao agente, ou seja, para LOMBROSO os indivíduos que nascessem com determinadas características morfológicas e de personalidade, deveriam ser considerados criminosos natos, tais como: **zigomas salientes, possuir habilidade em ambas as mãos (ambidestro), possuir cabelos abundantes, ser vaidoso, preguiçoso etc.**

Foi o que se denominou atavismo. Chegou a criar uma classificação de criminosos. Inicialmente muito festejada, paulatinamente sua teoria acabou caindo em descrédito, pois divorciada da realidade, haja vista ter-se verificado que inúmeros criminosos violentos não possuíam uma só das características por ele, consideradas indicativos de absoluta propensão à prática de delitos.

Por outro lado, constatou-se que várias pessoas que ostentavam os sinais considerados atávicos, jamais, ao longo de suas vidas, tiveram qualquer envolvimento com a justiça criminal.

Nada obstante ter perdido parte de seu prestígio, é irrefutável o facto de ter atraído a atenção dos estudiosos para o agente criminoso, pois àquela época o Direito Penal

[29]Cezar Roberto Bitencourt. *Ob., Cit.,* p. 45.

"caminhava para um dogmatismo exacerbado[30]. CÉSAR LOMBROSO é considerado o criador da Antropologia Criminal.

6. Direito Penal Romano, Canónico e Germânico

6.1. Direito Penal Romano

Em seus primórdios, o Direito Penal Romano encontrava-se vinculado à religião, se separado durante a fase da Realeza.

Nesta época, os crimes foram divididos em *crimina publica*, assim considerados os mais ofensivos e *delicta* privada, havidos como infracções menos gravosas, sendo debeladas pelos próprios particulares.

Nada obstante, tenha prevalecido a pena pública, período houve em que o *pater familias* tinha poderes praticamente absolutos sobre o destino de seus familiares, podendo deliberar sobre vida ou morte[31]. Ao longo da República, paulatinamente vão desaparecendo os *delicta* privada e predominando a regulação do Estado na seara Penal.

Uma vez tornada pública a função de aplicar a sanção penal, praticamente desaparece a pena de morte, nada obstante, fossem aplicadas penas infamantes de desterro, corporais, de trabalhos forçados, entre outras. Durante o Império, houve época em que o poder do soberano foi exercido de forma absoluta, surgem os crimina extraordinária, cabendo exclusivamente ao magistrado a tarefa de acusar.

Possuíam noções a respeito dos elementos subjectivos do delito (dolo e negligência), bem como de causas de exclusão de ilicitude (legítima defesa e estado de necessidade),

[30]Júlio Fabbrini Mirabete; Renato Nalini Fabbrini, *Manual de Direito Penal*, Parte geral. v. 1., 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 22.

[31]Guilherme de Souza Nucci, *Manual de Direito Penal, Parte geral e parte especial*, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 58.

tendo desenvolvido teorias a respeito da culpabilidade e levado a efeito distinção entre imputável e inimputável.

6.2. Direito Penal Canónico

O Direito Penal Canónico, inicialmente voltado à regulação das infracções cometidas pelos eclesiásticos, passou, em decorrência da associação entre o poder papal e o poder estatal, por abarcar a população em geral. Nada obsta que as suas regras fossem abrangentes, a execução de suas decisões ficava ao encargo do Estado.

Influenciado pelo Direito Romano, ao mesclar seus institutos à doutrina cristã, acabou o Direito Canónico por adquirir feição própria.

Privilegiando a responsabilização subjectiva através da aplicação de sanções, buscou corrigir o delinquente, consagrando o princípio da igualdade entre os homens perante Deus.

Introduziu a aplicação da pena privativa de liberdade, pois até então, a manutenção do agente no cárcere era empregada como mera garantia para a execução das cruéis penas corporais então existentes (estas eram sim, as verdadeiras sanções)[32]. Em decorrência da adopção de postulados cristãos, conferiu feição mais humanista ao Direito Penal.

Estabelecia penitências para aqueles que cometessem infracções, acabou por dar origem às modernas penitenciárias. Por outro lado, os clérigos deviam cumprir referidas sanções em suas células, originando a denominação das actuais celas ou atrás das grades.

6.3. Direito Penal Germânico

Inicialmente consuetudinário, o Direito Penal Germânico listava delitos públicos, praticados contra o interesse comum e delitos privados os quais, uma vez praticados, implicavam na perda da paz.

Deste modo, cometido um delito público qualquer um estava autorizado a eliminar o criminoso e, caso se tratasse de crime privado, competia ao ofendido ou seus familiares exercer o direito de vingança. De carácter rudimentar, prevaleciam a vingança privada e a composição, mais tarde passando a vigorar o talião.

[32]Luiz Alberto Machado. *Direito Criminal, Parte geral*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 23.

A prova no Processo Penal era regida pelas ordálias ou juízos de Deus, método cruel, que tinha por fundamento a crença que determinada divindade interviria no julgamento, demonstrando a verdade, e assim, a inocência do acusado.

Referidas espécies de prova, em voga durante a Idade Média foram originadas pelos povos europeus, durante o domínio Germânico- Barbárico, consistiam em impingir ao acusado sofrimentos físicos de toda sorte, tendo-o por inocente se não sucumbisse.

Assim era a "prova pelo fogo, pela qual se entendia que, não houvesse culpa, nada sofreria o acusado caso descalço caminhasse sobre uma chapa de ferro incandescente. Do mesmo modo, a "prova das bebidas amargas, que era utilizada para a comprovação de adultério feminino, pela qual se entendia que, uma vez ingerido o líquido de sabor horrível, permanecessem naturais as feições da suposta adúltera, seria inocente, mas, caso contraísse o rosto e seus olhos ficassem injectados, sua culpa era inquestionável. Ficaram famosas ainda, a **prova das serpentes e a prova da água fria**: nesta, se o pretenso culpado submergisse seria considerado inocente, caso viesse à tona, culpado; naquela, jogado o acusado sobre os répteis, se não fosse mordido provada estaria sua inocência, caso contrário, provado estaria a culpa.

II. CIÊNCIAS PENAIS. DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL

Para a compreensão científica da tarefa de aplicação do direito penal não basta o conhecimento das normas jurídicas-penas, antes se torna indispensável o domínio das contribuições que a gama das ciências criminais pode validamente fornecer. O conjunto das referidas ciências criminais ganha o designativo de uma enciclopédia[33].

Até os finais do séc. XIX a dogmática jurídico-penal era a única ciência que servia a aplicação do direito penal e, por conseguinte, a única em que o jurista podia e deveria legitimamente cultivar. Posteriormente, contudo, reconheceu-se que a tarefa social do crime não podia bastar-se com a uma ciência puramente jurídica, normativa e dogmática. A condução com êxito daquela tarefa dependia antes também, em alto grau, de uma definição das estratégias de controlo social do fenómeno da criminalidade, cuja, as quotas aumentam que, por um lado: era o domínio por excelência da política criminal.

[33] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit., p. 19.

1. A política criminal

A política criminal corresponde à que, deve ser implementada no combate à criminalidade. "É aquele aspecto do controle penal que, diz relação com o poder que tem o Estado, de definir um conflito social como criminal[34].

Ensina GERMANO M. DA SILVA citando JOSÉ BELEZA DOS SANTOS que, a Política Criminal é parte da Política do Direito e da Política em Geral que, num primeiro momento, designa o conjunto de meios e critérios empregados ou a empregar pelo direito penal para o tratamento da criminalidade, no quadro mais geral dos meios jurídicos utilizados ou a utilizar para a consecução dos fins concretos de uma comunidade jurídico[35].

Vai mais longe o mesmo autor, ao aferir que, todo o direito penal nasce precisamente de exigências de política criminal: em concreto, a de fazer possível a convivência pacífica na sociedade. A ciência do direito penal não pode por isso escapar da política, incluindo nas suas construções científicas as consequências políticas que dela derivam. É no campo da Política Criminal (e não no da dogmática jurídico-penal), que se discute e critica-se a oportunidade, a conveniência de medidas ou soluções propostas ou existentes no direito vigente, sendo este o terreno em que se defrontam as diversas correntes de opinião sobre o que deve ser o direito penal num determinado contexto[36].

2. Criminologia

A Criminologia é um conjunto de conhecimentos que estuda o fenómeno e as causas da criminalidade, a personalidade do delinquente, sua conduta delituosa e a maneira de ressocializá-lo.

Na concepção de NEWTON FERNANDES e VALTER FERNANDES, criminologia é o "tratado do Crime".

---

[34] O penalista deve, enfim, construir um sistema penal teleologicamente orientado para a consecução da finalidade do Direito Penal. De nada adianta produzir um belo e didáctico sistema penal, uma teoria do crime harmonicamente orientada, se as soluções nem sempre forem justas e condizentes com a função do Direito Penal

[35] Germano Marques da Silva, Ob., Cit., p. 185-186.

[36] Ibidem.

A interdisciplinaridade da criminologia é história, bastando, para demonstrar isso, dizer que seus fundadores foram um médico (Cesare Lombroso), um jurista sociólogo (Enrico Ferri) e um magistrado (Raffaele Garofalo).

Quando nasceu a criminologia, tratava de explicar a origem da delinquência utilizando o método das ciências, o esquema causal e explicativo, ou seja, buscava a causa do efeito produzido.

Hoje a criminologia é uma ciência causal-explicativa. Estuda as leis e factores da criminalidade e abrange **as áreas da antropologia e da sociologia criminal**. Com o objectivo de estudar o crime e o criminoso, encara os factores genéticos e etiológicos da criminalidade.

O **objecto da moderna criminologia** é o crime, suas circunstâncias, seu autor, sua vítima e o controle social.

Deverá ela orientar a política criminal na prevenção especial e directa dos crimes socialmente relevantes, na intervenção relativa às suas manifestações e aos seus efeitos graves para determinados indivíduos e famílias.

III. OUTRAS CIÊNCIAS DO DIREITO PENAL

1. Vitimológia

A denominada vitimológia foi definida no I *Simpósio Internacional* de *Vitimológia*, celebrado em Jerusalém em 1973, como «o estudo científico das vítimas» não parece que tenha também objecto autónomo; agrupa um conjunto de conhecimentos centrados sobre a vítima dos actos criminosos, desde perspectivas humanitárias orientadas para a sua ajuda (assistência jurídica, moral, terapêutica e económica), ao estudo das suas características (psicológicas, morais, sociais, culturais, etc.), das suas relações com o delinquente e do papel que desempenham na génese do crime[37].

De forma precisa e prática, a vitimológia significa estudo das pessoas que, individual ou colectivamente, sofreram dano, incluindo lesão física ou mental, sofrimento emocional, perda económica ou restrição substancial dos seus direitos fundamentais, através de actos ou omissões que consistem em violação a normas penais, incluindo aquelas que proscrevem abuso de poder.

[37] Germano Marques da Silva, Ob., Cit., p. 187.

2. **Penologia**

A penologia pretende ser a ciência das penas criminais. O Código Penal angolano, como a generalidade dos sistemas penais dos PALOPS, apontam como fim das penas a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade (art. 40.º do CP).

A penologia tem precisamente como objecto - o estudo das penas que devem, ser adoptadas e o modo de execução de cada uma, em ordem à prossecução do fim que devem prosseguir, nomeada e especialmente a reintegração do agente do crime na sociedade.

3. **Sociologia criminal**

A sociologia criminal estuda o crime como fenómeno social. Deve-se o nome a Henrique Ferri.

4. **Antropologia criminal**

Antropologia criminal estuda o homem delinquente, na sua unidade de corpo e espírito. O seu aparecimento deve-se a César Lombroso.

IV. CIÊNCIAS AUXILIARES DO DIREITO PENAL

1. Medicina Legal

A Medicina Legal é a disciplina que estabelece o contacto entre a medicina e o Direito, estudando e aplicando os conhecimentos médicos aos fins práticos do Direito. Uma das suas partes mais importantes no âmbito penal é a **Psiquiatria Forense** que, estuda as doenças e perturbações mentais e suas consequências no domínio do direito, como a perigosidade e imputabilidade. Dupla é a tarefa da psiquiatria, ora, colaborando com o legislador, na definição e solução de problemas do direito, ora, com a Justiça na aplicação do Direito ao caso concreto.

2. Psicologia Judiciária

A Psicologia Judiciária é a psicologia aplicada às pessoas que participam do processo penal - magistrados, advogados, arguido, ofendido, testemunhas, etc., sendo especialmente valiosa na avaliação da prova, nomeadamente para avaliar a credibilidade

do testemunho e da confissão, pela importância que estes meios de prova ainda têm na administração da justiça penal, patenteando-nos a relatividade desses meios probatórios.

3. Criminalística

Criminalística é a designação que se dá à técnica que resulta da aplicação de várias ciências à investigação criminal, na descoberta dos crimes e dos criminosos[38].

4. Ciência Penitenciária

A Ciência penitenciária estuda a administração e direcção das prisões. Não é necessário acentuar a necessária conjugação do direito penal com a ciência penitenciária.

CAPÍTULO IV
FONTE DE DIREITO PENAL

I. Algumas reflexões introdutórias

As fontes do direito são as origens das normas jurídicas. Segundo a doutrina pátria estas subdividem-se em fontes materiais (substanciais ou de produção) e fontes formais (ou de conhecimento).

1. Fontes materiais ou substanciais

Conforme ensina GRANDÃO RAMOS, as fontes matérias são a razão de ser, o fundamento do direito penal e a realidade que o determina[39].

2. Fontes Formais

Na esteira do mesmo autor, as fontes formais são as que, podem definir-se como as formas ou modos de manifestação ou revelação do direito penal. Estas dividem-se em fontes formais imediatas ou directas e fontes formais mediatas ou indirectas[40].

1.1. Fonte formal imediata ou directa

[38] Germano Marques da Silva, cit. Eurico Altavila, *Psicologia Judiciária*, 2 Vols. (Trad. de Fernando de Miranda), 3.ª ed., Coimbra, 1982.

[39] Vasco Grandão Ramos, *Direito Penal, Apontamentos*, 2002, p. 25.

[40] Ibidem

São aquelas que têm força vinculativa própria, sendo portanto, os verdadeiros modos de produção de direito penal. Ex.: lei. (lei do Estado)

1.1.1. A lei (lei do Estado é a única fonte do direito penal[41])

As alíneas b), c) e e) do art. 164.º da CRA de 2010, dispõem que, compete à Assembleia Nacional, legislar com reserva absoluta, sobre as seguintes matérias: regime dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos; restrições e limitações aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e a definição dos crimes, penas e medidas de segurança, bem como as bases do processo criminal.

Dizer que, só Assembleia Nacional pode definir comportamentos humanos tidos como crimes, estabelecer as penas e medidas de segurança, bem como descriminalizar certos comportamentos, significa que para além, da Assembleia Nacional, nem o Executivo ou um outro Órgão do Estado, pode legislar em matéria criminal, por se tratar de uma reserva absoluta da lei. Pode sim, o executivo exercer iniciativa legislativa, mediante propostas de lei apresentada à Assembleia Nacional, nos termos do art. 120.º da CRA de 2010.

1.2. Fonte formal indirecta ou mediata

São aquelas que, embora não têm força vinculativa própria, são importantes pelo modo como influenciam o processo de formação e revelação da norma jurídica. Ex.: costume, jurisprudência, doutrina, usos e os princípios gerais do direito.

1.2.1. Costume

Em virtude do princípio da reserva da lei, o costume está, por consequência, excluído como facto normativo relativamente às normas incriminadoras (*nulla poena sine lege scripta*, art. 1.º CP).

Pode apenas interpretá-las e preencher o conteúdo de conceitos normativos utilizados na lei penal. O art. 7.° n.º 1, do Código Civil dispõe expressamente que, a lei só deixa de vigorar se for revogada por outra lei, pelo que deve entender-se que, o costume também não pode revogar as leis penais. Aliás, como acima já referimos, a descriminalização de comportamentos é da competência ou reservada absoluta da Assembleia da Nacional.

[41] Ao dizer-se que fonte do direito penal é a lei do Estado quer significar-se que apenas a Assembleia da Nacional, têm competência para legislar em matéria penal.

Só é relevante para o direito penal, o costume que concretamente se mostrar mais favorável ao agente.

Conforme havíamos escrito o costume não é fonte do direito penal, porque não pode criar delitos, nem determinar penas muito menos medidas de segurança.

Entretanto, impede o princípio de reserva legal: não há crime sem lei anterior que o defina; não há pena sem prévia cominação legal. A conduta punível, positiva ou negativa, só pode resultar de um modelo legal, nunca de normas consuetudinárias.

Entretanto, o costume não é fonte formal imediata e criadora de Direito Penal. Por mais nocivo que seja um facto ao senso moral da colectividade, será atípico se não estiver definido em lei como crime[42].

1.2.2. Doutrina

A doutrina vale por aquilo que é. A doutrina é fruto do estudo de nossos professores de Direito, juristas, jusfilósofos, estudiosos, operadores jurídicos em geral, traduz-se em obras como: monografias, manuais, compêndios, tratados, pareceres, artigos, ensaios etc.[43]

Todo esse trabalho intelectual que constitui a doutrina, possui um papel impar no universo jurídico do sistema romano-germânico. A doutrina, embora não seja fonte directa do Direito Penal, opina, orienta, critica, interpreta, mostra caminhos ao magistrado, sugere modificações ao legislador, constrói e destrói mitos e dogmas. A opinião maior e no sentido de negar mesmo a doutrina a categoria de fonte do Direito Penal[44].

Na realidade, no nosso sistema, a doutrina forma a base dos conhecimentos jurídicos de nossos profissionais, pois e ela quem os instrui nas escolas de Direito. A doutrina actua directamente sobre as mentes dos operadores jurídicos por meio de construções teóricas que actuam sobre a legislação e a jurisprudência. Somente por meio da obra de estudiosos temos acesso a visão sistemática do Direito. **A simples leitura de textos**

[42] Aiken Renkel Afonso, *Resumo de Direito penal*, 2021, p. 18.

[43] Silvio de Salvo Venosa, *Introdução Ao Estudo do Direito***,** 2.º Ed., Editora Atlas S.A., São Paulo, 2009, p. 135-136.

[44] Ibidem

legais, por si só, assemelha-se a um corpo sem alma, por vezes complexo e inatingível[45].

E na obra dos doutrinadores que se encontram muitos dos caminhos trilhados pelo legislador e pelo juiz. Situações, como negligência grosseira, norma penal em branco, orientações claras sobre a responsabilidade penal da pessoa colectiva, retroactividade da lei mais favorável e muito mais, possuem palpável base em nosso meio antes que fossem lançados a jurisprudência e a lei.

1.2.3. **Jurisprudência**

Como imediata consequência do princípio da reserva de lei a jurisprudência não é fonte formal de direito penal, embora assuma o papel de legislador complementar no domínio da concretização das cláusulas gerais e dos conceitos indeterminados.

Ou seja, sendo a jurisprudência um conjunto de decisões dos tribunais. Tal, como escreve GRANÃO RAMOS, até ao alvorecer da Revolução Francesa, os juízes não se encontravam limitados pelo princípio da legalidade, de modo que podiam classificar arbitrariamente quaisquer factos como crimes e aplicar-lhes as penas que entendessem[46].

1.2.4. Usos

O uso traduz-se como uma prática social reiterada. Não atinge o *status* de costume porque apresenta apenas o aspecto material o *corpus,* faltando-lhe o aspecto subjectivo, o *animus, (*a consciência da obrigatoriedade). Não é fonte de direito penal.

3.3.5**. Princípios gerais do direito**

Conceituar princípios gerais do Direito é tarefa árdua que se espalha em inúmeras teorias, nem sempre conclusivas. A matéria e de ordem filosófica. A enumeração das fontes do direito costuma encerrar-se com a menção a esses princípios.

Cada autor, sob diversas correntes de pensamento, procura dar sua própria posição sobre o tema, para a corrente legalista ou positivista, os princípios gerais de Direito são aqueles norteadores do ordenamento jurídico, extraídos das diversas regras particulares.

[45] Ibidem

[46] Orlando Rodrigues, Ob., Cti., p. 26.

Em momento próprio iremos definir e catalogar esses princípios**.** Por agora cumpri-nos em dizer que também não é fonte de direito penal.

CAPÍTULO V

INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICO-PENAIS

I. Interpretação em direito penal

1. Noção

Interpretar é *inter pretare*, que deriva de *inter press*, corretor, intermediário, mediador. Intérprete é o mediador entre o texto da lei e a realidade do Direito Penal, ao contrário do Direito Civil, o Direito Penal, não nos apresenta a *numerus apertus*, mas sim a *numerus clausus*.

Dito em outro modo, a interpretação consiste na investigação do alcance e do sentido das regras do Direito.

2. Elementos de interpretação

Desde Savigny que, se conhecem os seguintes elementos da interpretação: gramatical, histórico, sistemático e o teleológico.

Conforme o autor acima citado, o aplicador do Direito deveria utilizar-se de todos os elementos, de modo que eles convergiriam para o verdadeiro sentido e o alcance da regra em análise.

O **elemento gramatical** (ou interpretação gramatical) é de todos, o único indispensável, por razões óbvias, já que se refere àquele em que, se verificam semanticamente os vocábulos empregados no texto normativo. Toda actividade interpretativa começa pela interpretação gramatical. Esta, porém, não esgota o processo hermenêutico.

Não se pode jamais, segundo pensamos, olvidar-se do **elemento histórico.** Isto porque toda a regra possui um antecedente histórico que a motiva.

Não há como compreender um instituto jurídico sem situá-lo no tempo e no espaço, de modo a verificar-se em que contexto ele surgiu. As regras e princípios jurídicos não são vazios; pelo contrário, são factos humanos que propulsionam sua criação e, ademais, existem valores por detrás deles.

Todo o complexo de factos e valores que inspiram a norma deve ser levado em conta quando de sua aplicação. Para isto, é fundamental o elemento histórico.

Além do mais, o **elemento sistemático** é de inegável importância. Toda regra, quando ingressa no ordenamento jurídico, deve ser devidamente harmonizado com o sistema que lhe é preexistente. A aplicação de uma regra não pode contradizer outra, igualmente vigente e conforme com a Constituição; é função do intérprete compatibilizá-las, delimitando o espaço de aplicação de cada uma delas – eis a função do elemento sistemático[47].

O elemento teleológico, por derradeiro, talvez seja de todos o mais precioso, porquanto as regras buscam, todas elas, o cumprimento de um **fim**; é isso que se investiga por meio da interpretação teleológica.

3. Relevância da interpretação em matéria jurídico-penal

Em matéria jurídico-penal é proibido a interpretação extensiva, sempre que a mesma vir a incriminar o ou agravar a responsabilidade jurídico-penal do agente. Ou seja, nos termos do artigo 1.º n.º 3, do CP "não é permitido o recurso à interpretação extensiva para qualificar um facto como crime, para definir um estado de perigosidade ou para determinar a pena ou a medida de segurança que lhes correspondem", salvo se for em benefício do agente". Portanto, a interpretação extensiva em direito penal é proibida, em situações *supra* (o inverso é permitido).

II. Analogia

1. Noção

O ideal seria o ordenamento jurídico preencher todos os acontecimentos, todos os factos sociais. É sabido que isto é impossível. Sempre existirão, situações não descritas ou previstas pelo legislador.

Assim, a analogia constitui método de integração do ordenamento jurídico. Trata-se de um mecanismo utilizado para suprir lacunas. Consiste em aplicar a uma hipótese não

[47] Registre-se, ainda, que a **interpretação se classifica quanto à origem**. Nesse ponto fala-se em:

1. **Interpretação autêntica**, quando deriva do legislador, isto é, do órgão de que provém a regra;

2. **Interpretação doutrinária**, quando elaborada pelos escritores de Direito; e

3. **Interpretação judicial**, se decorrente de decisões proferidas pelo Poder Judicial.

prevista em lei a disposição relativa a um caso semelhante. Ou seja, "O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade na lei. No julgamento da lide, caber-lhe-á aplicar as normas legais, não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito." **Só que em direito penal isso não é bem assim.**

Para melhor entendimento ilustra-se o seguinte exemplo: o legislador, através da lei ***A,*** regulou o facto ***B,*** o julgador precisa decidir o facto ***C***, procura e não encontra no direito positivo uma lei adequada a esse facto. Percebe-se, porém, que há pontos de semelhança entre o facto ***B*** (regulado) e o facto ***C*** (não regulado). Então, através da analogia, aplica ao facto ***C*** a lei ***A.***

3. Pressupostos

Para utilizá-la, é preciso que se verifiquem dois pressupostos[48]:

a) Existência de uma lacuna na lei;
b) Encontro no ordenamento jurídico de uma solução legal semelhante, vale dizer, uma regra jurídica que tenha sido estipulada para regular caso análogo.

4. Relevância da analogia em matéria jurídico-penal

Em Direito Penal, o recurso à analogia é admissível em certas circunstâncias e inadmissível noutras.

É possível recorrer à analogia quando:

- ✓ For para afastar ou diminuir a pena;
- ✓ For em benefício do agente;
- ✓ Seja um meio de interpretação.

Não é possível recorrer à analogia nos termos do art. 1.º n.º 3, do CP, quando:

- ✓ Seja para agravar a pena;
- ✓ Se não for em benefício do agente;
- ✓ Seja para integrar uma lacuna num crime legalmente previsto.

[48] André Estefam, *parte geral do direito penal,* vol 7, 2018,

CAPÍTULO VI

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO PENAL

1. Noção

Nas lições do Prof. LISENDER ANDRÉ[49], princípios fundamentais do direito penal e processual penal, seria um enunciado mas abstracto, mas impreciso, que actuaria como elemento de harmonização das normas, cujos efeitos seriam auxiliar na superação interpretativa das lacunas e contradições lógicas existentes no texto legal, orientar o legislador e orientar o julgador, sempre de forma a preservar a ordem normativa, a coerência e a harmonia da lei.

2. Classificação

A classificação dos princípios fundamentais do direito penal faz-se em função de uma combinação entre CP e CRA, como sejam:

2.1. Princípio legalidade

2.1.1. Noção

O princípio da legalidade é o princípio reitor do direito penal e da moderna política criminal, importa consignar que, a legalidade é um dos princípios essenciais do direito penal, garantido pelos artˢ. 2.º e 65.º da CRA de 2010, bem como o art.º 1.º do CP.

Nas lições de PAITA DE CARVALHO, o referido princípio dispõe de um fundamento jurídico-político, efectivamente a matriz desse princípio foi e continua ser, a de garantia do cidadão frente ao poder punitivo do Estado. Neste sentido, é correta e adequada a frase com que Franz Von Liszt, em final do Séc. XIX, cunhou o princípio da legalidade como: ‘’***magna charta* de delinquente’’.** Pois que, ao exigir-se uma lei escrita, certa, estrita e prévia ao facto, o infractor está protegido contra intervenções punitivas arbitrárias[50].

[49] Lisender André, Professor de Direito Processual Penal e Processual Civil II e III, UMN-Lubango.

[50] Américo Paita de Carvalho, direito penal parte geral-cimbra editora-2.º edição-pp.154-155-2011

2.1.2. Postulados

Importa transmitir que, o referido princípio apresenta os seguintes postulados:

a) A exigência da lei em sentido formal ou proibição do custume- *nullum crimen sine lege scripta*[51]*;*

b) A exigência de determinabilidade ou tipicidade – *nullum crimen sine lege certa*[52]*;*

c) A proibição de aplicação de analogia – *nullum crimen sine lege stricta*[53]*;*

d) A proibição da retroactividade da lei penal desfavorável - *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*[54].

2.2. Princípio proporcionalidade

O princípio proporcionalidade em sentido amplo está previsto nos arts. 57.º n.º 1, 58.º n.º 3 e 4, 198.º, n.º 1 e 205.º todos da CRA de 2010[55]. A proporcionalidade constitui um importante princípio moderador em direito penal, assentes nas noções básicas de racionalidade, liberdade de expressão, julgamento justo, direitos do arguido, segurança pública, eficiência e exclusão de arbítrios.

[51] O nosso direito é constitucionalmente dominado pelo princípio (***nullum crimen sine lege scripta***), tal resulta do n.º 2.º do artigo 65.º da CRA, ‘’ Ninguém pode ser condenado por crime senão em virtude de lei anterior que declare punível a acção ou a omissão, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados por lei anterior.

[52] A lei penal deve ser *determinada* em seu conteúdo, não se permite a construção de tipos penais excessivamente genéricos, os quais são denominados tipos penais vagos, ou seja exige-se o legislador penal de que a criação deve ser precisa e clara.

[53] Entende-se que a aplicação da analogia significaria o exercício do poder legislativo pelo juiz, a criação de uma lei nova, operação que é incompatível com o princípio da legalidade, pois a analogia, segundo Santos Justos, refere a um raciocínio ou operação mental que, partindo de certas semelhanças observadas, conclui-se que existem outras. Ou seja funda-se na semelhança entre dois objectos.

[54] Esta é uma matéria, exclusivamente da aplicação da lei penal no tempo, tem uma multiplicidade de questões a tratar, consideramos mais adequado dedicar-lhe em capítulo próprio.

[55] Jónatas E. M .Machado; Paulo N. Costa e Esteves. C. Hilario – *direito constitucional angolano* – 2º edição – Coimbra editora – 2013 pp. 81-82.

Por outras palavras, a proporcionalidade em sentido amplo, preconiza o justo equilíbrio entre os interesses em conflito, obrigando o legislador, os juízes e demais operadores do direito a ponderar os interesses em conflito para, em função dos valores subjacentes e os fins prosseguidos os resolver segundo medida adequado. Este divide-se em três subprincípios a saber:

2.2.1. Princípio da proporcionalidade em sentido estrito

O princípio da proporcionalidade, em sentido restrito, significa que os meios legais restritivos da liberdade e os fins obtidos devem situar-se numa justa medida, determinada pela gravidade do mal causado e censurabilidade do seu autor[56].

2.2.2. Princípio da subsidiariedade ou da intervenção mínima

O princípio da subsidiariedade, que se concretiza no princípio da intervenção mínima, significa que as normas incriminadoras e as sanções devem revelar-se necessárias, porque os fins prosseguidos pela lei penal, só podem ser obtidos sempre que os outros ramos do direito se mostrarem insuficiente ou inadequados.

2.2.3. Princípio da adequação ou adequação social

O princípio da adequação ou adequação social significa que, as normas incriminadoras e as sanções penais legalmente previstas devem revelar-se adequadas para a prossecução dos fins visados pela lei.

2.3. Princípio responsabilidade penal individual

Nos termos do art. 65.º n.º 1, da CRA de 2010 e do art. 41.º n.º 3, do CP, estabelecem que, trata-se de um princípio em virtude do qual, somente incorre em responsabilidade criminal, quem tiver cometido um delito. Ou seja, deve ser ao indivíduo, e somente a ele, que se deve responsabilizar pelo que tenha feito. Sendo imperativo combater resolutamente qualquer implicação extensiva aos seus familiares, parentes e amigos ou a outras pessoas inocentes que, embora tenham algumas ligações com o infractor, foram alheios à acção delituosa.

[56] Citando-Cf. J. J. Gomes Canotilho / Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 4.ª ed., 2007, p. 392. Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2." ed., 2010, p. 372 ss.

2.4. Princípio da insignificância e bem de valor diminuto

Para efeitos de reconhecimento, não se pode confundir os conceitos de bem de valor diminuto, com bem de valor insignificante.

O Valor Diminuto é aquele que não exceda metade do salário mensal mais baixo da função pública, no momento em que o facto for praticado (391.º CP), significa dizer quem furtar ou roubar o bem avaliado em 20.000,00kz, pode incorrer em uma moldura penal abstracta de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias, se o valor da coisa subtraída não for elevado.

Já o princípio da insignificância tem sido adoptado pela nossa jurisprudência nos casos de furto de objecto material insignificante, lesão insignificante ao Fisco, maus tratos de importância mínima, descaminho e dano de pequena monta, lesão corporal de extrema singeleza, roubo de uma galinha, furto de um pente ou agulha e etc.

Segundo a jurisprudência nos exemplos expostos, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a incriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.

O princípio da insignificância está ligado aos chamados “crimes de bagatela” (ou “delitos de lesão mínima”), este princípio recomenda que o Direito Penal, pela adequação típica, somente intervenha nos casos de lesão jurídica de certa gravidade, reconhecendo a atipicidade do facto nas hipóteses de perturbações jurídicas mais leves (pequeníssima relevância material).

2.5. Princípio da fragmentariedade

É consequência dos princípios da reserva legal e da intervenção necessária (mínima). O Direito Penal não pode proteger todos os bens jurídicos de violações: só os mais importantes. E, dentre estes, não os tutela de todas as lesões: intervém somente nos casos de maior gravidade, protegendo um fragmento dos interesses jurídicos, por isso é fragmentário.

2.6. Princípio culpabilidade

A culpa pressupõe a consciência ética, isto é, a capacidade prática da pessoa de dominar e dirigir os próprios impulsos psíquicos e de ser motivado por valores e a liberdade de agir em conformidade, sem admissão das quais, não se respeita a pessoa nem se entende o seu direito à liberdade.

Segundo o relatório de fundamentação do código penal, o ordenamento jurídico-penal angolano, tem matriz assente na culpa[57], partindo da compreensão de que, toda a pena tem de ter como suporte ideológico-normativo uma culpa concreta», isto é, um direito penal assente no princípio «*nulla poena sine culpa*», com o sentido de que a culpa é o limite da responsabilidade penal e da pena, sem subalternizar as finalidades de prevenção e, em particular, as atinentes à recuperação e reinserção social do delinquente[58].

Este princípio é um dos que deriva da própria Constituição nos termos do art. 65.º n.º 4, da CRA de 2010, bem como o art. e 42.º n.º 1, do CP. No entanto, o mesmo apresenta alguns problemas:

Quanto ao seu significado – o termo culpa é frequentemente usado em dois sentidos:

a) Não possibilidade de em direito penal haver responsabilidade objectiva (art. 8.º do CP);
b) Intenção criminosa ou culpa – que respeita ao fundamento subjectivo que, a responsabilidade criminal tem sempre de ter, sendo, por isso sinónimo de dolo ou negligência (art. 12.º e 13.º do CP).

Quer isto dizer que um dos possíveis sentidos de culpa é não haver responsabilidade objectiva, ou seja, para que seja responsável à pessoa tem de ter, uma falta subjectiva (intenção de fazer algo ou descuido ao fazer algo) em princípio lícita. Neste sentido devemos usar a terminologia "princípio da responsabilidade subjectiva" e deixar de lado a terminologia "princípio da culpa".

[57] Nestes termos conclui-se que:
Não deve haver responsabilidade objectiva no direito penal;
➢ As pessoas não devem ser responsabilizadas criminalmente se forem inimputáveis;
➢ É necessário dolo ou negligencia para que uma pessoa seja criminalmente responsabilizada;
➢ É também preciso que essa pessoa tenha agido com a suficiente liberdade para que possa ser censurada ou para valer a pena puni-la.
[58] Relatório de fundamentação do código penal.

Outro sentido, mais restrito, do termo é que não pode ter responsabilidade criminal quem não tiver liberdade de entendimento e de decisão. Isto é: os inimputáveis, em princípio, não são responsáveis criminalmente (não são censuráveis porque não sabem o que fazem ou não adianta puni-las porque isso não tem impactos sociais e seria considerado injusto).

2.7. Princípio humanidade

Princípio humanidade assenta na ideia, em os Estados elevarem os seres humanos, como seu fim último de actuação, "fonte de imputação de todos os valores, consciência e vivência de si próprio" (art. 1.º CRA de 2010).

Daí advém que, o ser humano diversamente de outros seres vivos, torna-se objecto de respeito, não por sua animalidade, mas em decorrência de sua humanidade, que se reflecte em sua personalidade única. Tal como avança o Prof. RAUL ARAÚJO, este basilar princípio impõe o reconhecimento a todas as entidades públicas e privadas de que o valor da pessoa humana prevalece sobre todos os demais (art. 28.º da CRA de 2010). O Estado está vinculado, por um lado, a obrigatoriedade de tomar a medidas atinentes a defesa e protecção da dignidade da pessoa humana, contra todos aqueles que possam por em causa. Por outro lado, o Estado tem o dever de não agir sempre que possa afectar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.[59] Neste caso o princípio da humanidade busca o seu significado histórico, como proibição da pena de morte, prisão perpétua, proibição de torturas e tratamentos degradantes e desumanos.

2.8. Princípio da representação ou da bandeira

Trata-se de um princípio subsidiário, quando houver deficiência legislativa ou desinteresse de quem deveria reprimir, aplica-se a lei do Estado em que, está registada a embarcação ou a aeronave ou cuja, bandeira ostenta aos delitos praticados em seu interior.

[59] Raul Carlos Vasques Araújo-introdução ao direito constitucional angolano-2 edição- editora CEDP/UAN-pp.114-2018.

CAPÍTULO VII

FUNÇÃO DO DIREITO PENAL

SECÇÃO I

FINS DO DIREITO PENAL E DAS SANÇÕES PENAIS

SECÇÃO II

FINS DO DIREITO PENAL

I. Algumas reflexões introdutórias

A definição da função do Direito Penal é um problema antigo, ainda não de todo solucionado. Entretanto, há, modernamente, unanimidade doutrinária no sentido de ser o papel deste ramo do Direito a protecção de bens jurídicos, a que se chegou após uma longa e lenta evolução desta temática, que iniciou no período do Iluminismo, quando o conteúdo material do delito era localizado na lesão ou exposição a perigo de direitos subjectivos; no início do século XIX, o crime passou a ser visto como a lesão ou exposição a perigo de bens jurídicos, sendo que, numa fase inicial somente bens materiais ou corpóreos poderiam ser objecto de tutela penal, concepção de autoria de BIRNBAUN, que pretendia limitar o âmbito de incidência das normas penais incriminadoras. Já no final do século XIX, com BINDING e LIZST, o bem jurídico passa a ser identificado com bens vitais da comunidade ou do indivíduo que, por sua importância, são protegidos juridicamente. E tido como fins do direito penal.

A nível da doutrina os autores, frequentemente se referem aos fins das penas e das medidas de segurança criminais, do que aos fins do direito penal. No presente segmento cuidaremos sumariamente em discutir os fins do direito penal e posteriormente os fins das penas e das medidas de segurança criminais.

Conforme ensina o Prof. GERMANO M. SILVA, para analisarmos os fins do direito penal, é necessário saber: **para que serve o direito penal? A razão por que a doutrina mais frequentemente trata dos fins das sanções do que dos fins do direito penal?** Tal percepção, parece resultar do entendimento de que este ramo do direito não tem fins que no essencial o distingam de todos os demais: neste sentido, o fim do Direito seria uno. O que haveria de específico no direito penal seria a própria especificidade das sanções, das penas e das medidas de segurança criminais, pela sua

natureza aflitiva, e o que ao jurista importaria seria a legitimação do mal em que a sanção consiste e a sua adequação ao comportamento penalmente pressuposto[60].

1. Fins do direito penal

O autor acima citado entende que, a análise dos fins do direito penal pode equacionar-se em três perspectivas: **a do ser**, **a do dever ser expresso pelo direito positivo e a do dever ser sem limitação a qualquer direito positivo.**

a) A do ser

O **ser** é objecto de análises empíricas sobre as funções sociais do direito penal, sendo, pois, do âmbito das ciências sociais (sociologia, psicologia, etc.), que analisam as funções que o direito penal realmente cumpre em uma determinada sociedade.

b) A do dever ser expresso pelo direito positivo

O dever ser expresso pelo direito positivo, pretende descobrir quais são os fins que, em concreto direito penal positivo se propõe.

c) A do dever ser sem limitação a qualquer direito positivo

Nesta categoria busca-se construir uma teoria legitimadora do direito penal num contexto histórico, político e social determinado; procura-se agora uma base crítica para analisar as soluções do direito positivo.

2. Distinção entre fins do direito penal e fins das penas

JOSÉ BELEZA DOS SANTOS, citado por GERMANO M. SILVA é de opinião que, os objectivos e os fins do Direito em geral, e do direito penal em especial, não se confundem com os fins imediatos das sanções aplicáveis como consequência da violação das normas. As sanções são instrumentais relativamente aos fins do Direito, servem para reforçar a imperatividade das normas e estas têm por finalidade ordenar a vida social conforme à Justiça ou, pelo menos, com pretensão de Justiça[61].

[60] Germano Marques da Silva, Ob., Cit., p. 55.

[61] José Beleza dos Santos, *Ensaio sobre a introdução ao direito criminal*, p.118: cit. por Germano M. Silva – 56.

3. Diversidade dos fins do direito penal

Ainda sobre o Prof. GERMANO M. SILVA considera que, a legitimação do direito penal resulta essencialmente da conjugação de duas grandes categorias de fins específicos que deve prosseguir, como sejam: fins utilitaristas e fins garantísticos

Ambos naturalmente ordenados e subordinados a essa finalidade última de todo o Direito que é a da ordenação da vida social conforme à Justiça.

a) Fins utilitaristas

A consagração teórica do utilitarismo como concepção legitimadora do direito penal é fruto do movimento iluminista e tem dominado desde então o desenvolvimento teórico do direito penal; assenta essencialmente na ideia da prevenção geral.

b) Fins garantísticos

A mesma corrente de pensamento entronca, também a denominada função garantística do direito penal, de defesa da pessoa, primeiro formal e depois material, contra os abusos do poder punitivo do Estado e a violência dos demais. São estes fins, conjugadamente utilitaristas e garantísticos, que essencialmente legitimam o direito penal moderno[62].

3.1. O fim da redução da violência estatal na perspectiva utilitarista

As incriminações, porque limitadoras da liberdade dos cidadãos, e as penas, porque se traduzem em sofrimento infligido aos delinquentes, devem limitar-se ao mínimo[63]-

[62] ibidem

[63] Este princípio, o da intervenção mínima, admitido como princípio geral pela doutrina, exprime a ideia de que o direito penal há-de reduzir a sua intervenção só aos casos em que seja absolutamente necessária em termos de utilidade social geral. Se, como é manifesto, o direito penal comporta sempre um mal, não pode ser admitido senão nos casos em que seja imprescindível para cumprir os fins de protecção social através da incriminação de factos lesivos de bens jurídicos especialmente relevantes para a vida em sociedade. A referida ideia, que responde ao critério de que a pena criminal só é admissível quando não haja outro mal menor que cumpra a mesma finalidade, tem duas manifestações: externa, uma, segundo a qual deve prescindir-se da incriminação sempre que seja possível esperar similares efeitos preventivos da intervenção de meios menos lesivos, nomeadamente através de ramos de direito de outra natureza, interna, outra, segundo a qual deve prescindir-se de uma sanção penal mais grave e sempre que possa esperar-se similar efeito preventivo de outra sanção penal menos gravosa.

indispensável para a realização dos seus fins, até porque além, do mal que directamente representam, têm também na maioria das vezes custos, não só para os delinquentes, mas também para as suas famílias, as mais das vezes inocentes, e sempre e não despiciendos, custos para a própria sociedade.

3.2. O fim da redução da violência estatal na perspectiva garantístico-individual

Seguindo novamente a doutrina do Prof. GERMANO M. DA SILVA, a prevenção não se limita a si mesma. A introdução de critérios limitadores da prevenção é uma questão cultural, de modelo do Estado, e foi-o inicialmente pelo Estado liberal de direito. Ora, esses limites ao *jus puniendi*, em defesa das pessoas em face do poder punitivo do Estado, assumem-se também como verdadeiros fins do direito penal[64].

3.3. O fim da protecção de bens jurídicos e da protecção da vítima

O direito penal tem um objectivo prático e socialmente útil: proteger aqueles bens ou interesses de cuja tutela depende a garantia de uma convivência pacífica, os bens essenciais para uma ordenada convivência humana.

A tutela penal de bens ou interesses de importância secundária seria desproporcionada, por excessiva, tendo em conta a gravidade das sanções penais, e, por isso, a tutela jurídica desses bens deveria ser feita por meios extrapenais.

Ainda nos lindes da doutrina portuguesa, o acento posto na protecção de bens jurídicos como função exclusiva do direito penal fez olvidar a vítima do crime. Ao menos em certa medida como que se despersonalizou a agressão criminal para considerá-la apenas na perspectiva da lesão de valores de conteúdo abstracto - os bens jurídicos - cuja protecção cabe ao Estado. Durante muito tempo a vítima permaneceu quase ignorada.

Com o nascimento no pós-guerra da vitimológia, as atenções da doutrina, que antes se ocupava fundamentalmente do agente do facto criminoso, passou também a prestar atenção às vítimas, primeiro na perspectiva das causas do crime, em que a vítima pode ter também um lugar de relevo, depois com a preocupação de atender às suas necessidades e de proteger os seus interesses.

[64] Germano Marques da Silva, Ob., Cit., pp 65 a 67.

II. TEORIA DO BEM JURÍDICO-PENAL

1. Algumas reflexões introdutórias

Ainda sobre a função do direito penal em último plano, compre-nos sinteticamente descrever a teoria do bem jurídico-penal.

A ideia de protecção de bens jurídicos como função do direito penal é retomada na Alemanha a partir dos anos cinquenta[65]. Por sua vez a pena criminal sacrifica bens pessoas constitucionalmente protegidos **nomeadamente a liberdade**.

Ora, tendo em conta o carácter gravoso dos direitos fundamentais (liberdade), a definição e a compreensão da noção de bem jurídico-penal é uma das formas mais consistentes de analisar o Direito Penal. Desse modo, a noção de bem jurídico-penal deve obedecer rigorosamente algumas concepções e âmbitos da ordenação axiológica jurídico-constitucional[66].

Tais concepções encontram-se intrinsecamente ligadas a evolução histórica do direito penal, conforme foi analisado minuciosamente no capítulo III sob tema: ciência conjunta do direito penal (enciclopédica do direito penal), concretamente nas fases históricas do direito penal.

2. Concepções de bem jurídico-penal

A teoria do bem jurídico-penal é aprendida com base as seguintes concepções: concepção positivistas-legalista, concepção jusnaturalista, concepção moralista, concepção sistémico funcional, concepção ético-social e a concepção jurídico-constitucional.

2.1. Concepção positivistas-legalista

A ideia de bem jurídico-penal surgiu com a filosofia penal iluminista, o Direito Penal era produzido de forma anárquica e as definições do delito, feitas de forma indeterminada. Assim, bem jurídico-penal, seria todo e qualquer interesse que o legislador decide atribuir protecção penal.

[65] Germano Marques da Silva pag.40-41

[66] Paita de Carvalho pag. 45

2.2. Concepção jusnaturalista

A concepção jusnaturalista reconduziria o universo dos bem jurídicos-penais a um pré-existente conjunto de valores imutáveis e como que transcendentes a realidade da história humana.

2.3. Concepção moralista

Segundo concepção moralista, bem-jurídico penal seria todos aqueles valores impostos pela moral religiosa.

Em épocas em que Estado era obra divina e divino os seus representantes. Tal concepção tinha razão de ser, com o advento do iluminismo (séc. XVIII), a religião foi substituída pela razão e, como consequência, a própria organização social passou a decorrer de actos humanos e racionais.

Nas palavras de PAITA DE CARVALHO ‘’a partir do momento histórico em que autonomizaram e separaram a cidade de Deus e a Cidade dos Homens, mal irá, a religião que pretenda intervir-se no braço secular do Estado, para impor aos seus membros da sociedade e a partir do momento histórico da consagração do Estado de direito democrático e plural, mal irá o Estado, que tentar impor aos seus cidadãos, um quadro de valores inspirados numa determinada condição religiosa’’.

Ao nosso ver, tal, concepção também não é aceite pelos limites impostos pela Constituição da República de Angola de 2010, nomeadamente nos artigos 10.º e 41.º.

2.4. Concepção sistémico funcional

Segundo esta perspectiva à principal função do direito penal é a de garantir a funcionalidade do sistema social.

Inicialmente perfilhamos, esta posição, na medida em que o Direito penal, tem a finalidade de tutelar os interesses da vida humana, pois a protecção de interesses é a essência do direito, a ideia finalística, a força que o produz.

Porém, e por força do princípio da subsidiariedade, não é nem seria a concepção sistémico funcional o critério eleito para definir os bens jurídicos penais.

Concepção, esta que, não é compatível com funcionalidade do sistema penal. Ou seja, o Direito Penal ao intervir, só deve emprestar a sua tutela a determinados bens de agressões humanas, quando essa tutela não puder ser eficazmente dada através de outros quadros sancionatórios existentes no ordenamento jurídico.

2.5. Concepções ético-social

Esta concepção entende que, só deverão ser assumidos e qualificados como bens jurídicos penais os valores considerados pelo *ethos* social comunitário, como essências ou indispensáveis para a realização pessoal de cada um dos membros da sociedade.

A referida concepção também não colhe. O facto de um valor ser ético-socialmente relevante, isto não, quer dizer que, o mesmo valor será penalmente relevante, ou seja, a ideia de bem jurídico-penal, remete-nos ao princípio da ofensividade dos delitos como condição necessária da justificação do *jus puniendi*.

2.6. Concepção jurídico-constitucional

O direito penal português, elege o critério jurídico-constitucional como sendo o que melhor se enquadra no actual Estado Democrático de Direito, para definir bem jurídico-penal, sendo os demais bastante vagos e difusos. Procedendo o nosso direito deste, seguimos naturalmente a mesma posição.

Chegados aqui, levanta-se algumas questões como: **o bem jurídico é um bem do direito ou da ordem jurídica? Porque que o conceito bem jurídico tem de ser extraído na constituição?**

Quanto a primeira questão compreende-se facilmente que, o bem Jurídico não é um bem do direito ou da ordem jurídica, ao contrário é um bem do homem que o direito reconhece e protege. Entretanto, não é qualquer direito do homem que pode ser visto ou considerado como bem jurídico-penal, somente aqueles que o direito reconheço e protege, isto para dizer que, pode haver violações de outros valores eticamente relevantes para o homem, mais para o direito penal em particular, será como se fosse uma não violação ou um não assunto, não se pode dizer que, há violação de um bem jurídico, se este bem não preencher os elementos constitutivos de crimes ou contravenções.

Quanto a segunda questão, a mesma encontra fundamento nos artigos 27.º e 57.º da CRA de 2010, tais artigos, estabelecem os pressupostos da qualidade legal de um bem como bem jurídico-penal.

2.7. Noção de bem jurídico-penal

A noção que hoje existe ainda não é totalmente exacta.

O primeiro autor que deu a noção de bem jurídico foi BIRNBAUM (1834), definiu bem jurídico como interesses primordiais do indivíduo na sociedade. Por ex.: a vida, o corpo, a liberdade e o património.

Posteriormente surgem HONIG (1930) e EDUARDO CORREIA autores que, defenderam o conceito metodológico de bem jurídico de raiz normativista, definindo um bem jurídico, como uma forma abreviada de exprimir o sentido e a finalidade de um preceito legal. Ou seja, bem jurídico era a expressão sintética do espírito da lei.

Este conceito não serve porque nem sempre o fim da norma coincide com o bem jurídico protegido (ex.: no crime de burla o bem jurídico protegido é a propriedade, mas a finalidade da norma é impedir o enriquecimento de alguém que burla).

Face a esta crítica, surgem duas noções de bem jurídico:

1. JAKOBS e STRATENWERTH: de acordo com esta parte da doutrina deve-se ir buscar ao sistema social de uma comunidade a fonte legitimadora e produtora da ordem legal dos bens jurídicos existentes. Esta noção pode ter as mesmas críticas que concepção positivista sociológica, pela dificuldade de precisão do conceito, mais uma vez, iremos buscar o conceito à ordem social.

2. ROXIN e FIGUEIREDO DIAS: concordam com a doutrina anterior de que é no sistema social que se deve procurar bem jurídico, mas não basta, esses bens do sistema social têm de se transformar em bens dignos de tutela penal, isso faz-se através da ordem jurídico-constitucional. Para um bem jurídico ser jurídico-penalmente relevante é necessário que tenha uma referência expressa ou implícita na ordem jurídica constitucional dos direitos fundamentais. O bem jurídico tem que ser redutível da Constituição. Esta conclusão tem apoio na nossa na Constituição da República de 2010,

nos artigos. 6.º n.º 2 e o art. 57.º n. 1. O art. 6.º n.º 2, determina que toda a actividade do legislador está subordinada à Constituição. É esta que nos estabelece o quadro fundamental. Descreve o artigo 57.º n. 1, que "a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário, proporcional e razoável numa sociedade livre e democrática, para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos".

TAIPA DE CARVALHO define como bem – jurídicos os interesses ou valores apreendidos pela consciência ético-social, como fundamentais à convivência comunitária, na qual se realiza a pessoa humana.

GERMANO M. DA SILVA defende que, a ideia de serem as Constituições a definirem o quadro normativo dos valores a proteger pelo direito penal começa a ser questionada, por ser limitativa e logo insuficiente perante as exigências da comunidade e dessa forma se põe em causa a limitação do poder punitivo que se buscava na ideia de bem jurídico.

Não obstante e essa pequena controversa, há na doutrina um certo consenso em torno do núcleo central do conceito do bem jurídico-penal que, permite defini-lo como "a expressão de um valor ou interesse, da pessoa ou da comunidade, na conservação ou integridade de um certo Estado, objecto ou bem em si, mesmo socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso".

SECÇÃO III

FINS DAS PENAS

1. Noção de pena

A pena é estudada de modo fragmentário por várias disciplinas jurídicas. Em matéria jurídico-penal, ela é vista como uma sanção aflitiva imposta pelo Estado, mediante acção penal, ao autor de uma infracção (penal), como retribuição de seu acto ilícito, firme na diminuição de um bem jurídico e cujo fim é evitar novos delitos[67].

[67] Soler, *Derecho penal argentino,* v. 2, Buenos Aires, 1970, p. 342. Na edição de 1978 Soler alterou seu conceito de pena: "pena es un mal amenazado primero, y luego impuesto al violador de un precepto legal, como retribución, consistente en la disminución de un bien jurídico, y cuyo fin es evitar los delitos"

Para nós pena é a privação total ou parcial de um bem jurídico imposta pelo Estado, por meio da acção penal, ao criminoso como retribuição ao delito perpetrado.

2. O problema dos fins das penas

Nas palavras do Prof. F. DIAS "a questão dos fins das penas constitui a questão do destino do direito penal e do seu paradigma[68]". A essa questão o Prof. GRANDÃO RAMOS designou de fins mediatos ou últimos das penas[69]. Entendemos nós que não é tecnicamente correcta a expressão fins mediados e imediatos das penas, tal como prefere o citado autor.

Assim, os fins das penas podem, ser atados na retribuição, na prevenção geral e na prevenção especial, agrupadas dentro das chamadas teorias absolutas, relativas e mistas ou eclécticas.

2.1. Teorias absolutas: pena como instrumento de retribuição

Para esta teoria o fim das penas reside na retribuição, expiação, reparação ou compensação do mal do crime e nessa essência se esgota.

Dito de outro modo, a retribuição traduz-se no castigo imposto por uma razão de justiça ou por razões lógicas, dialécticas, morais, estéticas, religiosas e etc.

Para Kant, adepto dessa teoria, mesmo se uma sociedade voluntariamente se dissolvesse, ainda assim, o último assassino deveria ser punido, a fim de que, cada um recebesse a retribuição que exige sua conduta. Nota-se, então, que a base das teorias absolutas encontra-se no passado, que demanda reparação. Ou seja, pune-se porque se pecou (*punir quia peccatum est).*

Portanto, a teoria absoluta como fins das penas deve ser recusada. Porque ela não é verdadeiramente não quer ser, nem pode ser, uma teoria dos fins das penas, pois ela visa justamente o contraio ao princípio da culpa como a máxima de todo o direito penal humano democrático e civilizado. Outrossim, encontra-se afastado por força do art. 40.º da CP, por falta de harmonia.

[68] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit., p.44.

[69] Orlando Rodrigues, Ob., Cit., p. 16.

2.2. Teorias relativas: pena como instrumentos de prevenção

Os adeptos desta teoria reconhecem também, que a pena se traduz num mal para quem sofre, mas como instrumento político-criminal destinado actuar no mundo, não pode a pena bastar-se com essas características, nem si mesma destituída de sentido social positivo[70].

As teorias relativas ou da prevenção subdivide-se em de prevenção geral e prevenção especial.

2.2.1. Classificação pena como instrumentos de prevenção

2.2.1.1. Prevenção geral

A prevenção geral radica na concepção da pena como um instrumento político-criminal destinado actuar sobre a generalidade dos membros da comunidade, afastando-os da prática de crimes, através da ameaça penal estatuída pela lei, da realidade da sua aplicação e da efectivação da sua execução[71].

Esta por conseguinte divide-se em prevenção geral negativa e prevenção geral positiva.

a) Prevenção geral negativa

Prevenção geral negativa - dá-se nas situações em que, a pena é acolhida como forma de intimidação das outras pessoas através do sofrimento que ela se inflige ao delinquente e cujo receio as conduzirá a não cometerem factos puníveis. Ou seja, o delinquente é instrumentalizado na conspecção de uma inquebrantabilidade da ordem jurídica.

b) Prevenção geral positiva

Prevenção geral positiva - consiste na forma em que o Estado, se serve para manter e reforçar a confiança da comunidade na validade e na força de vigência das suas normas de tutela jurídico-penal.

[70] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit., pp. 49-50.

[71] Ibidem

2.2.2.2. Prevenção especial ou individual

Os causídicos desta teoria, partem da ideia que o fim das penas, assentam sobre o próprio criminoso, segregando-o ou neutralizando-o, isto é, afastando-o do convívio - social, intimidando-o para que não volte a delinquir, ou reeducando-o e corrigindo-o, recuperando como um ser social, através de um processo de ressocialização. Esta por seu turno divide-se em: **prevenção especial negativa ou neutralização e prevenção especial positiva ou socialização.**

a) Prevenção especial negativa ou neutralização

Prevenção especial negativa ou neutralização consiste em alcançar um efeito de pura defesa social através da separação ou segregação do delinquente, assim procurando atingir-se a neutralização da sua perigosidade social.

b) Prevenção especial positiva ou socialização

Prevenção especial positiva ou socialização consiste em criar condições necessárias para que o delinquente possa, no futuro continuar a viver a sua vida sem cometer crimes. Ou seja, esta doutrina consiste na reinserção social, ressocialização e socialização do delinquente na sociedade, pode se tratar de alguém que sempre esteve dessocializado. (art. 40.º CP).

2.1.2. A concertação agente vitima e a reparação dos danos

A sanção civil é essencialmente um remédio, ainda que possa secundariamente exercer uma função de repressão e de prevenção, enquanto a sanção criminal é sobretudo um castigo, pois já nada remedeia, e tem por função principal a prevenção de futura criminalidade[72].

Sucede, que o facto criminoso pode causar e causa geralmente, danos patrimoniais e morais ao ofendido e a pena criminal não é adequada a reparar estes danos.

[72] Germano Marques da Silva; *Direito Penal Português* – Vol. 1, Introdução e Teoria da Lei Penal, Ed. 3.º, Verbo Editora, Coimbra (2018), p. 146-149.

Foi por essa razão que o art. 140.º do CP veio estabelecer a indemnização ao ofendido pelos prejuízos que o crime lhe causou.

O n.º 1 do artigo 141.º do CP, vai mais longe ao determinar a necessidade de o Estado fixar em legislação especial as condições em que se poderá assegurar a indemnização devida em consequência da prática de actos criminalmente tipificados, sempre que não puder ser satisfeita pelo agente.

Este preceito é, entre outros, uma clara manifestação da forma inovadora e consequente como a vítima começa a ser encarada pela moderna política criminal. Ou seja, como um sujeito da relação jurídica punitiva, com dignidade até agora só concedida ao agente do crime e ao titular do poder de punir (Estado).

De harmonia com o n.º 2, do mesmo artigo, nos casos não cobertos por tal, legislação especial, o tribunal pode (e deve) atribuir ao lesado, até ao limite do dano, os objectos, valores e vantagens provenientes do crime (correspondentes aos "*instrumenta sceleris"*, "*producta sceleris*" e "*fructi sceleris"*) transferidos para a titularidade do Estado, bastando ao lesado requerê-lo[73].

O n.º 3, do referido artigo, descreve que, não sendo a mesma legislação aplicável, se o dano provocado pelo crime for de tal modo grave que o lesado fique privado dos meios de subsistência, deve o tribunal atribuir-lhe, no todo ou em parte, até ao limite do dano, o montante da multa paga pelo condenado, desde que seja de prever que este não repare os prejuízos que causou e desde que o lesado o requeira. O Estado ficará, em tal caso, naturalmente sub-rogado no direito do lesado à indemnização, conforme consta no n.º 4, do mesmo artigo.

2.3. Teorias mistas ou unificadoras[74]

[73] Relatório de fundamentação do Código Penal

[74] Fala-se por outro da lado, das finalidades e limites das penas criminais – onde analisaremos sumariamente **o ponte de partida: as exigências da prevenção geral positiva ou de integração** – a finalidade visada pela pena há-de ser a da tutela necessária dos bens jurídico-penais caso concreto. Por outra o **ponto de chegada as exigências da prevenção especial nomeadamente da prevenção especial positiva ou da socialização** – dentro da moldura ou dos limites consentidos pela prevenção geral positiva ou de integração- entre o ponto óptimo e o ponto ainda comunitariamente suportável de medida da tutela dos bens jurídicos. Devem actuar, em toda a medida possível, pontos de vista de prevenção especial, sendo assim eles que vão determinar, em última instancia, a medida da pena. isso significa que releva

A maioria das doutrinas sobre os fins das penas radica em tentativas, as mais variadas, de combinar, sob diversos pontos de vista, algumas ou todas as doutrinas que atrás ficam referenciadas.

2.3.1. Teoria em que reentra ainda a ideia da retribuição

Poderá esta, ser definida como o de uma pena retributiva no seio da qual procura dar-se realização a pontos de vista de prevenção, geral e especial, ou diferente no que toca a hierarquização das perspectivas integrantes, para todavia, se exprimir no fundo a mesma ideia como o de uma pena preventiva através de justa retribuição[75]

2.3.2. Teorias da prevenção integral

O ponto de partida é o de que a combinação ou unificação das finalidades da pena só pode ocorrer a nível de prevenção, geral e especial, com exclusão de qualquer ressonância retributiva, expiatória ou compensatória. Esta concepção deve ser globalmente recusada. É denominador comum de todas as doutrinas a recusa do pensamento da culpa e do seu princípio como limite do problema: ou porque procuram substitui-lo pela categoria da perigosidade ou, como modernamente sucede, com frequência, pelo princípio jurídico-constitucional da proporcionalidade, o por uma manipulação da ideia de culpa como meio derivado da prevenção.

Teoria unificadora preventiva – Roxin e as três fases do funcionamento do Direito Penal

O melhor penalista mundial, defende a teoria unificadora preventiva, denominando-a como teoria unificadora dialéctica. A ideia principal subjacente é a prevenção.

Roxin começa por fazer uma crítica mais ou menos pormenorizada das três doutrinas e chega à conclusão de que nenhuma delas serve. Assim, tenta fazer uma construção pessoal, distinguindo no funcionamento do Direito Penal vários níveis desse mesmo funcionamento e discute se a questão dos fins das penas não deverá ser vista,

---

neste contexto qualquer uma das funções que o pensamento da prevenção especial realiza: seja função positiva de socialização, seja qualquer uma das funções negativas subordinadas de advertências individual u de segurança ou inocuização.

[75] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit., p. 61.

fundamentalmente, em função da distinção das três fases em que o Estado enfrenta o individuo com o Direito Penal.

O direito penal enfrenta o individuo de três maneiras:

1- No momento da ameaça – encontra-se com ele ameaçando-o com penas através das disposições legais (máxime as que estão presentes no Código Penal):

O que pode, para Roxin, justificar a fase da ameaça é a necessidade que o Estado tem de proteger bens jurídicos essenciais, de forma a alcançar uma vida comum ordenada. Deste fim, o autor retira que:

▪ O Estado só poderá ameaçar com uma pena quando estejam em causa bens jurídicos essenciais (se forem morais já não deve actuar) e tem de se demonstrar que essa actuação seja essencial/indispensável - duas restrições à ameaça penal;

▪ Os bens jurídicos essenciais conseguem proteger-se através da prevenção;

▪ O direito penal também protege bens jurídicos supra individuais (ex.: ambiente), por forma a garantir a dignidade do Estado social, bem como garantir ao cidadão o livre desenvolvimento da sua personalidade.

2- No momento da aplicação da pena – depois da fase da lei escrita, será a fase da condenação, onde se pretende condenar quando a lei ameaçadora não fui suficiente; há que justificar a aplicação da pena através das sentenças:

➢ Em primeiro lugar, a finalidade da aplicação da pena demonstra que o fim da ameaça penal se concretiza ou tem eficácia;

➢ Por outro lado, o fim da aplicação será, também, proteger bens jurídicos essenciais;

➢ No entanto, na fase da aplicação não basta este fim, há que harmonizá-lo com a dignidade da pessoa humana (agente) e com a protecção dela; Mas como? Se o agente for julgado de acordo com a sua culpa e não de acordo com a sua utilidade, foge-se à crítica da teoria da prevenção global.

O problema prende-se com o conceito social de culpa – para Roxin a culpa que interessa é a culpa que os outros pensam que o agente tem (isto é, a culpa que a sociedade atribui àquele agente).

A professora Bárbara Sousa e Brito discorda com esta ideia – a culpa deve ser um juízo de censura de desvalor que se faz ao agente. Na aplicação da pena tem de se ter em conta o fim de evitar a prática de futuros crimes por parte do próprio agente.

3- No momento de execução da pena - para Roxin, a única execução que interessa é a socializadora – o fim da execução da pena é socializar o público – este é o fim último, mas que tem como limite a culpa e tem de respeitar a personalidade do arguido.

Resposta única e conclusiva para os 3 momentos: o fim das penas é a protecção subsidiária de bens jurídicos, individuais e sociais, mediante a prevenção geral e especial que salvaguarde a personalidade do agente no quadro traçado pela medida da culpa.

Concluindo as finalidades e limites das penas criminais:

Diz o prof. F. DIAS que, "a base da solução para o problema dos fins da pena reside em que estes só podem ter natureza preventiva, não natureza retributiva".

Fins das penas face à ordem jurídica angolana

Quais os fins das penas presentes nos arts. 40.º, nº 1 e 2 e no art. 70.º CP?

Art. 40.º, o legislador está centrado na fase da aplicação. Quando refere a protecção de bens jurídicos, está aqui plasmada a teoria da prevenção, a aplicação da pena só pode proteger bens jurídicos, não o que já aconteceu, mas próximos. Quando refere a reintegração do agente na sociedade, está presente a ideia de prevenção especial e de recuperação.

Artigo 71.º, o juiz deve ter em conta fins da pena na aplicação de determinada medida, nomeadamente a culpa. Está presente a teoria da reparação.

SECÇÃO IV

FINS DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. Noção de medida de segurança

Tal como as penas, as medidas de segurança constituem uma reacção organizada pelo Estado contra os agentes de comportamentos que põem em perigo ou lesam interesses ou valores merecedores de tutela penal[76].

2. O problema das medidas de segurança

2.1. Finalidade primária: prevenção especial em função de um facto ilícito-típico

As medidas de segurança visam obstar, no interesse da segurança da vida comunitária a prática de actos ilícitos-típicos futuros, através de uma actuação especial-preventiva sobre o agente perigoso. A finalidade de prevenção especial ganha assim, uma dupla função: por um lado, função de segurança, por outro lado, função de socialização[77].

2.2. Finalidade secundária: a prevenção geral

Ensina-nos o prof. F. DIAS que uma tal finalidade não possui qualquer autonomia no âmbito da medida de segurança, ela só pode ser conseguida de uma forma reflexa e dependente, na medida em que a privação ou restrição de direitos em que aplicação e execução da medida de segurança se traduzem na restrição de direitos como sejam: suspensão da execução do internamento; interdição de actividades; cassação da licença de condução de veículos motorizados; interdição da concessão de licença de condução de veículos motorizados; cassação de licença de porte de arma e interdição de concessão de licença de porte de arma.

3. Relacionamento da pena com medida de segurança

Do exposto compre-nos em afirmar que em matéria de finalidades das reacções criminais, não existem diferenças fundamentais entre penas e medidas de segurança, tal como sobreveio o art. 40.º do CP, cuja epígrafe é finalidades das penas e das medidas de segurança.

[76] Vasco Grandão Ramos; *Estudo das Penas*, Luanda: 2001, p. 7.

[77] Vasco Grandão Ramos; *Estudo das Penas*, Luanda: 2001, p. 13

4. Questão do dualismo ou monismo do sistema penal

O que se pretende esclarecer em primeiro lugar é se o nosso sistema sancionatório criminal é monista ou dualista?

O sistema sancionatório dualista é aquele em que existe a possibilidade em aplicar penas e mediadas de segurança ao mesmo tempo, no agente que tenha cometido um crime ou o seu comportamento mostra-se como um perigo social.

Não é este, pois o caminho seguido pelo nosso código penal, o relatório de fundamentação do referido código, propende para um sistema **tendencialmente monista**. Ou seja, **não se pode aplicar ao agente pelo mesmo facto uma pena e uma a medida de segurança privativas de liberdade ao mesmo tempo, ou aplica-se uma pena ou uma medida de segurança**.

Dissemos tendencialmente monista, na medida em que, não se pode aplicar ao mesmo tempo uma pena privativa de liberdade e uma medida de segurança privativa de liberdade.

Diferente é aplicação de uma pena privativa de liberdade e aplicação de uma medida de segurança não privativa de liberdade. Conforme o exemplo do Prof. F. DIAS diz o autor lusitano "que é perfeitamente possível, que o agente de um crime de violação, em que se seguiu o roubo da vítima, venha a ser declarado inimputável relativamente a violação, porque actuo sob influência de uma neurose grave determinante de uma tara de natureza sexual". Mas seja, já considerado imputável relativamente ao roubo. Caso em que lhe deverá ser aplicada uma pena pelo roubo e, eventualmente uma medida de segurança pela violação. Ainda que porem, o monismo do sistema não será afectado, porque não existe uma acumulação da pena com a medida de segurança como forma de reacções contra a criminalidade, antes, talvez possa dizer-se assim, pena e a medida de segurança, convivem numa sua divisão horizontal[78]. **Daí a expressão tendencialmente monista.**

[78] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit., pp. 100-101.

5. Medida de segurança vs pena

São múltiplos os critérios seguidos pela doutrina para distinguir a determinação da pena e das medidas de segurança. As mais correntes são os que se procedem às classificações em razão do (s):

1. **Dos agentes**[79] - as penas aplicam-se aos imputáveis e aos semi-imputáveis. As medidas de segurança, aplicam-se aos inimputáveis e, excepcionalmente, aos semi-imputáveis;

2. **Do carácter**[80] - as penas têm carácter retributivo-preventivo. As medidas de segurança, têm carácter preventivo,

3. **Da graduabilidade** - as penas são determinadas. As medidas de segurança não têm prazo determinado[81].

[79] Imputabilidade penal adquire-se, aos 16 anos de idade, sendo esta ainda muito reduzida ou relativa), só se conclui plenamente aos 18 anos, com o advento da maioridade geral (imputabilidade total ou absoluta), admitindo um escalão adicional e eventual de "maturação subsequente", até aos 21 anos. O que se entende, em suma, é que a imputabilidade, no caso dos menores com idade compreendida entre os 16 e os 18 anos, é uma imputabilidade penal especial.

[80] **Medidas de segurança** - têm a pretensão de evitar a futura prática de crimes, mediante a sua aplicação a situações de perigosidade social, ligada a determinadas actividades ou estilos de vida, de origem essencialmente exógena.

[81] A pena de prisão tem, em regra, a duração mínima de 3 meses e a duração máxima de 25 anos. Trata-se de uma norma dirigida ao legislador da Parte Especial, a que deve atender na determinação das penalidades. Mas essa duração máxima pode subir até aos 35 anos por força da punição da reincidência e do concurso de crimes ou em resultado de prorrogação da pena (artigo 44. n.º 2), nos casos em que a lei a impõe (*vd.* artigos 84.º e 85.º). Medidas de segurança - Apesar de que o artigo 101.º CP ter como epigrafe '' Pressupostos e duração mínima'', o legislador ordinário não determina expressamente os prazos de aplicação das medidas de segurança, penas diz que, ''quem tiver praticado um facto ilícito típico e for considerado inimputável, nos termos do artigo 18.º, é mandado internar pelo Tribunal em estabelecimento de cura, tratamento ou segurança, sempre que, por virtude da anomalia psíquica e da gravidade do facto praticado, houver fundado receio de que venha a cometer outros factos da mesma espécie''.

4. **Do fundamento**[82] - as penas têm como fundamento a culpabilidade do agente. As medidas de segurança têm como fundamento a periculosidade ou estado de perigo social/criminal do agente.

CAPÍTULO VIII

OS LIMITES DO DIREITO PENAL

SECÇÃO I

DIREITO PENAL E OUTROS RAMOS DO DIREITO

I. Algumas reflexões introdutórias

Diante deste tema, convém, analisar as relações que outros ramos de direito têm com o direito penal, sobretudo os mais representativos. É a essa análise que vamos proceder nos números seguintes. Dizer, ainda que, para analise e discussão, desta temática seguiremos na íntegra as lições do Prof. GERMANO M. DA SILVA[83].

1. Direito penal e outros ramos do direito

1.1. Direito penal e direito constitucional

O direito constitucional constitui a matriz axiológica do sistema jurídico do país.

O Direito Penal está intimamente relacionado com o direito constitucional. Sendo a Constituição o estatuto jurídico do político, o direito penal funda-se nela porquanto, as normas de direito penal ou são formalmente constitucionais ou são autorizadas ou delegadas por outras normas constitucionais e ainda porque as opções axiológicas constitucionais devem ser respeitadas pelas normas penais que lhe são subordinadas.

A Constituição não contém normas penais incriminadoras, mas contém normas que condicionam o conteúdo de normas penais, como sucede, com as normas que proíbem a pena de morte (art. 59.º), a tortura, tratamentos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos (art. 60.º), penas ou medidas de segurança com carácter perpétuo ou de

[82] A análise da culpabilidade compreendida como fundamento da pena é dirigida à protecção do indivíduo, isto sim revela o verdadeiro fundamento do direito penal moderno. **As medidas de segurança**, segundo a teoria, fundam-se e medem-se pela periculosidade do agente. Ou seja, declara o artigo 42.º n.º 3 do CP, que a perigosidade criminal é pressuposto irrenunciável da aplicação de qualquer medida de segurança.

[83] Germano Marques da Silva, Ob., Cit., pp. 141-

duração ilimitada ou indefinida e a transmissibilidade das penas (art. 66.º), bem como suas fontes (164.º, al. b) c)e e), todos da CRA de 2010.

Para além, das normas penais formalmente constitucionais é a Constituição que estabelece o quadro dos valores fundamentais da ordem jurídica angolana a que toda a legislação se tem de subordinar. No domínio penal são princípios que emanam da Constituição: o princípio da culpa, o da subsidiariedade, o da legalidade, da proporcionalidade, da humanidade e da jurisdicionalidade na aplicação do direito penal.

1.2. Direito penal e direito civil

O direito penal distingue-se formalmente do direito civil (e do direito privado em geral) pela natureza das sanções aplicáveis aos respectivos ilícitos.

O ilícito civil determina sempre, como consequência jurídica, a execução forçada do património, a obrigação de indemnização, a obrigação de restituição da coisa, ou a nulidade do acto; o ilícito penal acarreta uma consequência especial, a pena ou medida de segurança, que consistem num mal infligido ao autor do facto ilícito e que afectam ou podem afectar a própria pessoa do autor.

O ilícito civil determina, em regra, coacção patrimonial, o ilícito penal determina coacção pessoal. Dificilmente pode ir-se mais longe na distinção entre os dois tipos de ilícito.

Seria arbitrário determinar *a priori* os factos que devem considerar-se ilícitos penais ou ilícitos civis. Muitos factos deixam de ser ilícitos penais e passam a simples ilícitos civis por razões políticas as mais diversas, dependendo dos povos, dos tempos e das necessidades sociais. Veja-se, por exemplo, a despenalização dos cheques pós-datados sem provisão, que durante anos foram tutelados simultaneamente pelo direito civil e pelo direito penal e a partir de certa altura passaram a constituir só ilícitos civis.

1.2.1. A sanção criminal e a indemnização civil por perdas e danos. A responsabilidade civil emergente do crime

As sanções civis distinguem-se, como referimos, das sanções penais e visam sobretudo remediar o mal causado com a prática do facto ilícito, quer inutilizando o acto quanto às suas vantagens jurídicas - como é o caso das nulidades - quer fazendo cumprir

especificamente um dever jurídico violado, quer na reivindicação quer remediando patrimonialmente os interesses do ofendido, dando-lhe um valor equivalente ao dano patrimonial sofrido ou compensando-o de um dano moral.

As sanções criminais, como vimos, têm uma finalidade diversa, têm por fim castigar para prevenir a prática de actos criminosos a que podem ajuntar-se outras finalidades acessórias, como, a recuperação social do delinquente.

De lembrar que a sanção civil é essencialmente um remédio, ainda que possa secundariamente exercer uma função de repressão e de prevenção, enquanto a sanção criminal é sobretudo um castigo, pois já nada remedeia, e tem por função principal a prevenção de futura criminalidade.

1.3. Direito penal e direito administrativo

O Direito Administrativo é o sistema de normas jurídicas que regulam a organização e o funcionamento da Administração Pública, bem como as relações estabelecidas entre ela e os particulares no exercício da actividade administrativa de gestão pública[84].

Neste sistema de normas pode distinguir-se três tipos de normas administrativas: as normas orgânicas, as normas funcionais e as normas relacionais. Relativamente às normas orgânicas e funcionais a distinção com as normas do direito penal parece-nos nítida.

Aquelas regulam a organização da Administração Pública ou o modo de agir específico da Administração Pública - e distinguem-se das normas incriminadoras porque estas estabelecem sanções de natureza repressiva. **Relativamente às normas administrativas relacionais,** que são as que regulam as relações entre a Administração e os particulares no desempenho da actividade administrativa, é que as fronteiras são mais difíceis de estabelecer, quando se considere preceito e não apenas a sanção.

Grande parte da doutrina costuma distinguir o direito penal do direito administrativo considerando aquele repressivo e este preventivo, mas a distinção não nos parece aceitável. O direito penal é tão preventivo como o direito administrativo e este tão repressivo como aquele, pois um e outro impõem sanções à desobediência de um preceito que impõe ou proíbe um determinado comportamento.

[84] Diogo Freitas do Amaral, *Curso de Direito Administrativo,* Vol. I, Coimbra, 1989, p.125.

A diferença está na natureza da sanção em consideração da gravidade da ofensa que ambos os tipos de ilícitos acarretam aos interesses da colectividade. A diferença, no que respeita às normas que cominam sanções para quem desobedece aos comandos é apenas uma diferença de grau.

1.4. Direito penal e direito disciplinar

O direito penal e o direito disciplinar são ambos direitos punitivos, mas distinguem-se pela natureza da sanção e pelos fins que cada um prossegue.

O direito disciplinar prossegue o bom funcionamento dos serviços, das empresas e de certas actividades profissionais mediante a imposição de deveres funcionais e se a violação desses deveres pode muitas vezes lesar ou pôr em perigo de lesão bens jurídico-penais, essa lesão ou perigo de lesão não acontece necessariamente nem na maior parte das vezes.

As sanções disciplinares têm fins idênticos aos das penas criminais; como elas reprovam e procuram prevenir faltas idênticas por parte de quem quer que seja obrigado a deveres disciplinares e especialmente daquele que os violou. Mas aquelas sanções têm essencialmente em vista o interesse da função que defendem e a sua actuação repressiva e preventiva é condicionada pelo interesse dessa função, por aquilo que mais convenha ao seu desempenho actual e futuro.

Em resumo:

a) O ilícito disciplinar é diverso do ilícito criminal; pode haver factos que constituam o primeiro e não sejam compreendidos no segundo; e ainda que o mesmo facto revista os caracteres de ambos, isto não obsta a que, sob um ponto de vista, seja olhado como infracção disciplinar e, sob outro, como ilícito penal;

b) As sanções disciplinares são independentes das penais, podendo existir sem elas ou acumular-se com elas.

1.4.1. A relativa autonomia do procedimento disciplinar. O *"ne bis in idem"*

A doutrina entende geralmente que os procedimentos disciplinar e criminal, são autónomos e, por isso, a decisão num dos processos não compromete nem condiciona a decisão no noutro.

Os art^{s}. 64.º e 65.º do Código Penal dispõem sobre a pena acessória de proibição do exercício e suspensão do exercício de função pública. A pena acessória de proibição do exercício de função pública é aplicável pela prática de crime no exercício de função pública quando o facto:

a) For praticado com flagrante e grave abuso da função ou com manifesta e grave violação dos deveres que lhe são inerentes;
b) Revelar falta de dignidade no exercício do cargo ou da função;
c) Implicar a perda da confiança necessária ao exercício de cargo ou função.

Ora, uma das questões que se podem colocar é a seguinte: sendo aplicada a um funcionário uma pena acessória de proibição do exercício de função pública, nos termos do art. 64.º do CP, é ainda possível pelos mesmos factos, mas agora simplesmente na perspectiva disciplinar, condenar o funcionário na mesma ou noutra pena?

Se o tribunal condenar o funcionário por crime a que em abstracto seria possível a aplicação da pena criminal acessória, mas não aplicar esta por considerar não se verificarem os respectivos pressupostos, pode depois a administração condenar o funcionário numa pena disciplinar?

Questão análoga foi discutida (1982), pelo saudoso Prof. EDUARDO CORREIA defendido com veemência a plena autonomia do direito penal e do direito disciplinar.

Da plena autonomia do direito penal e do direito disciplinar parece dever concluir-se que uma decisão num domínio não prejudica a decisão que vier a ser tomada no outro e que a aplicação de duas sanções, uma de natureza penal e outra de natureza disciplinar, pelo mesmo facto não viola o princípio do *ne bis in*.

1.5. Direito penal e direito penal internacional

Com a designação inicialmente atribuída a Bentham, o direito penal internacional aproxima-se do direito internacional privado, pois um e outro são direitos nacionais, distinguindo-se pelo seu objecto.

O *iter criminis* das infracções penais pode realizar-se em mais de um país ou ter conexão com a ordem jurídica de mais de um país e consequentemente interessar a vários ordenamentos jurídicos nacionais, ocorrendo coincidência ou conflito de tratamento.

Ora, o direito penal internacional seria o direito interno destinado à resolução desses potenciais conflitos, constituído por normas cuja função é a de determinar a lei aplicável a factos criminosos que podem entrar em conexão com várias ordens jurídicas. Estas normas são normas de direito interno. Pode discutir-se a amplitude do seu objecto, mas são sempre de considerar normas penais, ainda que em sentido amplo, e ainda também normas penais integrantes e não normas incriminadoras. Já discutimos essa temática nas matérias introdutórias.

1.6. Direito penal e o direito internacional penal

Diversamente do direito penal internacional, como referimos é um ramo do direito interno, o agora denominado direito internacional penal é o ramo do direito público internacional que determina as infracções, estabelece as penas e fixa as condições da responsabilidade penal internacional dos Estados e dos indivíduos.

Trata-se de uma realidade cujas origens remontam somente à primeira Guerra, mas que tem tido muito recentemente manifestações que a erigem como um verdadeiro direito internacional no domínio penal.

É que, segundo os princípios do direito internacional penal, a jurisdição interna concorre com a jurisdição internacional na competência para o julgamento dos crimes previstos pelo direito penal internacional, como expressamente foi consagrado no Estatuto do Tribunal Militar Internacional, constituído pelos Aliados, em Londres, em 8 de Agosto de 1945.

A problemática do direito penal internacional no que ora, nos importa respeita à existência de um direito que tenha directamente como destinatários os cidadãos do mundo e não apenas normas de direito internacional convencional que vinculem os Estados que ratificaram essas convenções.

A primeira manifestação desse direito parece encontrar-se no tratado de Versailles, em que se reclamava a punição dos criminosos alemães implicados na 1.ª Grande Guerra

Mundial. A questão voltou a assumir grande importância no fim da 2.ª a Guerra Mundial, em que pela Convenção de Londres as potências aliadas definiram crimes de guerra e contra a paz e a humanidade, atribuindo-lhes eficácia retroactiva. Com base na Convenção de Londres tiveram lugar os julgamentos de Nuremberga e de Tóquio em que foram julgados várias pessoas com responsabilidades naquele conflito, por crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Os julgamentos de Nuremberga e de Tóquio foram criticados por muitos autores como constituindo legislação retroactiva. Em todo o caso não parece ser lícito alegar o carácter retroactivo da legislação em casos futuros, já que a sentença do Tribunal de Nuremberga constitui um precedente, e os seus princípios, bem como os estabelecidos na Carta, foram mais tarde aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas e pela Comissão de Direito Internacional, sendo agora de considerar direito penal internacional comum.

A questão do direito penal internacional e da jurisdição internacional colocou-se novamente na actualidade com a criação dos Tribunais Internacionais *ad hoc* para o julgamento dos crimes de guerra, contra a paz e a humanidade praticados na ex-Jusgolávia1 e no Ruanda e as Nações Unidas têm vindo a preparar a constituição de um Tribunal Penal Internacional.

CAPÍTULO XIX

A LEI PENAL E A SUA APLICAÇÃO

SECÇÃO I

APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO

I. Algumas reflexões introdutórias

Todos sabemos que as normas jurídicas só devem aplicar-se em princípio, aqueles factos que tenham lugar depois da sua entrada em vigor, e por conseguinte nunca antes da sua publicação[85].

No direito penal este princípio está intimamente ligado ao princípio " *nullum crimen sine lege*".

Trata-se naturalmente de defender o individuo do próprio legislador, que poderia, através de uma nova incriminação, ir punir a prática de um facto só levando a cabo pela convicção de que era ilícito, isto criaria como bem se compreende a maior intranquilidade social[86]. Nestes termos a pena nunca deveria realizar os seus fins, previstos no art. 40.º do CP. Nesta perspectiva, o direito penal desempenha um papel importantíssimo em defender os direitos individuas.

1. Princípio geral da aplicação da lei penal no tempo

I.1. O princípio da irretroactividade da lei penal

[85] Eduardo Correia, *Direito Criminal*, II reimpressão, Coimbra, 1968, p. 153.

[86] Ibidem.

A irretroactividade é o princípio reitor da aplicação da lei penal no tempo, nos termos do art.º 2.º do CP, determina que "as penas e as medidas de segurança são determinadas pela lei vigente ao tempo da prática do facto ou da verificação dos pressupostos de que dependem". Isto significa que a lei só dispõe para regular factos futuros.

Conforme diz o Prof. JOSÉ F. COSTA, o princípio da irretroactividade da lei penal é ele próprio o pórtico de um pensamento, abertura ou rasgo de uma maneira de ver o direito penal, forma de perscrutar o grau de civilização de um povo[87].

No mesmo sentido entende o autor, acima citado, que o direito penal é um direito das liberdades, no qual não teria nenhum apoio, nenhum entendimento de acordo com o qual, se o princípio da proibição da retroactividade (irretroactividade) da lei penal fosse absoluto que implica-se a imposição de normas penais menos favorável ao agente[88]. Por isso se impõe o princípio da aplicação da lei penal mais favorável ao agente, funcionando como uma excepção daquele.

2. Excepção do princípio da irretroactividade da lei pena no tempo

2.1. Princípio da aplicação da lei mais favorável

Lei penal é mais favorável – quando?

i. Quando a punição é mais leve (art. 2.º nº 2, do CP);
ii. Quando a lei nova elimina essa infracção (o facto que era considerado crime pela lei antiga, deixa de o ser pela lei nova – art. 2. º, nº 3, do CP e art. 65.º, n.º 4 da CRA de 2010);
    - Ou a norma penal que previa aquele crime desaparece sem ser substituída por qualquer outra;
    - Ou apesar de não ser eliminada, o facto concreto deixa de ser punível porque surge uma nova causa de exclusão da ilicitude (ex.: o aborto deixou de ser considerado crime se for feito até à 16ª semana de gestação, isto é uma causa de exclusão da ilicitude).

Para determinar a lei mais favorável, não se deve apenas confrontar as duas leis mas sim referir um facto efectivamente praticado – o caso *sub judice*.

[87] José de Faria Costa, *Noções Fundamentais de Direito Penal*, 3.º Ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 76.

[88] Ibidem.

Leis em confronto no momento da execução da pena:

➢ De acordo com o art. 2.º, nº 2, do CP, – se é mais leve aplica-se a lei nova.

➢ Se já houve transito em julgado:

▪ Se face à lei nova o limite máximo a aplicar ao crime for menor que a pena concreta aplicada ao agente, nesse caso a pena é automaticamente reduzida ao limite máximo da lei nova (o limite máximo será então menor que a pena aplicada, havendo uma redução imediata desta).

▪ O agente pode recorrer ao tribunal para recalcular a medida da pena à luz da lei nova.

Por ex.: C pratica um crime sob a vigência da lei *X*, que comina pena de reclusão de 1 a 4 anos. Por ocasião do julgamento, passa a viger a lei *Y*, regulando o mesmo facto e impondo a pena de reclusão de 2 a 8 anos.

Qual a lei a ser aplicada, a anterior, mais favorável, ou a posterior, mais severa?

A questão das penas temporárias e das leis de emergência.

As leis de emergência ou temporárias têm um período de vigência determinado que vigora num espaço de tempo limitado face a situações excepcionais e, esse prazo ou resulta expressamente da lei ou da verificação de circunstâncias excepcionais.

Como o próprio nome indica, aplicam-se a situações de emergência, temporárias ou de anomalia.

Regime – art. 2.º n.º 4, do CP:

➢ O facto praticado durante a vigência de uma lei de emergência, continua a ser avaliado à luz dela, mesmo que o julgamento seja posterior;

Questão doutrinária: mas isto não é inconstitucional?

Se o que era considerado crime deixou de o ser, porque é que vamos aplicar uma lei de emergência?

Para maior parte da doutrina, as leis temporárias têm aplicação aos factos praticados durante a vigência da lei, mesmo que julgados em momento posterior ao da vigência.

Lei penal intermédia

Neste caso, o início da vigência é posterior ao momento da prática do facto e o termo da vigência é anterior ao julgamento. Logo, a lei não se encontra em vigor nem no momento da prática da acção nem no momento do julgamento.

3. O *tempus delicti*: Momento da prática do facto

Conforme diz, F. DIAS o pressuposto de actuação do princípio da irretroactividade é pois a determinação do *tempus delicti*, isto é, daquele que deve considerar-se o momento da prática do facto[89].

Desta feita, pergunta-se em que momento o facto é praticado? Para ser respondida a referida questão é necessário fazer uma análise minuciosa, a chamada determinação do *tempus delicti*, com maior realce as teorias consagradas no art. 3.º do CP, como sejam:

a) Teoria da actividade

Segundo a teoria da actividade o facto considera-se praticado no momento em que o agente actuou, ou no caso de omissão no momento em que devia ter actuado, independentemente do momento em que o resultado típico se tenha verificado.

Esta é a posição adoptada pelo nosso código penal, nos termos do art. 3.º do CP.

b) Teoria do resultado ou evento

Na teoria do resultado ou do evento o facto considera-se praticado no momento da produção do resultado.

Ex.: No homicídio tempo do crime é o de seu resultado (morte), e não o da prática dos actos executórios (acção).

c) Teoria mista ou da ubiquidade

[89] Jorge de Figueiredo Dias-Direito Penal-Parte Geral-Tomo I: Questões Fundamentais da Doutrina do Crime. 2.º Edição. Coimbra Editora: 2007

Quanto a teoria mista é a combinação das duas primeiras, de acordo com essa teoria o facto considera-se praticado independentemente, o momento da acção ou do resultado.

No homicídio, por exemplo é tanto o tempo da prática da acção quanto o da produção do evento morte.

4. Instituto da prescrição

Uma outra forma de relacionar o direito penal com o tempo encontra-se no instituto da prescrição, previsto na parte geral do código penal, a luz dos artigos 133.º e ss.

O instituto da prescrição do procedimento criminal reveste natureza preponderantemente material e não processual ou adjectiva. A prescrição do procedimento criminal não se identifica dogmaticamente com uma causa de exclusão da ilicitude ou da punibilidade, mas sim, em todo o caso, com uma causa de afastamento da punição. Com isso, queremos dizer o seguinte: o agente deverá saber à partida que a sua conduta é punida com determinada pena, mas que existe um limite de tempo, em que o seu comportamento criminal pode ser perseguido penalmente[90]. Passado o tempo estabelecido por lei, cessa tal perseguição.

Nos ensinamentos de F. DIAS à prescrição da pena constitui um obstáculo de realização (execução) processual- e acentua, no plano material, que o decurso do tempo tornou a execução da pena sem sentido[91]. Pois conforme ficou referido na nota antecedente o facto deixou de carecer de punição.

Caso assim, não fosse contrariaria, aliás, a essência dos fins das penas e consagraria retribuição de matriz eminentemente retributiva[92].

[90] Pereira Victor De Sá; Alexandre Lafayette, *Código Penal Português- Anotado e Comentado-Legislação Conexa e Complementar*, 2.º Ed. Quid Juiris Editora. Lisboa, 2014. p. 83.

[91]Jorge de Figueiredo Dias, *Direito Penal II, As Consequências Jurídicas do Crime, Coimbra*: 1993, p. 702.

[92] Pereira e Lafayette, Ob. Cit., p, 353.

SECÇÃO II

APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO ESPAÇO

I. Algumas reflexões introdutórias

O âmbito de vigência da lei penal no espaço, suscita questões como em que espaços ou território é que a lei penal angolana é aplicável?

A verdade é que pretende-se provar, que nem sempre o crime irá violar interesses apenas do Estado angolano. Podendo naturalmente acontecer que o mesmo agente viole bens jurídicos penais de dois ou mais Estados. Se assim, suceder, estes Estados se arroguem o direito de puni-lo, podendo apenas um proceder a tramitação processual, dentre eles, qual Estado irá punir o agente? A aplicação da lei penal no espaço preocupa-se com essas questões.

Assim sendo, todos os códigos penais contêm disposições sobre os modos de resolução desses conflitos. O conjunto dessas disposições é vulgarmente chamado de direito penal internacional.

Tradicionalmente contrapõem-se a designação de direito internacional penal, não cabe nos linde deste capítulo discutir essa questão, até porque já foi em momento antecedente devidamente tratada. Por agora, nos atemos apenas na aplicação da lei no espaço, a palavra espaço aqui é tratada como sinónimo de território.

O território angolano não é um conceito dado pelos penalistas, resultam das normas do direito constitucional e também das normas de direito internacional público. Portanto não cabe, nos limites deste livro discutir essa questão, por se afigurar uma discussão desnecessária e irrelevante.

1. Princípio geral da aplicação da lei no espaço

I.1. Princípio da territorialidade

O princípio da territorialidade é o primeiro, geralmente o predominante - os crimes cometidos dentro de um certo território são regidos pelas suas leis, independentemente da nacionalidade do agente do crime ou da vítima.

Dito de outro modo, seguindo a orientação prevista no art. 4.º do CP, a Lei Penal angolana é aplicável a factos total ou parcialmente praticados em território angolano ou a bordo de navios ou aeronaves de matrícula ou sob pavilhão angolanos, independentemente da nacionalidade do agente, salvo convenção ou tratado internacional em contrário.

A partir da terceira alinha do referido artigo sobretudo na última parte encontramos consagrado o chamado do **princípio da bandeira ou critério do pavilhão** como é preferivelmente chamado pelo Prof. F. DIAS, segundo o qual o Estado em que está, registado navio ou aeronave pode sujeitar ao seu poder punitivo as infracções cometidas a bordo, ainda que o facto, haja sido cometido por um estrangeiro em território de soberania estrangeira ou no alto mar salvo convenção ou tratado internacional em contrário.

Este princípio (Princípio da bandeira ou critério do pavilhão) é decorrente da teoria do *territoire flottant*) território flutuante e se vincula ao princípio da territorialidade. Por ele, consideram-se as embarcações e aeronaves extensão do território do país em que se acham matriculadas. Ou seja, o critério do pavilhão é visto ou considerado como uma ampliação ou elasticidade do princípio da territorialidade.

Portanto, a maioria das legislações nacionais elegem o princípio da territorialidade como o princípio basilar de aplicação da lei penal no espaço[93], a nossa lei não é excepção quanto a isso.

[93] **Razões materiais**, são de natureza político-criminal e estão relacionadas com os fundamentos e as finalidades preventivas da punibilidade penal. É no território do estado, onde foi praticado o crime que mais se fazem sentir as necessidades de prevenção geral positiva de pacificação social e de reafirmação da ordem jurídica-penal e da importância dos bens jurídicos ai protegidos.

Razões processuais, pois é no território, onde o crime foi praticado, que a investigação e a prova do crime é mais fácil de realizar-se e, portanto maiores são garantias de uma decisão eficaz e justa.

A territorialidade como princípio fundamental da aplicação da lei penal no espaço encontra-se entre nós consagrados no art.º 4.º CP segundo o qual a Lei Penal Angolana é aplicável a factos total ou parcialmente praticados em território angolano ou a bordo de navios ou aeronaves de matrícula ou sob pavilhão angolanos, independentemente da nacionalidade

2. Excepções ou desvios do princípio da territorialidade

2.1. Princípio da nacionalidade

Princípio da nacionalidade**,** também chamado da personalidade, determina que a lei a ser aplicada é sempre a do país de origem do delinquente, onde quer que ele se encontre. Acresce o Prof. EDUARDO CORREIA, desde que este tenha praticado o facto no estrangeiro e se encontra em seu país[94].

Este princípio se desdobra em dois subprincípios: **princípio da nacionalidade activa e princípio da nacionalidade passiva**. Pelo primeiro, aplica-se a lei do país a que pertence o agente, sem se atender ao bem jurídico violado pelo crime; pelo segundo, a lei do país de origem só se aplica quando o bem jurídico ofendido pertença a pessoas da mesma nacionalidade.

A aplicação deste princípio exige a verificação dos seguintes requisitos:

a) Que o infractor se encontre em Angola;
b) Que o facto constitua crime no país onde foi praticado; e
c) Não tendo o agente sido julgado no país em que cometeu o crime.

A razão de ser deste princípio reside na ideia de que os nacionais de um certo Estado permanecem ligados/vinculados a sua nação, onde quer que se encontrem. Visa garantir que os angolanos que tenham cometido crimes em território estrangeiro sejam responsabilizados; visa prestar solidariedade ao Estado estrangeiro em que a ordem pública foi violada pelo nacional que regressou a Angola e não pode ser extraditado em decorrência do princípio da não-extradição de nacionais. Este princípio (da não extradição dos nacionais) encontra-se previsto no artigo 70.º ca CRA de 2010.

2.1.1. Princípio da protecção dos interesses nacionais

Estabelece que a lei penal angolana aplica-se a todos os actos praticados no estrangeiro, que violem os interesses superiores do Estado, sejam eles praticados por nacionais ou estrangeiros.

[94] Eduardo Correia, *Direito Criminal*. II reimpressão, Coimbra Editora., p. 176.

Dito de outro modo, este princípio leva em conta a nacionalidade do bem jurídico lesado pelo crime, independentemente do local de sua prática ou da nacionalidade do sujeito activo.

Enumeração dos interesses protegidos:

- ✓ Interesses que são alicerces do funcionamento do Estado de Direito Democrático (arts.329.º a 338.º CP);
- ✓ Interesses do Estado na confiança de circulação fiduciária (255.º a 265.º) – ex.: a Falsificação de Moeda;
- ✓ Se estiverem em causa interesses de independência e integração nacionais (310.º a 328.º) – ex.: traição à pátria;
- ✓ Quando estejam em causa interesses de segurança da comunidade ou segurança e funcionamento do Estado de Direito – ex.: burla informática e das comunicações (441.º a 444.º);

2.1.2. Princípio da universalidade

Este princípio advoga que os Estados modernos devem proteger certos interesses considerados como fundamentais pela comunidade internacional, independentemente de quem seja o agente do crime ou o lugar onde o facto ocorra.

A lei penal angolana, reconhece a necessidade de protecção desde bens supranacionais, fazendo uma enumeração taxativa (5.º alínea b). assim, determina aplicabilidade da lei angolana com base neste principio aos crimes de: **Crimes Contra a Paz e a Comunidade Internacional (art. 377.º a 390.º do CP).**

3. *lucus delicti:* Lugar da prática do facto

A quanto a aplicação da lei penal no espaço o sistema jurídico angolano, a semelha-se com sistema jurídico português e francês, baseia-se essencialmente no princípio da territorialidade.

A aplicação do princípio da territorialidade pode dar lugar a várias dificuldades. Assim, há crimes cuja consumação se protela por mais ou menos tempo, podendo a consumação protelada ter lugar em vários países. É possível também suceder que várias

actividades do mesmo crime ou actos de comparticipação da mesma infracção se espalhem por diversos Estados.

Nestes e em outros casos coloca-se o problema de saber onde deve considerar-se a **sede do delito**? A lei substantiva não resolve expressamente o problema. A solução é encontrada na doutrina que oferece soluções nas seguintes teorias:

a) Teorias da actividade ou acção

Os defensores desta teoria são de opinião, que o lugar do crime é aquele em que se cometeu a acção ou omissão.

b) Teoria do resultado ou evento

Para estes o lugar do crime é aquele em que se produziu o resultado.

c) Teoria ubiquidade ou mista

O facto considera-se praticado no momento em que o agente actuou ou, no caso de omissão, no momento em que devia ter actuado, independentemente do momento em que o resultado típico se tenha verificado. Este é a teoria adoptada pelo nosso código penal nos termos do art. 6.º.

4. O instituto da extradição

A extradição é o acto pelo qual um país entrega ao outro um criminoso para ser julgado ou punido.

A extradição justifica-se pois ela convém aos dois Estados, ao que extradita porque se vê livre de um criminoso e ao que pede a extradição pois pode punir o autor de um delito. Inicialmente, a extradição fazia-se por acordos particulares, mais tarde, à partir do século XVII, começou a ser regulada por acordos internacionais.

As fontes que regulam a extradição são de Direito internacional e de direito interno. **Promanam de tratados, convenções e acordos entre os Estados, assentando-se no princípio da reciprocidade, e adoptados e completados por leis internas.**

4.1. Condições da extradição:

a) A extradição só pode ter lugar mediante decisão judicial;
b) Relativamente ao delito ou crime, conceder-se-á a extradição quando o crime seja punível pela lei angolana e pelo Estado requerente.

4.2. Causas excludentes da extradição

1ª A extradição não se aplica a nacionais. Veja-se o 70.º n.º 1 da CRA de 2010;

2ª Não é permitida a extradição de cidadãos estrangeiros por motivos políticos ou por factos passíveis de condenação à pena de morte e sempre que se admita, com fundamento, que o extraditado possa vir a ser sujeito a tortura, tratamento desumano, cruel ou de que resulte lesão irreversível da integridade física, segundo o direito do Estado requisitante. Veja-se o art. 70.º da CRA de 2010.

4.3. Processo de extradição

Distinguem-se em duas fases: administrativa e judicial.

Uma vez verificado que, o criminoso se refugiou num país estrangeiro, o Ministério público fará uma exposição em que apresentará o assunto devidamente instruído com as provas justificativas, que será transmitido ao Ministério dos Negócios estrangeiros do país onde o criminoso se refugiou.

4.4. Efeitos da extradição

Esta tem como efeito a entrega do indivíduo ao governo que pede a extradição.

4.5. Limites da extradição

A extradição é dominada pelo **princípio da especialidade,** segundo o qual o extraditando não pode ser punido por uma infracção anterior à entrega, que seja diferente daquela que motivou a extradição. O fundamento deste princípio resulta do facto que o Estado requerente poderia pedir a extradição tendo em vista a punição de outros factos diferentes dos que motivaram a extradição, como é o caso de crimes políticos que não são admitidos como fundamento da extradição.

4.6. Reextradição

Ocorre quando o Estado beneficiário entrega o extraditando a um outro Estado, seja ele o que lhe entregou o agente, seja ele um terceiro. Nestes casos, segundo EDUARDO CORREIA é necessária a autorização do Estado que extraditou o criminoso.

SECÇÃO III

APLICAÇÃO DA LEI PENAL QUANTO AS PESSOAS

I. O princípio da igualdade dos cidadãos

Lei é igual para todos e não existem privilégios pessoais que limitem a aplicabilidade da lei penal, não vigorando o princípio do *princeps legibus solutus*[95].

Este raciocínio se funda no princípio da igualdade de todos perante a lei. Assim, Constituição da República de Angola de 2010, no seu art.º 23.º, reza que todos são iguais perante a Constituição e a lei, sem distinção de qualquer natureza.

A igualdade aqui tratada pode ser, entendida em duais perspectivas, por um lado, igualdade formal ou jurídica – própria do Estado liberal. Por outro lado, igualdade material – prevê que as pessoas sejam iguais, mas baseadas em pressupostos bem claros, ou seja, não se pode tratar duas pessoas como iguais que verdadeiramente não sejam.

Nesta perspectiva o princípio impõe um tratamento jurídico idêntico a todos os que se encontrem em situações idênticas ou similar, nomeadamente, igualdade de sexo, igualdade de oportunidades e igualdade perante os cargos públicos.

A ideia de igualdade exige a vedação de privilégios e de discriminações de situações de desvantagem e, por outro lado, deverá haver tratamento igual para situações iguais e um tratamento desigual em situações desiguais. No fundo, a questão central é a de saber, nas palavras de GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, se "existe fundamento material bastante para diferenciações de tratamento jurídico[96]". Será sob este prisma que explicaremos as razões para o tratamento das imunidades à luz do princípio da igualdade.

[95] Manuel Cavaleiro de Ferreira, *Direito Penal Português*, I, p. 157; Germano Marques da Silva, *Curso de Processo Penal*, I n.º 22.3.

[96] J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. I, 3.ª edição revista, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 341.

1. Casos de excepção do princípio da igualdade

1.1. Imunidades

Segundo LAURA RICCIO, imunidade penal é o conjunto de situações que, não obstante a prática de factos previstos na lei como crimes, não implica consequências penais para determinados sujeitos[97].

Do ponto de vista jurídico-constitucional imunidades são privilégio de os titulares de órgãos de soberania que só poderem ser detidos, presos ou acusados criminalmente mediante autorização do órgão a que pertencem ou de outro órgão de soberania.

1.2. Imunidades diplomáticas

Imunidades diplomáticas são situações que certas pessoas possuem em virtude das suas funções na orgânica do Estado ou em razão de regras de Direito Internacional, designadamente. As denominadas imunidades diplomáticas, advêm do Direito Internacional, excluindo os Chefes de Estado e representantes dos Governos Estrangeiros da jurisdição criminal dos países onde se encontram acreditados[98].

Ademais, as imunidades têm uma natureza adjectiva, isto é, os diplomatas acreditados em Angola ou vice-versa, gozam de uma isenção temporária, quanto à inaplicabilidade das penas previstas nas leis penais para os factos por eles praticados e aos quais, segundo os princípios gerais, seria aplicável a lei penal angolana. Tal como diz EDUARDO CORREIA, as imunidades substantivas são como que apagam o crime. Ao passo que as imunidades adjectivas tornam dependente o procedimento criminal de certas condições[99], ou seja natureza substantiva só pode determinar-se em razão de cada imunidade concreta, em função dos termos da lei que a atribui.

1.3. Titulares de órgãos públicos

[97] Definição original: “Per immunità in generale deve intendersi l’insieme delle situazioni in cui, alla comissione di fatti previsti dalla legge come reato, non seguono per determinati soggetti conseguenze penali.”, cfr. RICCIO, Laura, “Immunità”, in Digesto delle Discipline Penalistiche, VI, quarta edizione, Torino: UTET, 1987, p. 176.

[98] Damásio de Jesus. Direito Penal-1-Parte Geral, p. 180

[99] Eduardo Correia, Direito Criminal, Coimbra Editora, Ed. 2.º, 1968. p. 190

No âmbito da aplicação da lei penal às pessoas que sejam titulares de cargos públicos a Constituição da República de 2010, estabelece algumas diferenças relativamente ao Presidente da República, Vice Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros, Secretários de Estado e Vice-Ministros, Deputados e em menor medida outros Membros do Governo[100].

a) Presidente e Vice Presidente da República

O Presidente e o Vice-Presidente da República encontram-se sujeitos a um regime dualista, isto é, por um lado, gozam de imunidades ou privilégios, ou seja, não são responsável pelos actos praticados no exercício das suas funções, salvo em caso de suborno, traição à Pátria e prática de crimes definidos pela presente Constituição como imprescritíveis e insusceptíveis de amnistia, implicando a destituição do cargo e a impossibilidade de candidatura para outro mandato (art.º 127.º n.º 1 e 2 da CRA de 2010). Por outro lado, respondem perante ao Tribunal Supremo, pelos crimes estranhos praticados ao exercício das suas funções, isto depois de cinco anos terminado o seu mandato (art.º 127.º n.º 3 da CRA de 2010)[101].

Os processos de responsabilização criminal e os processos de destituição, do Presidente e o Vice-Presidente da República, a que se refere o parágrafo anterior obedece aos requisitos estabelecidos no art. 129.º n.º 5 da CRA de 2010.

b) Deputados

As imunidades parlamentares consistem essencialmente no direito em que os deputados têm no parlamento de emitirem livremente as suas opiniões e votos e de não serem detidos ou processados, sem a autorização prévia concedida Assembleia Nacional (art.º 150.º n.º 2 da CRA de 2010).

A imunidade parlamentar consolidou-se sobretudo como um meio de proteger a liberdade de expressão dos parlamentares.

Esta imunidade também é chamada de inviolabilidade ou imunidade em sentido estrito - traduz-se na não sujeição dos deputados a detenção, prisão, mera audição (como

[100] Cristóvão Marcos Chivela; Aiken Renkel Afonso, *Projecto de Direito Penal Angolano, Noções Fundamentais e Teoria Geral do Crime,* Lubango, 2021.

[101] Ibidem.

declarante ou como arguido) ou julgamento por quaisquer outros actos, salvo nos casos especificados na Constituição ou na lei e com as formalidades nelas previstas. (art.º 150.º n.º 2 da CRA de 2010)[102].

c) Outros Membros de Estado

Conforme já referenciado, no âmbito de vigência pessoal da lei penal, podem existir determinadas categorias de pessoas que, por gozarem de um estatuto jurídico-constitucional de imunidade, poderão estar subtraídas ao poder punitivo estadual, nomeadamente, Ministros de Estado, Ministros, Secretários de Estado e Vice-Ministros os Juízes, os Magistrados do Ministério Público, Governadores Provinciais, Generais e Comissários. *Vide*. art[s]. 75.º, 140.º, 179.º, 188.º e 201.º, todos da CRA de 2010). Esta matéria encontra-se melhor desenvolvida no projecto doutrinal devidamente citado em nota de rodapé.

1.4. Instituição essencial à administração da justiça

Quando a Constituição da República, se refere as Instituições Essenciais à Administração da Justiça, fala tão-somente dos Provedores de Justiça (art.º 192.º CRA de 2010) e dos Advogados (art.º 194.º CRA de 2010).

Quanto aos advogados, dispõe a Constituição da República de Angola que " Nos actos e manifestações processuais forenses necessários ao exercício da sua actividade, os Advogados gozam de imunidades, nos limites consagrados na lei'', como elemento essencial à administração da justiça (art.º 194.º n.º 1 da CRA de 2010).

A CRA de 2010, vai mais longe estabelecendo, garantia a inviolabilidade dos documentos respeitantes ao exercício da profissão, nos limites previstos na lei, apenas sendo admissíveis buscas, apreensões, arrolamentos e diligências semelhantes ordenados por decisão judicial e efectuadas na presença do magistrado competente, do Advogado, bem como do presidente do conselho provincial da Ordem dos Advogados, ou Delega da Ordem conforme os casos, os quais podem delegar um outro advogado 47.º EOA. Sempre que esteja em causa a prática de facto ilícito punível com prisão superior a dois anos e cujos indícios imputem ao Advogado a sua prática (…).

[102] Ibidem

PARTE II

DOUTRINA GERAL DO CRIME

TÍPÍTULO I

CONSTRUÇÃO DA DOUTRINA GERAL DO CRIME: TEORIA DA INFRACÇÃO

CAPÍTULO I

DO FACTO PUNIVEL

I. Algumas reflexões introdutórias

Na concepção mais acatada até o final do século passado no caso a concepção finalista, a conduta ou facto punível era entendido como a acção ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade.

Sua existência pressupõe um comportamento humano (não há conduta no comportamento de animais). As pessoas jurídicas, embora possam ser sujeitos activos de crimes, como será analisado, somente podem praticar uma conduta penalmente relevante quando forem cometidas em seu nome, por sua conta e no seu interesse, ou em seu benefício, a título individual ou no desempenho de funções, pelos seus órgãos, representantes, ou por pessoas que nela detenham uma posição de liderança. (art. 9º do CP).

1. Classificação tripartida do facto punível (infracções)

Seguindo os ensinamentos do Prof. BANGULA QUEMBA[103], no ordenamento jurídico angolano coabitam três tipos de infracções: **crime e contravenção, artigos 1.º e 142.º,** ambos do CP, e **transgressão administrativa, artigos 3.º e 4.º** da LTA[104].

A Constituição da República de Angola (CRA de 2010) estabelece na al. e) do artigo 164.º como sendo matéria de reserva absoluta da Assembleia Nacional, a «definição dos crimes, penas e medidas de segurança, bem como as bases do processo criminal» e na al. *t*) do n.º 1 do artigo 165.º, estabelece o «regime geral da punição das infracções disciplinares e dos actos ilícitos de mera ordenação social, bem como do respectivo processo». Interessa-nos apenas reflectir sobre as **contravenções e crimes**. Ademais, por ser o direito penal por excelência, um direito fragmentário deixaremos a transgressão administrativa para o outro ramo do direito.

[103] Advogado e Docente da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola.

[104] Celestino Quemba, Contraordenações, Contravenções e Transgressões Administrativas: Um Olhar Ao Ordenamento Jurídico Angolano, p. 49.

SECÇÃO I

CONTRAVENÇÃO

I. Reflexões introdutórias

O direito de mera ordenação social começou a nascer no final das duas Guerras Mundiais, primeiro da República Federal da Alemanha (RFA) e depois na República Democrática Alemã (RDA). Por intermédio de Eberhard Schmidt, hoje comummente considerado como que o pai do direito contra-ordenacional actual[105].

Uma das grandes preocupações deste autor na época foi, libertar o direito penal económico de todos os sinais de degenerescência totalitária que o caracterizaram desde 1938. Um dos sinais mais marcantes dessa decadência foi a autêntica tomada de assalto da esfera de jurisdição criminal pela administração. A confiança do Estado totalitário no poder judicial era nula, tal como era nulo o seu respeito pelo princípio da independência judicial[106].

Comprometendo desta forma o sistema "jurídico" alemão, em matéria de crimes económicos tivesse sido insuflado sobretudo do lado das chamadas "penas de ordem" ("*Ordnungsstrafen*"), sobre as quais a administração nazi tinha mão directa. Isso explica que com o crescimento exponencial dos tipos penais económicos associado ao esforço de guerra o direito penal económico alemão tivesse ficado infestado desse tipo de delitos através dos quais, durante o período nazi, a administração logrou tomar conta da jurisdição penal.

O que sucedeu foi que, condutas já tipificadas como crimes foram também qualificadas como infracções às quais poderiam ser aplicadas penas de ordem, levando a que um mesmo facto pudesse ser ameaçado com uma sanção penal, mas também com uma pena de ordem. Nesse caso, era a administração que chamava a si a faculdade de discricionariamente decidir se exercia o seu poder sancionatório.

Optando, na maior parte das vezes por exercê-lo, mediante aplicação de uma pena de ordem, a administração determinava ainda que o facto deixaria de ser punido judicialmente com uma pena criminal. Deste modo, ao visado era retirada a

[105] Nuno Fernando da Rocha Almeida Brandão, *Crimes E Contra-Ordenações: Da Cisão À Convergência Material*, Coimbra, 2013, p. 18.

[106] Ibidem

possibilidade de ver o seu caso apreciado por um juiz independente e de acordo com as regras e garantias próprias do processo penal, passando a sua sorte a ser decidida exclusivamente pela administração nazi, que, naturalmente se considerava subtraída ao controlo judicial.

Conforme escreve o Prof. BANGULA QUEMBA, Já nesta altura, EBERHARD SCHIMIDT, direccionava todos os seus conhecimentos jurídico-económicos para «libertar o direito penal económico de todas as perversões da ditadura nazi», considerando sobretudo que a aplicação das sanções do foro penal fosse da responsabilidade exclusiva dos tribunais, cumprindo-se, deste modo, o princípio da separação de poderes, como princípio elementar do Estado Democrático de Direito[107].

Finalmente em 1949 consolida-se o direito penal da contra-ordenação e faz-se a captura do direito penal de justiça. Restituir-se à justiça aquilo que é da justiça e dar ou deixar à administração apenas aquilo que é da administração[108]. Surgindo desta feita um novo tipo de infracção, a contra-ordenação punível com uma sanção pecuniária, isto é, coima.

1. Figuras afins

1.1. Contravenção, Contra-ordenação ou Transgressões Administrativas?

1.1.1. Contra-ordenação

Dispõe o artigo 1.º do Regime Geral das Contra-ordenações (RGCO) «contra-ordenação como sendo todo o facto ilícito e censurável que preencha um tipo legal no qual se comine uma coima». Assim, contra-ordenação possui como «qualquer outro tipo de infracção» uma estrutura. Da conjugação do artigo 1.º com os artigos 2.º e 8.º, n.º 1, do RGCO conclui-se que constitui contra-ordenação todo o comportamento: típico, ilícito, culposo e punível. Que tem como consequência jurídica coima.

1.1.2. Transgressões Administrativas

A noção de transgressões administrativas vem prevista no artigo 3.º da Lei n.º 12/11, de 16 de Fevereiro, Lei das Transgressões Administrativas (LTA) que dispõe[109]:

[107] Celestino Bangula Quemba, Ob., Cit., p. 36.

[108] Conforme dizia CRISTO À MATEUS – *dai de César o que é de César e de Deus o que é de Deus*.

[109] Celestino Bangula Quemba, Ob., Cit., p. 43.

1. São transgressões administrativas qualquer acção ou omissão, dolosa ou negligente, punível com multa, cujo resultado perturba ou venha a perturbar o ambiente, o sossego, a ordem pública, a segurança de pessoas e bens, a higiene e saúde pública, a ornamentação e embelezamento de lugares públicos e privados, bem como a actividade administrativa das entidades públicas, não cumprindo as regras com esse fim estabelecidas.

2. Configura igualmente uma transgressão administrativa a acção ou omissão que perturba, de forma directa ou indirecta, a actividade administrativa das entidades públicas, ordenamento da vida em sociedade, através das regras previstas em leis ou regulamentos.[110] Tem como consequência jurídica coima.

1.1.3. Contravenções

O artigo 142.º do CP estabelece que constitui contravenção o facto ilícito assim denominado pela lei e punível somente com pena de multa. Tem como consequência jurídica multa.

O artigo 3.º do CP de 1886 trazia uma noção formal de contravenção dispondo que «Considera-se contravenção o facto voluntário punível que unicamente consiste na violação ou na falta de observância das disposições preventivas das leis e regulamentos, independentemente de qualquer intenção maléfica.

1.1.4. Posição dominante e regime jurídico

Das três figuras aqui analisadas, o nosso ordenamento jurídico determina, que ao lado dos crimes configura-se como infracção penal as contravenções, neste sentido a quem,

[110] O n.º 1 do artigo 5.º da mesma lei, prevê como modalidades de transgressões administrativas:
Que perturbem o sossego, a paz e a tranquilidade das pessoas;
Que ponham em perigo, de forma directa ou indirecta a saúde pública;
Que atentem contra o meio ambiente e o ordenamento do território;
Que ponham em perigo, de forma directa ou indirecta, presente ou futura, a segurança das pessoas, bens e actividade económica lícita;
Que afectem a ornamentação e o embelezamento de lugares públicos ou privados;
Que por qualquer acto ou omissão perturbem a circulação rodoviária;
Que perturbem a actividade administrativa do Estado e demais entidades no exercício de funções públicas.

em vez de fazer uma classificação tripartida como o nosso, apenas faz uma classificação bipartida.

Quanto ao regime jurídico das contravenções vem previstas no art. 142.º e ss do CP, **face a essa situação a questão que não se cala a nível da doutrina é a de saber se a CRA não fala em contravenções, qual o fundamento para se adoptar em sede do Código Penal a figura das contravenções e não as contra-ordenações?** Se são essas que estão previstas na CRA de 2010, nos termos do art. 165.º al. *t)*. **Estamos em presença de uma mera desconformidade jurídica ou de uma verdadeira inconstitucionalidade**?[111]

Por exemplo: o artigo 142.º define a *contravenção como o facto ilícito penal punível exclusivamente com multa* e, **para dar eficácia ao conceito e à figura, determina que será considerado crime todo o facto ilícito a que a lei fizer corresponder pena privativa de liberdade.** *E se o mesmo facto constituir simultaneamente crime e contravenção, o agente é punido a título de crime* (artigo 145.º), estes factos são os que vêm previstos nos artigos 302.º e ss do CP.

Conforme anota o Prof. BANGULA QUEMBA, o Código de Estrada qualifica tais infracções como sendo verdadeiras contravenções (artigos 133.º, 134.º, 135.º e 178.º código de estrada), mas na prática não obedecem ao regime das contravenções, tal como referido *supra*. As multas não são aplicadas pelo Tribunal e nem por um Juiz, aliás, isto resultam do próprio Código de Estrada[112].

Vai mais longe o mesmo autor, em dizer que, o contraventor, ainda que não pague a multa dentro dos prazos estabelecidos, remete-se ao processo em Tribunal e para reaver a documentação fica apenas com a obrigação de pagar uma «taxa» equivalente a cinquenta por cento da multa aplicada. Em matéria de infracções rodoviárias, não conhecemos nenhum caso de conversão de multa em prisão pelo seu não pagamento. Pois, sendo a contravenção uma infracção de natureza penal, o seu não pagamento pode fazer incorrer, como já ficou dito, o infractor em uma pena de prisão através da sua conversão, a luz do art. 144.º do CP.

2. Distinção entre coima e multa

[111] Celestino Bangula Quemba, Ob., Cit., p. 50.

[112] Ibidem

A coima é uma sanção aplicável a quem pratica uma contra-ordenação ou transgressão administrativa. A coima é uma sanção pecuniária. Em caso algum, a coima,[113] mesmo que não paga, se pode converter em prisão, ao contrário da multa que também é uma sanção pecuniária aplicável a quem pratica uma contravenção que pode ser convertida em prisão quando não paga, artigo 49.º do CP.

3. Distinção entre contravenção e Crime

A doutrina faz uma distinção de contravenção e crime, tendo em conta a vários critérios como sejam:

1. **Quanto ao bem jurídico:**

a) CONTRAVENÇÃO - basta a simples violação de regras leis e regulamentos. Isto significa, que nas contravenções pune-se a mera desobediência à lei, não há infracção do ponto de vista material.

b) CRIME – é necessário a violação dos bens jurídico-penal.

2. **Quando ao objecto:**

a) CONTRAVENÇÃO - existe apenas o objecto formal, isto é a lei[114].

b) CRIME - existe tanto o objecto formal, como o objecto material.

3. **Quanto a imputação**:

a) CONTRAVENÇÃO - o facto é punível independentemente do dolo.

[113] A coima é igualmente diferente da sanção civil, ela, assim como a pena, está voltada para o passado, não visa a reparação, mas a repressão.

[114] Por Exemplo – a norma que proíbe o excesso de velocidade. (se um veiculo embater contra outro e causar danos materiais e pessoas, esses danos são objecto material não da contravenção mas dos crimes de danos.)

b) CRIME - só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência.

4. **Quanto a consequência jurídica ou a sanção:**

a) **CONTRAVENÇÃO** - é punível apenas com multa.

b) **O CRIME** – é punível com penas de prisão e multa.

SECÇÃO II

CRIME

I. Evolução histórica da teoria do crime

Como nos diz o Prof. F. DIAS hoje, em matéria de dogmática jurídico-penal e construção do conceito de crime é o de que todo o direito penal é direito penal de **facto, não direito penal do agente.**

E num duplo sentido: de que toda a regulamentação jurídico-penal liga a punibilidade a tipos de factos singulares e à sua natureza, não a tipos de agentes e às características da sua personalidade; e também de que as sanções aplicadas ao agente constituem consequências daqueles factos singulares e neles se fundamentam, não sendo formas de reacção contra uma certa personalidade ou tipo de personalidade.

Desta feita, para melhor entendermos o estado actual das coisas, é fundamental estudarmos a história que está por trás da evolução da teoria da infracção.

1. A concepção “clássica” (positivista-naturalista) ou simplesmente escola clássica de Lizst e Biling

Foi fundada por LISZT, em finais do século XIX e inícios do século XX, mas tarde melhorada por BELING, fazendo uma alteração profunda na teoria geral do crime. Diz-se escola clássica por ser a primeira, todas as posteriores vêm dela.

Filosoficamente, LISZT era um positivista, o que significa que acreditava que a realidade é dada pela experiência. Os positivistas negam a metafísica e acreditam que o saber não pode ir para além da realidade. Como filósofo positivista que era, LISZT entendeu que o crime é uma realidade no mundo da experiência e os elementos que o

constituem são parte dessa realidade, devendo fazer-se uma distinção material desses elementos.

Assim, LISZT considerava haver quatro elementos do crime: **acção, ilicitude, culpa e punibilidade.**

a) Quanto à acção: LISZT adoptava um conceito naturalístico de acção, segundo o qual, a acção se traduz num movimento corporal que leva a uma transformação no mundo exterior estando este movimento e essa transformação ligados por um nexo de causalidade.

b) Quanto à ilicitude: nesta altura, a ilicitude consistia na contrariedade a uma norma jurídica e era constituída apenas pelos elementos objectivos do crime.

c) Quando à culpa: era composta pelos elementos subjectivos do crime como o dolo e a negligência, e, por isso, todos os processos anímicos e espirituais que se desenrolavam no interior do autor ao praticar o crime pertenciam à culpa.

d) Quanto à punibilidade: correspondia ao conjunto de elementos adicionais, geralmente objectivos, que permitiam distinguir determinado crime de outros actos ilícitos e culposos.

Em 1901 BELING entra em cena, fazendo uma alteração profunda na teoria geral do crime, introduz um novo elemento, **a tipicidade**. Introduziu-o com a sua monografia "teoria da infracção". Em termos gerais, vem dizer que para haver um crime é necessário que também haja uma **correspondência ou conformidade do facto praticado com a previsão da norma incriminadora.** Assim, a tipicidade é a existência de correspondência entre o facto e um tipo legal.

2. A concepção neoclássica (normativista) ou simplesmente escola neoclássica de Mezger, Eduardo Correia e Cavaleiro Ferreira

Fundada nos anos de 1930, seu principal percussor foi MEZGER. É neoclássico porque é uma continuação do sistema anterior, e não um sistema autónomo. Contudo, parte das críticas escola anterior.

A escola neoclássica é, do ponto de vista da filosofia, neokantiana, para os defensores desta escola ao contrário dos positivistas, que ao lado do mundo natural, há o mundo da

cultura, dos valores, ou seja, o direito passa a pertencer ao mundo dos valores. A ilicitude e a culpa já não são comparados pela sua distinção material, mas são considerados enquanto valores.

Em princípio não negam quanto aos elementos do crime, isto é **acção, ilicitude, culpa, punibilidade e tipicidade (tendo surgido mas tarde),** mas desconstroem por completo as posições apresentadas por LISZT.

a) Quanto à acção: deixa de ser apenas uma realidade do mundo natural passa a ser um conceito valorativo, ou seja, acção passou a ser definida como um comportamento humano voluntário socialmente relevante.

b) Quanto à tipicidade: deixa de se situar ao lado da ilicitude para se transformar no **tipo de ilícito**. Isto é, o tipo passa a ter a mera missão formal de conter os elementos da ilicitude e surge por isso como uma fundamentação positiva da ilicitude[115].

c) **Quanto à culpa:** passou a ser definida como um juízo de censura e esse juízo de censura só existiria se fosse exigível ao agente um comportamento contrário ao adoptado e se, além disso, houvesse uma motivação negativa do agente. **Ainda considerava como formas de culpa, o dolo e a negligência**. Dolo existia quando a pessoa tinha condição para se motivar pelo direito e não o fazia, enquanto a negligência era quando houvesse falta de atenção no cumprimento do dever de cuidado.

3. A concepção finalista (ontico-fenomenologica) ou Escola finalista de Welzel

[115] Por sua vez, a **ilicitude surge como um desvalor**, para além de conter elementos objectivos, passa a conter por vezes, mas só por vezes, elementos subjectivos. Nesta altura, começa a perceber-se que, para valorar um facto como furto, não bastaria a subtracção, passando ser necessário provar a intenção de apropriação.

Mezger distingue **elementos positivos** de **elementos negativos do tipo da ilicitude**. Os positivos fundamentavam o juízo de ilicitude e os negativos seriam os que agora chamamos de causas de exclusão da ilicitude. Outra distinção importante feita pela escola neoclássica, e que continua a ser feita, ainda que noutros moldes, é entre a ilicitude formal e a ilicitude material. A **ilicitude formal** ocorre sempre que houver contrariedade à norma jurídica enquanto que a **ilicitude material** surge quando há danosidade social ou ofensa material dos bens jurídicos.

Assim, **já não interessa apenas saber se o facto é ilícito ou não, e passa a ser importante a gravidade da lesão dos bens jurídicos, a medida do desvalor.**

O principal representante da escola Finalista é WELZEL. Esta escola surge a partir de 1930, determinou os caminhos da dogmática do crime, procurando naturalmente como é óbvio melhorar os elementos do crime acima propostos.

a) Quanto à acção: para a escola finalista, a acção consiste num processo causal conduzido pela vontade para determinado fim. Em suma, a acção humana é uma essência e o central dela é ser uma supra determinação final de um processo causal. A novidade aqui é que o conceito de acção passa a conter a palavra **"vontade".**

b) Quanto à tipicidade: Na escola finalista, a tipicidade surge como uma valoração autónoma da ilicitude.

Ao partir do conceito final de acção, começa-se a perceber que para afirmar que uma acção é típica temos de ter em conta os elementos subjectivos: a tipicidade passa a resultar da conjugação do tipo objectivo com o tipo subjectivo. E, portanto, nos crimes dolosos o tipo só estaria preenchido se houvesse dolo e nos crimes negligentes, o tipo só estaria preenchido com a violação do cuidado necessário. Assim o dolo e a negligência deixam de ser elementos da culpa, passando a fazer parte da tipicidade.

c) **Quanto à ilicitude:** passa a compreender dois desvalores: o desvalor da acção e o desvalor do resultado. O primeiro tem a ver com a vontade ilícita, elementos subjectivos, enquanto, que o segundo já tem a ver com o desvalor de lesão do bem jurídico. Ainda ao nível da ilicitude na escola finalista surge a chamada teoria dos tipos permissivos que estabelece que quando estes tipos se verificam se exclui a punibilidade.

d) Quanto à culpa: passa a ser é um juízo de censura pelo facto de o agente não ter agido de outra maneira.

4. Concepção pós-finalistas de Roxin, Jakobs

Dentro dos pós-finalistas, encontramos nomes tão importantes como ROXIN e JAKOBS. Actualmente, a maior parte da doutrina pode ser incluída nos pós-finalistas. Isto porque, a larga maioria da doutrina, tal como os finalistas, considera que o dolo e a negligência são elementos do tipo, não sendo possível dizer que um facto preenche materialmente o tipo de crime se não houver dolo ou negligência.

Consequentemente, a ilicitude, isto é, o tal juízo de contrariedade da acção face à norma jurídica, também só pode ser feito, tendo em conta os elementos subjectivos. Concluindo o dolo e negligência, deixam de ser apenas formas de culpa, passam a fazer parte do tipo.

- ✓ **Forma de aparecimento do crime**

Como nos diz o Prof. F. DIAS, a construção do conceito do facto punível se substitui por uma construção que em rigor, deve ser quadripartida. Significa que o crime aparece em quatro formas, como sejam: **Crimes dolosos de acção**, **Crimes negligentes de acção, Crimes dolosos de omissão** e **Crimes negligentes de omissão**[116]**,** serão devidamente descriminados nos pontos subsequentes.

CAPÍTULO II

OS FACTOS PUNÍVEIS DOLOSOS DE ACÇÃO

I. Conceito do facto punível (infracção penal)

1. Noção formal de crime

Formalmente crime ou delito é o facto voluntário declarado punível pela lei penal ou criminal.

2. Noção material de crime

Materialmente crime é todo o facto ou comportamento humano que lesa ou ameaça de lesão (põe em perigo) bens jurídicos fundamentais.

3. Noção analítica de crime

[116] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit., p. 261.

Analiticamente o crime é um facto típico, ilícito e culposo. Este é o conceito maioritariamente aceite pela doutrina.

4. Pressupostos do facto punível penal

Tal como a epígrafe indica os pressupostos do crime, são elementos pré-existentes à infracção, ou seja, são elementos sem os quais, seria impossível nascer a infracção ou até concebe-la[117]. Desta feita são pressupostos da infracção os **sujeitos e objecto do crime.**

Questão polémica que se levanta é sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Até ao código penal de 1886, prevalecia, de forma unânime, o entendimento de que apenas o ser humano, pessoa física, isoladamente ou associado a outros, tinha capacidade para delinquir. A pessoa jurídica não podia ser sujeito activo de crime, em face da máxima *societas delinquere non potest.* Assunto que será tratado em momento próprio.

4.1. Sujeitos do crime

O crime é compostos por: **sujeito activo** e **sujeito passivo**, apare dessas dois agentes, discute-se de igual modo, a posição do prejudicado diferenciando do sujeito passivo.

a) Sujeito activo

É aquele que realiza o facto descrito na norma penal incriminadora. É aquele cuja actividade é subsumível ao tipo legal incriminador.

Dito em outras palavras, o sujeito activo é todo àquele que tem capacidade para delinquir (é a pessoa que pratica o crime), este pode ser pessoa singular ou colectiva.

b) Sujeito passivo

É o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão pelo comportamento criminoso.

[117] Grandão Ramos, Ob., Cit., p.58.

Dito em outras palavras, é aquele que sofre acção levada a cabo pelo delinquente (é a pessoa que sobre o crime), este pode ser qualquer pessoa colectiva ou singular, (criança ou adulto, nascido ou em face de formação "embrião").

Os mortos, animais ou coisas inanimadas não podem ser sujeito passivo de delitos, podendo ser seu objecto material.

Pode o sujeito activo de um crime ser também seu sujeito passivo? Entende-se que não, visto que quando se define como crime condutas ofensivas à própria pessoa é porque elas lesam interesses ou bens de terceiros.

c) Sujeito passivo vs prejudicado

Por fim, impende destacar a diferença entre sujeito passivo e prejudicado, pois este (prejudicado) é qualquer pessoa a quem o crime haja causado prejuízo, pecuniário ou não, podendo ser ressarcido, enquanto, que aquele (sujeito passivo) é o titular do bem jurídico violado, que também poderá ser ressarcido.

4.2. Objecto do crime

O objecto do crime pode ser material ou jurídico.

a) Objecto material

Objectivo material são as coisas ou pessoas sobre que incide acção[118].

Quanto a nós consideramos que o objecto material é a coisa ou pessoa que é atingida pela acção delituosa, aquilo sobre o que recai a conduta. Ex$^{s.}$: coisa alheia móvel, alguém, documento. Por vezes, o sujeito passivo do delito pode se confundir com o seu objecto material, como no crime de lesões corporais. De notar-se que existem infracções que não possuem objecto substancial, como o crime de falso testemunho.

b) Objecto jurídico

Endente o Prof. GRANDÃO RAMOS, que o objecto formal do crime pode ser imediato e mediato. *Vide.* Direito Penal-apontamentos Grandão Ramos -2015. p. 59, não será este o caminho seguido por nós.

[118] Grandão Ramos, Ob., Cit., p. 59.

De forma sucinta e precisa, entende-se por objecto formal o bem e o interesse protegido pela norma penal, é o que se visa tutelar quando se erige certa conduta como infracção penal.

Ex^{s}: vida, integridade física, honra, Liberdade Sexual**,** património, etc. Foi o critério escolhido pelo legislador pátrio para dividir em capítulos a Parte Especial do CP. Não há crime sem objecto jurídico, pois, em face do princípio da lesividade, não há crime sem lesão ou perigo de lesão a bem jurídico.

5. Elementos do facto punível (infracção penal ou crime)

Os elementos do facto punível são os que compõe o conceito analítico do crime.

SECÇÃO I

ACÇÃO

I. Algumas reflexões introdutórias

Maior parte da doutrina defende que a acção é o primeiro elemento do crime. Contudo, o Prof. F. DIAS considera que o primeiro elemento do crime é a acção típica, este apresenta dois argumentos para fundamentar a sua posição.

Em primeiro lugar, conceito final de acção - direito penal só interessam as acções típicas, pelo que não faz sentido, começar pelo conceito de acção por si só. O segundo argumento de F. DIAS é que não se pode ou não se consegue chegar a um conceito geral de acção previamente ao tipo. Para este autor não é possível um conceito de acção que tenha um conteúdo material neutral e geral, em relação aos outros elementos[119].

[119] **Como se refuta estes argumentos?** Em primeiro lugar, a professora Ana Bárbara Sousa Brito considera que **é possível chegar a um conceito de acção suficientemente geral para servir de base aos restantes elementos do crime**. Por outro lado, apesar de Figueiredo Dias defender que só interessa a acção típica, é certo que, quando ele se depara com casos como o do sonâmbulo, vai buscar o conceito de acção para excluir a relevância desse comportamento e assim temos a tal função do conceito da acção. Isto é, o autor acaba por também precisar desse conceito, apesar de dizer que não interessa. A **afirmação de que ao direito penal só interessam as acções típicas não é verdadeira.**

A professora Ana Bárbara Sousa Brito considera que esta tese não deve proceder, e temos de ter sempre a acção como substrato, a base de todos os outros elementos necessários. Ao contrário do que Figueiredo Dias pensa, diz-nos que é possível chegar a um conceito de acção e que este é mesmo indispensável já

1. Funções do conceito de acção

O conceito de acção tem de cumprir fundamentalmente quatro funções. Em primeiro lugar: **função classificatória**, o conceito tem de ser um tal que assuma o carácter – o significado lógico – de conceito superior, de *genus proximus*, abrangendo todas as formas possíveis de aparecimento do comportamento punível[120].

Função delimitadora - isto é, o conceito de acção deve permitir por si só excluir todos os comportamentos irrelevantes para o direito penal. Por outras palavras, todos os comportamentos que à partida sabemos que não são relevantes para o direito penal têm de ser excluídas pelo conceito de acção. No mesmo sentido acresce F. DIAS que os acontecimentos naturais, comportamentos de animais, puros actos praticados sob *vis compulsiva*[121], não pode aceitar-se como acção relevante para o direito penal.

Função de definição - significa que o conceito de acção tem de ser um conceito com um conteúdo material, suficientemente e amplo para servir de suporte aos restantes elementos do crime. A existência de uma acção jurídico-socialmente relevante é o suporte ou o ponto de referência de todos os outros elementos e, nesse sentido, que tem de ser suficientemente amplo.

Função de elemento de ligação - significa que o conceito de acção deve ser neutral em relação aos restantes elementos do crime. Se o conceito de acção é a base de todos os outros elementos, tem de ser neutral face a estes, sob pena de se confundir face a esses outros elementos.

2. Diferentes concepções de acção

2.1. Conceito final de acção

que estabelece o limite da responsabilidade penal, daí a importância prática de saber se há ou não uma acção jurídica penalmente relevante.

[120] Jorge Figueiredo Dias, Ob., Cit., p. 251. No mesmo sentido **PROF. DOUTORA ANA BÁRBARA SOUSA BRITO,** entende que há a **função classificatória ou função de elemento básico da sistemática do crime**. Isto significa que um conceito de acção deve abarcar em si todas as formas de comportamento humano que possam ser relevantes para o direito penal.

[121] Jorge de Figueiredo Dias. Ob., Cit., p. 259.

Relativamente a esta temática, o Prof. F. DIAS, leva acabo uma tentativa de um esclarecimento das relações entre a finalidade e o dolo[122], no final do dia o estudante não chega se quer entender o que ele pretendia transmitir.

Para não nos tornamos iguais aquilo que criticamos, com a ajuda da Prof. ANA BÁRBARA SOUSA BRITO, cumpri-nos esclarecer o seguinte:

Para a escola finalista, acção é a existência de um processo causal conduzido pela vontade para atingir determinado fim.

Por isso, para haver uma acção, era preciso haver três momentos: um **primeiro momento** em que o agente antecipa mentalmente o seu objectivo; no **segundo momento** ele elege os meios necessários para prosseguir esse fim/objectivo; e no **terceiro momento** ele põe em andamento os processos causais com vista à prossecução dos fins. Não obstante a isso a escola finalística não ficou isenta de críticas[123].

2.2. Conceito social de acção

De acordo com o conceito social de acção, há uma acção sempre que houver um comportamento humano voluntário socialmente relevante.

O Prof. F. DIAS, formula uma crítica a este conceito da seguinte forma: "o que se passa com o conceito final passa-se igualmente, ao menos em parte com o conceito social de acção, isto é deixando de fora a negligência e omissão[124].

2.3. Conceito "negativo" de acção

[122] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit., 254.

[123] Primeiro, se temos de ter um terceiro momento em que o agente "põe em andamento o processo causal", **este conceito em princípio não abarca as omissões** e, por isso, deixa de fora uma realidade central do direito. Em segundo lugar, parece **não incluir as acções negligentes**, nomeadamente as acções negligentes e conscientes. Na negligência consciente, o agente prevê a realização do facto, mas não se conforma, afasta a ideia. Enquanto que na negligência inconsciente, o agente não prevê a realização do facto, mas podia prever, porque apesar de não ter representado o facto, ele tinha a possibilidade efectiva de o representar. Com base nessa possibilidade, podemos afirmar uma ligação subjectiva entre o sujeito e o facto. Se se descrever a acção jurídico-penalmente relevante desta forma, as acções negligentes dificilmente estarão aqui incluídas.

[124] Ibidem

Jakobs vem dizer que a acção surge como evitabilidade de uma diferença de resultado. O que se significa? Para Jakobs, todo o comportamento que for evitável, é uma acção jurídico-penalmente relevante e um comportamento será evitável se for conhecido ou cognoscível pelo agente. Caminha pela mesma direcção o Prof. F. DIAS. *Vide. Ob. Cit.*, p.257.

2.4. Conceito pessoal de acção

Para ROXIN, acção é a exteriorização da personalidade do agente entendida como unidade de corpo e espírito. O que é que isto quer dizer? Exteriorização significa que a conduta está sujeita ao controlo do eu, mas ROXIN diz que, além de ser esta realidade ôntica, traduz-se sempre numa valoração social.

2.5. Conceito causal da acção

De acordo com este conceito, há uma acção jurídico penalmente relevante quando houver um movimento corporal que leva a uma transformação no mundo exterior, estando este movimento e essa transformação ligados por um nexo de causalidade. Chama-se de conceito causal porque é importante saber que a causa da transformação no mundo exterior foi um movimento corporal.

2.6. Acção relevante para o direito penal

Quando falamos em conceito de acção jurídico-penalmente relevante, a maior parte da doutrina considera que, se está a pensar na acção em sentido amplo. Isto quer dizer que o conceito de acção abarca quer as **acções em sentido estrito, quer as omissões.**

Uma das grandes discussões é saber se a omissão faz ou não parte do género comportamento humano.

Para uma parte da doutrina, nomeadamente WELZEL e, entre os portugueses, JOSÉ DE SOUSA E BRITO, a omissão só faz sentido dentro do género comum à acção e omissão. Isto quer dizer que **a omissão cabe no género comportamento humano e deve ser vista como uma realidade que tem existência no mundo exterior ao lado da acção**. A professora ANA BÁRBARA SOUSA E BRITO concorda e diz-nos que para haver omissão, o agente tem de ter capacidade de agir, de adoptar uma acção alternativa.

Outra parte da doutrina, nomeadamente **MEZGER** e, entre os portugueses, **EDUARDO CORREIA,** entende que **a omissão não existe como realidade no mundo exterior e que deve ser encarada como uma negação da acção**. Isto é, para estes autores, a omissão é um produto, um juízo por parte do julgador. Dentro desta corrente há quem defenda a chamada **teoria lógica ou normativa da acção esperada,** segundo a qual a omissão continua a ser um juízo efetuado por quem julga a acção ao relacionar o que aconteceu com a conduta esperada. Por outras palavras, a omissão será um produto avaliado consoante a acção que, naquela situação, deveria ter sido tomada.

Tendo em conta as limitações objectivas do nosso estudo não cabe aqui levantar rios de tintas para dissipar esta querela. **Interessa-nos é dizer apenas que a omissão faz sim parte do género comportamento humano, isto nos termos do art. 8.º do CP.**

- ✓ **Casos práticos**

1. A e B estavam a trabalhar num andaime a 5 metros do solo quando este último, vítima de um choque eléctrico que o projectou para trás, empurrou **A** fazendo-o cair do andaime. **A** ficou gravemente ferido**. B,** emigrante brasileiro em situação ilegal, receando vir a ser descoberto, decidiu fugir do local sem prestar qualquer auxílio ao **A.**

1.1. Determine a responsabilidade criminal de **B,** na hipótese de **A** vir a falecer por não ter sido tempestivamente auxiliado.

2. Uma rapariga ficou grávida e ocultou o facto a todos. Quando sentiu as dores do parto, fechou-se no quarto da sua residência e não pediu nem aceitou a possível ajuda da sua irmã. Nascida a criança, não laqueou o cordão umbilical nem desobstruiu as vias respiratórias do recém-nascido, o que ocasionou a sua morte. *Quid iuris?*

SECÇÃO II

TIPICIDADE

I. Algumas reflexões introdutórias

A partir do momento em que se chega à conclusão de que, há uma acção jurídico-penalmente relevante, o próximo passo é averiguar se essa acção é típica.

1. Acção típica

Tipo é o modelo geral e abstracto que, da finalidade e atribuição da norma penal (é a descrição do facto criminoso feita pela lei), ou seja, determina uma conduta protege um valor ou um bem jurídico. O tipo existe para ser violado, caso contrário é irrelevante.

Afirmar que uma acção é típica significa que aquela conduta se integra, se subsume, a um determinado tipo legal de crime. É este conceito de tipo usado na análise do crime, por sua vez, é um conceito de tipo indiciário.

2. Sentido e conteúdo do tipo

Como já foi referido, no tipo indiciário, diferente do tipo essencial, o que queremos averiguar é se determinada conduta está conforme determinado tipo legal, porque abrange as circunstâncias descritas na previsão na norma.

É um tipo indiciário porque, quando está **preenchido o tipo, indicia-se a ilicitude** do comportamento. Isto porque a ilicitude se analisa pela técnica negativa da exclusão: para sabermos se é lícito ou ilícito é perceber se se verificam algumas das causas de exclusão da ilicitude. Veremos estas causas mais adiante.

Como é que um comportamento se subsume a um tipo legal de crime? Em primeiro lugar temos de ver se estão presentes os elementos objectivos e subjectivos do tipo. É claro que isto pressupõe que saibamos quais são estes elementos:

3. Elementos do tipo

3.1. Elementos objectivos

Os elementos objectivos do tipo são elementos descritivos e normativos

3.1.1. Elementos descritivos

Os elementos descritivos são os elementos que se referem à materialidade do facto, descrevem a norma penal. (ex.: matar, subtrair, violar, mulher grávida, criança, idoso, arma de fogo e etc., etc.).

3.1.2. Elementos normativos

Os elementos normativos são expressões utilizadas pela lei, com significado jurídico ou social (ex.: os conceitos de documento, cheque, justa causa, autorização, conceitos de valores, conceitos de crimes sexuais etc.)

3.2. Elementos subjectivos ou tipo subjectivo de ilícito

Como já se disse, a maior parte da doutrina defende que, na subsunção de um comportamento a um tipo, se devem verificar primeiro os elementos objectivos e só depois os elementos subjectivos. Estes por sua vez, são constituídos pelo **dolo** e pela **negligência** (art. 11.º CP).

O artigo 11.º prevê que, por regra, a lei penal exige o dolo e só excepcionalmente podemos punir a título de negligência. Isto significa que quando não temos um tipo de crime previsto na forma como negligente, não podemos punir aquele tipo de crime a título de negligência, porque se o legislador não o previr expressamente, não é possível punir aquele crime daquela forma.

3.2.1. Dolo

3.2.1.1. Noção

O dolo é o elemento subjectivo comum a todos os tipos (dolosos) e consiste na representação e vontade psicológica de realização do facto[125].

Dolo consiste no conhecimento e vontade de realização do facto típico. Ou seja, o dolo consiste no conhecimento e representação dos elementos objectivos do tipo.

3.2.1.2. Elementos do dolo

Para a maior parte da doutrina, os elementos constitutivos do dolo são dois: **elemento intelectual ou cognitivo** - que se traduz no conhecimento da realização do facto típico, e o **elemento volitivo -** que consiste na vontade de realizar o facto típico.

3.2.1.2.1. Elemento intelectual ou cognitivo

Para uma parte da doutrina, nomeadamente o Prof. F. DIAS, existe mais um elemento, designado por **elemento emocional**. Segundo este autor, para afirmar o dolo não basta que haja conhecimento das circunstâncias do facto e a vontade de o realizar, esse conhecimento está sempre acompanhado por uma consciência ética que vai permitir ao agente resolver a ilicitude do seu comportamento. Isto quer dizer que, para além, de termos de provar que o agente conhecia os elementos objectivos do facto e tinha vontade de o realizar, há que provar uma **atitude pessoal do agente contrária ao dever jurídico-penal[126].**

[125] António João Latas; Jorge Dias Duarte; Pedro Vaz Patto - *direito penal e processual penal*, Tomo I, Ed. 2007, P. 42.

[126] **A professora Ana Bárbara Sousa Brito discorda** porque considera que a atitude do agente face à ordem jurídica é um elemento comum ao dolo e à negligência e não deve ser analisado ao nível do dolo, mas ao nível da culpa. É na culpa que temos de analisar a atitude do agente face à ordem jurídica. Essa atitude pessoal face ao nosso ordenamento, provavelmente é mais forte no dolo do que na negligência, mas isso não significa que seja um elemento autónomo do dolo e da negligência, devendo ser analisado ao nível da culpa.

Porque é que o **professor Figueiredo Dias** defende este elemento emocional? Este autor **adopte um conceito de culpa diferente** daquele que nós utilizamos**.** A ideia é de que quando o agente representa e quer realizar o facto ilícito, necessariamente tem uma atitude pessoal contrária à ordem jurídica, sendo muito difícil separar esse elemento do volitivo, estão associados.

A professora Ana Bárbara Sousa Brito diz que não há dúvida que está intrinsecamente ligado, só que ao decompor o crime em elementos, estamos a separar o inseparável, analisando um comportamento humano, e quem decide os elementos do crime são os conceitos que adoptamos, embora a realidade analisada seja a mesma. Portanto, esta atitude do agente face ao ordenamento jurídico é claramente um

3.2.1.2.2. Requisitos

São três os requisitos exigíveis do elemento intelectual ou cognitivo do dolo, como sejam:

a) **Conhecimento dos elementos objectivos do tipo**

O elemento intelectual exige que o agente conheça, saiba, represente correctamente ou tenha consciência das circunstâncias do facto que preenche um tipo de ilícito objectivo. Esta representação pressupõe desde logo que o sujeito conheça os elementos essenciais da factualidade típica, os elementos objectivos do tipo.

b) **Conhecimento actual**

Em segundo lugar, essa representação, esse conhecimento tem de ser um conhecimento actual. Imaginemos que um médico sabe que determinada pessoa é alérgica a uma certa substância. Passados dez anos, essa pessoa aparece no seu hospital e, não se lembrando ele da alergia, administra-lhe a tal substância. Neste caso, a representação do agente não é actual, pelo que só será punido a título de negligência e não de dolo.

c) **Representação concreta**

Em terceiro lugar tem de ser uma representação concreta. Isto significa que, para haver dolo, não basta que o agente conte com a eventualidade de um perigo abstracto, é preciso que ele conte com a possibilidade real do perigo inerente à sua conduta. Este elemento é muito importante para distinguir das situações de erro.

II. OS ERROS EM DIREITO PENAL

Erro em direito penal traduz-se não só na discrepância entre a representação do autor e a realidade (o agente representa uma realidade quando ela não se verifica na realidade), mas também quando há falta de conhecimento da realidade.

Qual é o regime que se aplica quando acontece essa situação? **Se há erro sobre um elemento essencial, não há dolo**, **se há erro sobre um elemento não essencial há dolo**.

elemento que interessa à culpa já que esta é um juízo de censura que se faz ao agente que podendo motivar-se pelo direito, não o fez.

1. Classificação dos erros sobre os elementos do facto típico

1.1. O erro sobre a factualidade típica

O erro é tomado em sentido amplo, abrangendo tanto a representação errónea como a ausência de representação (artigo 14.º 1).

1.2. O erro sobre o processo causal

Costuma se analisar a propósito do elemento intelectual e o erro sobre o processo causal, dentro do qual se distingue se o desvio entre o processo causal pensado e o processo causal realizado é ou não essencial.

O Prof. PAITA DE CARVALHO explica-nos que há que distinguir se o processo causal é elemento do tipo legal ou não é. Tratando-se de um processo causal típico, o erro é relevante, excluindo o dolo relativamente ao respectivo crime de execução vincula, o que não se significa que não possa ser imputado ao agente o resultado a título de dolo, se entre a acção e o resultado existir uma relação de adequação e desde que, obviamente haja ao lado do crime de processo[127].

A Profª. FERNANDA PALMA dá-nos exemplos para compreendermos a diferença.

O **A** atira o **B** da ponte, pensando que este morrerá devido ao embate na água, mas na realidade morre porque bateu com a cabeça num pilar. *Quid Juris?* É um caso de **erro sobre o processo causal, em que não há um desvio essencial entre o processo causal pensado e o processo causal realizado.** O **A** vai ser punido pelo crime de homicídio doloso do **B**, porque, não havendo um desvio essencial, a representação errada do processo causal **é totalmente irrelevante**.

E se **A** atirar **B** da ponte pensando que este morre da queda, mas um tubarão salta e engole o **B** antes de ele cair na água? Este já será um caso de **erro sobre o processo causal em que há um desvio essencial, no sentido de imprevisível, entre o processo causal pensado e o processo causal realizado.** Nesta situação há uma interrupção no processo causal. Este exemplo não tem nada que ver com o dolo, mas é importante para se perceber que não se afasta o dolo. **Se houver um desvio essencial não há**

[127] Américo Paita de Carvalho, *Direito Penal-Parte Geral-Questões Fundamentais da Doutrina do Crime*, Ed. 2.º, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 323-324

imputação objectiva do resultado ao agente. O agente apenas pode ser **punido por tentativa**, já que não há conexão entre o risco criado e o resultado.

1.3. O chamado *dolus generalis*

Outra figura que não deve ser confundida com o erro é a do *dolus generalis* - é a figura que se aplica às situações em que o resultado se consuma em dois actos, mas o autor, ou o agente, previu erradamente criar o resultado apenas com a primeira acção.

A quem designa esta figura por dolo geral ou erro sucessivo – como sendo aquele em que o agente depois de pensar que já atingiu a consumação do crime, realiza uma nova acção para exaurir o delito mas é com essa nova acção que ocorre a consumação[128].

O exemplo académico é o caso do **A** que dispara sobre **B** e depois atira o corpo de **B** ao rio pensando que este estava morto, vindo-se a provar mais tarde que o **B** morreu afogado. Portanto, num primeiro momento o **A** pensa que conseguiu o resultado com a **primeira acção**, mas depois sabemos que foi só com a **segunda que o resultado efectivamente se concretizou**. Notar que o *dolus generalis* só se aplica quando a pessoa pensa que conseguiu o resultado com a primeira acção, porque se tiver dúvidas sobre isso, só pode haver negligência.

1.4. O *error in persona vel objecto*

Segundo o Prof. PAITA DE CARVALHO, verifica-se este erro, quando a identidade do objecto (pessoa ou coisa) atingido é diferente da identidade representada pelo agente.

Exemplos de escola:

Este será o caso do caçador que vai à caça com o seu amigo e a certa altura pensa que atrás da árvore está um veado, quando na realidade está o seu amigo. Nesta situação, o caçador, representa matar um veado, mas na realidade mata o amigo, pelo que não representa o objecto da acção. O que o caçador representa não é o mesmo objecto que vem previsto no tipo do **artigo 147º** e, por consequência, **exclui-se o dolo**, por força do **artigo 14º n.º 1,** em função do erro sobre os elementos essenciais do facto, mas **há a possibilidade de punir a título de negligência**, por força do n.º 3 do mesmo artigo. Portanto, o caçador seria punido por homicídio do amigo na forma negligente.

[128] Enriques Eira; Guilherme Fortes, Ob., Cit., p. 293.

Um caso diferente será o do **A** que quer matar o **B_1**, vai para a porta da casa do **B_1** e acabar por disparar sobre **B_2**, irmão gémeo do **B_1**. Aqui o agente, representa matar o **B_1**, quer matar o **B_1** e acaba por matar o **B_2**. O objecto da acção do tipo do **artigo 147.º** é uma pessoa. Se o agente, representou matar uma pessoa e matou uma pessoa, para o legislador isto basta, independentemente de ser **B_1** ou **B_2**. **Para a maior parte da doutrina, o erro sobre o objecto quando há identidade típica dos objectos é totalmente irrelevante**. O agente será punido pelo crime praticado de forma dolosa.

1.4.1. Distinção entre o erro sobre objecto e erro na execução

Na execução defeituosa, o agente quer acertar num determinado objecto, mas devido à tal execução defeituosa, seja porque não tem pontaria ou porque a vítima se desvia, acerta num objecto distinto, enquanto, que no erro sobre o objecto o agente representa um objecto e acerta nesse objecto que representa, apenas representa mal.

Imaginemos que o **A** quer acertar no **B**, mas falha a **pontaria** e acerta no **C** que estava ao lado do **B**. Neste caso, **o agente quer acertar num objecto, mas por desvio na execução acerta num objecto distinto daquele que ele queria e representou**. Não se pode confundir esta situação com o caso em que o atirador acerta no irmão gémeo daquele que queria matar por o ter confundido, porque aí seria erro no objecto já que ele representaria aquele objecto e atiraria naquele objecto e, não havendo qualquer desvio, o erro estaria na **representação** e não na **execução.**

1.5. A *aberratio ictus vel impetus*

A tradução de *aberratio ictus* é "desvio no caminho", mas esta figura também é conhecida como erro na execução ou execução defeituosa. Na *aberratio ictus* o resultado produz-se num objecto distinto do representado pelo autor. Ou seja, o agente por erro na execução da acção, atinge um objecto diferente daquele que projectou.

Segundo a doutrina maioritária; quer haja coincidência típica entre o objecto que o agente quis atingir e o objecto efectivamente atingido, quer não haja, o erro é sempre relevante. Excluindo o dolo. Assim, o agente responderá por tentativa do crime projectado em concurso com o crime consumado por negligência[129].

[129] Américo Paita de Carvalho, Ob., Cit., p. 323

Por ex.: **A** quer acertar no **B,** mas falha a pontaria e acerta no **C** que estava ao lado do B. Neste caso, o agente quer acertar num objecto, mas por desvio na execução acerta num objecto distinto daquele que ele queria e representou. Nestes termos **A** deve ser punido pela tentativa do crime que representou e punido pelo crime que realizou na forma negligente. Assim, de acordo com esta teoria, o **A** seria punido pelo homicídio tentado do **B** e pelo homicídio negligente do **C**.

Há portanto, duas acções mas tendo em conta a relação que existe entre essas acções, elas devem ser valoradas como uma só[130].

1.6. O conhecimento da proibição legal

Erro sobre a proibição legal dá-se naqueles casos em que o agente, age sem consciência da ilicitude. Pensa que sua conduta é lícita, quando na verdade está a praticar um crime. O dolo pressupõe o conhecimento da proibição. Assim, se o agente estava em erro sobre uma proibição cujo, o conhecimento era razoavelmente indispensável para que pudesse tomar conhecimento da ilicitude do facto, não há dolo, é neste sentido que o art. 15.º n.s 1 e 2, estabelece que, "exclui-se o dolo o erro quem actua sem consciência da ilicitude do facto".

[130] Quando é que se pode aplicar o *dolus generalis de modo a que* as duas ações sejam tratadas como uma só? **Há dois critérios.** O primeiro critério é o **critério de *Stratenwerth*** que nos diz **que se o agente, antes de praticar a primeira conduta, já tinha pensado e representado a segunda, o dolo abarca toda a situação num momento prévio**, isto é, o dolo abrange todo o processo causal que conduziu ao resultado, pelo que **o agente deve ser punido por um crime consumado a título de dolo.** O A seria punido pelo homicídio doloso do B. O autor acrescenta que se não for esse o caso, ou seja, **se o agente antes de praticar a primeira conduta, não pensou na segunda, então deve ser punido por tentativa do crime que representou e pelo crime que realizou na forma negligente**. Isto significa que se o A não tinha pensado em atirar o B ao rio, mas apenas em dar-lhe um tiro, vai ser punido por tentativa de homicídio (dar o tiro) e homicídio negligente (atirar ao rio).

Outro critério é o **critério de Figueiredo Dias** que vem dizer que o que importa é determinar se o risco que se concretiza no resultado pode ou não se reconduzir ao quadro dos riscos criados pela primeira conduta. Isto significa que **o que interessa é saber se, segundo as regras da experiência, era previsível, era normal, que o agente praticasse a segunda conduta.** Se a segunda é uma conduta caracteristicamente associada à primeira, posso aplicar o *dolus generalis*, se não for, não posso. Normalmente quando a pessoa dispara, quer-se desfazer do corpo, portanto dizemos que atirar ao rio está caracteristicamente associado a matar a pessoa.

3.2.1.2.2. Elemento volitivo do dolo

O elemento volitivo do dolo traduz-se na vontade de realização dos elementos objectivos do tipo, como *supra* aludido.

Dito de outro modo, o elemento volitivo do dolo corresponde à vontade do agente em praticar o facto típico.

3.2.1.3. Modalidades do dolo

O dolo pode assumir três modalidades conforme descreve o artigo 12.º, do CP, como sejam: dolo directo, dolo necessário e dolo eventual.

a) Dolo directo

Há dolo directo, dolo do primeiro grau ou dolo directo intencional - quando o agente prevê e quer a realização do facto típico como fim último da sua conduta. Note-se que a previsão não tem de ter um certo grau. Imaginemos que **A** está a uma distância considerável do **B** e aponta para o matar. Neste caso, há dolo directo. O grau não interessa, basta que preveja e queira matar o **B**.

Para sermos objectivo, há dolo directo quando o agente visa certo resultado, ou seja, o agente prevê e quer o resultado (o facto representado é o facto querido e o agente actua com a vontade de realizar esse mesmo facto).

b) Dolo necessário

Dolo necessário ou dolo de segundo grau ou dolo directo necessário é quando a realização do facto típico não surge como de grau intermédio para alcançar a finalidade última da conduta, mas como consequência necessária no sentido de inevitável da sua conduta. Por ex.: **A** quer matar **B** e põe uma bomba no avião. Ele prevê como consequência necessária da sua conduta a morte dos outros ocupantes.

Em outras palavras, realização do facto típico não é o objectivo imediato da sua conduta, mas o agente representa-a como consequência certa ou necessária da sua conduta e, portanto, quer a realização do tipo[131].

c) Dolo eventual

[131] António João Latas, Jorge Dias Duarte e Pedro Vaz Patto, Ob., Cit., p.

O dolo eventual caracteriza-se pelo facto do agente prever a realização do tipo como provável/possível e conformar-se com essa realização.

Esta figura é muito importante, porque tem semelhanças com a negligência consciente. Isto porque quer no dolo eventual quer na negligência consciente, o agente prevê a realização do facto típico como possível, com a diferença de que, no dolo eventual, esse agente prevê e conforma-se com a realização, enquanto, que na negligência consciente, ele prevê, mas não se conforma. Nas duas figuras o elemento **intelectual é o mesmo**, em ambos os casos o agente prevê como possível, o que varia é a parte **volitiva**, conformando-se ou não com a realização.

3.2.1.4. Dolo eventual vs Negligência consciente

Surgiram várias teorias para dar resposta a esta distinção.

a) Teorias intelectualistas ou da probabilidade

As teorias intelectualistas ou da probabilidade defendem que a distinção deve ser feita com **base no elemento intelectual** e defendem que no dolo o agente tem uma representação qualificada do facto típico. Para esta teoria, **há dolo eventual quando o agente prevê como provável a realização do facto típico**. Isto é, não basta que o agente preveja como possível, é preciso que veja como provável a realização do facto típico. Assim sendo, **há negligência consciente quando o agente prevê a realização do facto típico como consequência possível.** A diferença está entre o possível e o provável. Nem tudo o que é possível é provável.

b) **Teorias da vontade ou da aceitação**

No dolo eventual, o agente aprova a realização do facto típico, ele aceita intimamente a realização do facto típico, enquanto, que na negligência consciente o agente repudia a verificação do resultado, isto é, espera que o resultado não se verifique.

c) Teoria da conformação

Pelo que já se disse inicialmente, compreendemos que a teoria que a nossa ordem jurídica adopta é a **teoria da conformação,** está expressa legalmente no **artigo 12.º n.º 3** e **artigo 13.º n.º 1. do CP, s**egundo esta teoria, **no dolo eventual, o agente prevê a realização do facto típico como possível e conforma-se com a sua realização.**

Enquanto, que **na negligência consciente, o agente prevê a realização do facto típico como possível, mas não se conforma com a sua realização.** A diferença está no elemento volitivo.

Para além, das doutrinas acima referenciadas, bem como as chamadas Fórmulas de Frank[132], hoje a doutrina penal portuguesa, tem vindo a ensaiar o chamado critério da Profª. FERNANDA PALMA.

d) Critério da Profª. FERNANDA PALMA

A professora FERNANDA PALMA, tem vindo a chamar a atenção de que, a fórmula positiva de Frank pressupõe dizer que, se saiba no que é que o agente pensou. Das coisas mais difíceis em direito penal é provar o elemento subjectivo.

Assim sendo, a professora FERNANDA PALMA, acrescenta algo de novo a esta fórmula, propondo dois critérios para tentar determinar o que é que o agente pensou.

O primeiro é o critério da coerência das motivações: quanto mais forte for a motivação, maior o indício do dolo eventual. Estamos aqui a falar de possíveis benefícios que o agente possa obter com a prática do crime.

[132] **Quando é que se sabe se o agente se conformou com a realização do facto típico?** Para dar resposta a esta questão surgiram as chamadas **fórmulas de Frank.** Frank era um juiz do supremo tribunal alemão, tinha imensos casos para decidir deste género e, como tinha grandes dúvidas se seriam de dolo eventual ou de negligência consciente, criou fórmulas para encontrar o elemento subjectivo do agente.
A sua primeira fórmula, a **fórmula hipotética de Frank**, dizia que para sabermos se é um ou outro, **ficciona-se que o agente previu como certo a realização do facto típico e de seguida questiona-se se o agente ainda assim actuaria.** Se sim, há dolo eventual, se não, há negligência consciente. Esta fórmula teve de ser **afastada porque levava a resultados incorrectos**, nomeadamente no caso da organização criminosa que estropiava membros de crianças para obter esmolas. Face a este caso, importava saber se era dolo eventual ou negligência consciente e, se aplicássemos esta fórmula, diríamos que era negligência consciente porque se estes agentes soubessem que as crianças iam morrer não iam actuar já que mortas estas não serviam o objectivo da organização criminosa. Contudo, não parece de todo acertado considerar mera negligência um caso tão flagrante.
Face a isto, surgiu a **fórmula positiva de Frank** que dizia que **se o agente, ao actuar, previu como possível a realização do facto típico e pensou "aconteça o que acontecer eu atuo", há dolo eventual**. Pelo contrário, se o agente não confiar na realização do resultado, há negligência consciente. **Esta fórmula é defendida pela maior parte da doutrina e é compatível com o critério da conformação da nossa ordem jurídica.**

O segundo é o critério do grau de previsibilidade ou de probabilidade de realização do facto típico: quanto maior for o grau de previsão da realização do facto típico, maior probabilidade de termos dolo eventual. Quanto mais provável for a realização do facto típico, maior probabilidade de o agente se ter conformado com essa realização.

O exemplo que a professora FERNANDA PALMA dá é o caso da sida. Imaginemos que alguém infectado com o vírus da Sida tem relações sexuais com outra pessoa. É dolo? Se concluirmos que a transmissão do vírus era o fim da sua actividade sexual, teremos indubitavelmente dolo directo. Mas se não é este o caso e ele apenas tem consciência de que há essa possibilidade? Cientificamente, a probabilidade de transmissão situa-se entre os 0,1% e 1%, pelo que se costuma chegar à conclusão que neste caso não há dolo eventual porque a probabilidade é de tal forma baixa que não se justifica. Contudo, a professora FERNANDA PALMA acha que tendo em conta a lógica das emoções ligadas às situações, o agente deste caso tem dolo eventual. Ora, é algo estranho esta professora dar uma resposta e agora justificar desta forma, mas é assim o seu discurso.

Do exposto ficou claro que distinção entre dolo eventual e negligência consciente é tão difícil de fazer e tem uma importância prática tão relevante. Para questões de direito a constituir o que o prof. F. DIAS coloca a hipótese de no futuro ser criada uma terceira figura que se denominaria de **TEMERIDADE** e que abarcaria as situações de dolo eventual e de negligência consciente**.** Isto significaria uma transformação absoluta do sistema penal português: o dolo passaria a ter apenas duas formas, directa e indirecta, e a negligência passaria a ser apenas a inconsciente.

3.2.2. Negligência

3.2.2.1. Noção

A negligência[133] consiste na violação do dever de cuidado, em agir sem cuidado que as circunstâncias exigem e de que o agente é capaz.

Uma parte da doutrina entende que, a negligência é a ausência de precaução ou indiferença em relação ao acto realizado.

3.2.2.2. Modalidades ou forma da negligência

A negligência pode assumir três modalidades ou formas como sejam: a negligência consciente, negligência inconsciente e a negligência grosseira.

a) Negligência consciente

Há negligência consciente já aprofundamos, quando falamos sobre sua proximidade com a figura do dolo eventual. Fale lembrar que, há negligência consciente - quando o agente representa a realização do facto típico, mas não se conforma com essa realização, artigo 13º al. a) do CP.

b) Negligência inconsciente

A negligência inconsciente - é caracterizada pelo facto de o agente não prever a realização do facto típico, mas ter a possibilidade de o prever, artigo 13º b) do CP. Isto tem uma enorme dimensão prática uma vez que, leva a punição de uma pessoa que ao actuar não previu o facto típico, mas podia tê-lo previsto. Por outras palavras, na negligência inconsciente, agente não chegou a prever a possibilidade de verificação do evento ilícito (embora devesse e pudesse tê-la previsto).

c) Negligência grosseira

É uma figura praticamente nova no nosso ordenamento jurídico-penal, o legislador a descreve na parte especial do código no artigo 152.º al. b)).

[133] A negligência pode ser estudada como um elemento subjectivo do tipo, mas também pode ser estudada e vista como uma acção típica e ilícita. O professor Figueiredo Dias estuda a negligência no final do manual, como uma forma especial do surgimento do crime, em que olha para a negligência como uma acção típica ilícita. Contudo, a professora Ana Bárbara Sousa Brito considera que a negligência deve ser vista ao nível do tipo subjectivo porque é um elemento subjectivo.

Segundo o Prof. Cavaleiro de Ferreira, entende que a negligência grosseira deve corresponder a culpa temerária[134]. Revela um ilícito mais grave do que a negligência simples, ou seja, há uma violação do dever de cuidado especialmente intenso.

III. CONSTRUÇÃO OU CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS INCRIMINADORES OU AINDA TIPO DE TIPICIDADE

A construção dos tipos incriminadores não obedece um critério ou um padrão, varia de autor para autor e de ordenamento jurídico para ordenamento jurídico, quanto a nós por força do contexto histórico preferimos seguir a construção apresenta pelo Prof. F. DIAS[135].

Assim, sendo, em qualquer tipo de ilícito objectivo é a possível identificação dos tipos incriminadores com base nos seguintes critérios: **quanto ao autor, quanto a conduta, quanto ao bem jurídico, quanto à natureza dos crimes militares e grupos de tipos e figuras típicas de estrutura especial.**

1. Quanto ao autor

2.1. A questão da responsabilidade penal dos entes colectivos

Posteriormente, Malblanc, Feuerbach e Savigny, assumindo uma concepção romanista, recusaram a capacidade delitiva da pessoa jurídica, que foi consubstanciada no dogma *societas delinquere non potest*, ou seja, a pessoa jurídica não pode cometer crimes. Esse foi o juízo mais aceite até o final do século XX, ao menos nos países da família jurídica romano-germânica.

O Prof. F. DIAS, desde 1977 rejeitando os argumentos da incapacidade de acção e de culpa dos entes colectivos, vimos preconizando, sobretudo no âmbito do direito penal secundário, a legitimidade e possibilidade de sua responsabilização penal. Em sede político-criminal, se conclui pela alta conveniência ou mesmo imperiosa necessidade de responsabilização dos entes colectivos neste âmbito. Diz mais o autor não se vê razão dogmática de princípio a impedir que eles se consideram agentes possíveis dos tipos de ilícitos respectivos[136].

[134] Cavaleiro de Ferreira, *Lições de Direito Penal*, verbo, 1992, Vol. I, p. 310.

[135] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit., p. 302-321.

[136] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit., p. 298

Em 2020, o legislador angolano inspirando-se no nos códigos penais modernos, introduziram em seu sistema a responsabilidade penal da pessoa colectiva (art.º 9.º, 90.º e ss. CP).

Assim, a responsabilidade colectiva ou de grupo é tida como uma forma de incrementar a intervenção penal, especialmente nas actividades económicas. Pese embora o código não define um catálogo ou linha orientadora de que quais os crimes, deve a pessoa colectiva cometer, o código opta pelo critério do catálogo aberto, significa dizer que, as pessoas colectivas, são susceptíveis de cometerem todos os crimes previstos na parte especial do código.

Por essa razão, para a efectivação penal dos entes colectivos, não basta simplesmente o legislador consagrar a responsabilidade penal desde, é indispensável a que a doutrina e à jurisprudência dê um princípio ou critério, a menos geral de como se deve estabelecer-se para efeitos dogmáticos, teóricos e práticos a responsabilidade do ente colectivo.

1.2. Autor individual

1.2.1. Crimes comuns

Crimes comuns ou gerais – são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. Dito em outras palavras, são aqueles que não exigem, nenhuma qualidade específica do sujeito activo para sua prática. São exemplos os delitos de homicídio, de furto e de estupro.

1.2.2. Crime específico

É aquele praticado por certas pessoas, normalmente vinculadas por um dever especial ou profissional. Ou seja, são aquelas que exigem, determinada qualidade do sujeito activo para sua prática.

Estes dividem-se em, crimes específicos próprios ou puros e crimes específicos impróprios ou impuros.

a) Crime específico próprio ou puro

Crime específico próprio ou puro - é aquele que exige determinada qualidade do sujeito activo para sua prática., 357.º do CP.

São exemplos: o peculato, no qual se exige a qualidade de funcionário público (crime funcional art. 362.º do CP); o auto-aborto, que só pode ser praticado pela própria grávida art. 154.º,4 do CP; e os crimes cometidos no exercício de funções públicas e em prejuízo de funções públicas, art. 357 e ss. do CP.

b) Crime específico impróprio ou impuro

O crime específico impróprio é aquele que tem correspondência com outro crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, isto é, um crime específico impróprio é uma variante de um crime fundamental que pode ser praticado por qualquer pessoa, mas o facto de ter sido praticado por aquela pessoa agrava a responsabilidade. Se, por exemplo, houver uma violação de domicílio praticada por qualquer pessoa, a norma aplicável é o artigo 228.º do CP, mas se essa pessoa for um funcionário, já será o artigo 367.º do CP.

1.2.3. Crimes de mão própria

Os crimes de mão própria - são aqueles que só podem ser praticados na forma de autoria directa e singular. Por outras palavras, **crimes de mão própria -** o tipo exige a execução corporal do crime pela própria pessoa do agente. Expressão que se refere a crimes que apenas implicam a responsabilidade do autor material, que só pode ser praticado pelo agente que efectivamente pratica o facto. Ex.: **incesto, perjúrio e o crime de casamento fraudulento (bigamia), artigo 238.º do CP.**

1.2.4. Uni-subjectivo

Crimes singulares ou uni-subjectivos - são aqueles praticados por uma só pessoa.

1.2.5. Pluri-subjectivo

Crimes plurais ou pluri-subjectivos ou de participação necessária - são aqueles crimes praticados por mais de uma pessoa.

2. Quando a conduta

2.2. Crimes de resultado

Crimes de resultados - são aqueles em que prevê um resultado naturalístico como necessário para sua consumação.

2.3. Crimes de mera actividade ou formal

Crime formal ou de mera actividade - também chamados crimes de intenção ou de consumação antecipada. Por outras palavras, Os crimes formais - são aqueles em que não é necessário verificar-se um certo resultado, para o tipo ficar preenchido, basta que se verifique uma certa conduta. Também é denominado de delito de tipo incongruente. Ex.: é o caso da extorsão mediante sequestro e o do descaminho.

Os crimes formais opõem-se aos **crimes materiais ou de resultado** que, como o nome indica, são aqueles crimes que **pressupõem a verificação de um certo resultado para o tipo ficar preenchido.** Por outras palavras, só se dá a consumação do crime quando se verifica uma alteração externa espácio-temporalmente distinta da conduta.

2.4. Crime de execução vinculada

Crime de execução vinculada - é aquele que tem forma ou formas de realização no núcleo do tipo especificamente previstas em lei. Ex.: homicídios qualificados em razão do meio art. 148.º e importunação sexual, art, 191.º, todos do CP.

2.5. Crime de execução livre ou de forma livre

Crime de execução livre ou de forma livre - é aquele que não prevê uma forma específica de realização do núcleo do tipo. Podendo ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente como o furto simples e o homicídio simples.

3. Quanto ao bem jurídico. Crimes de dano e crimes de perigo; crimes simples (uni-ofensivos) e crimes complexos (pluri-ofensivos)

3.1. Bem jurídico e objecto da acção

Com base no bem jurídico faz-se uma distinção entre os crimes de dano ou de lesão e os crimes de perigo.

3.2. Crimes de dano

O crime de dano ou de lesão - é um crime para cuja consumação, a lei exige a efectiva lesão do bem jurídico. Para o crime de homicídio estar preenchido é preciso que haja a efectiva lesão do bem jurídico vida.

3.3. Crimes de perigo

O crime de perigo - não implica a efectiva lesão do bem jurídico, o perigo surge como fundamento da punição/punibilidade, isto é, a realização do tipo não pressupõe a lesão, mas antes se basta com a mera colocação em perigo do bem jurídico. Estes estão previstos no título IV, capítulo I artˢ. 277.º e ss. da parte especial do CP.

Dentro dos crimes de perigo é possível distinguir entre os crimes de perigo abstracto e os crimes de perigo concreto.

a) Crimes de perigo abstracto

Crime de perigo abstracto - para que o tipo esteja preenchido, basta haver uma acção adequada a produzir o perigo. Por ex.: conduzir embriagado. Neste crime, a colocação do bem em perigo não é o resultado. Basta que esse condutor seja apanhado, não é preciso que lese qualquer bem jurídico. Isto leva-nos a concluir que o perigo não é elemento do tipo, mas antes o motivo da proibição.

Como nos diz o Prof. F. DIAS, nestes tipo de crime - são tipificados certos comportamentos em nome da sua perigosidade típica para um bem jurídico, mas sem que ela necessite de ser comprovada no caso concreto. É como que uma presunção inilidível de perigo e, por isso, a conduta do agente é punida independentemente de ter criado ou não um perigo efectivo para um bem jurídico.

b) Crimes de perigo concreto

Por outro lado, o crime de perigo concreto - é aquele para cuja consumação se exige que, seja colocado em perigo determinado bem jurídico. Por outras palavras, o perigo faz parte do tipo e o tipo só está preenchido quando o bem jurídico tenha efectivamente sido posto em perigo. É o caso do crime de exposição ou abandono: se uma mãe deixa a criança à porta do orfanato, é preciso provar que a vida da criança correu efectivamente perigo para essa mãe ser punida pelo crime consumado, previsto no artigo 204.º do CP.

3.4. Crimes simples (uni-ofensivos)

Crimes simples - quando à violação apenas de um bem jurídico. Ex.: infanticídio (art. 151.º do CP) e furto - que ofende o património (art. 192.º do CP).

3.5. Crimes complexos

Crimes complexos - cujo cometimento implica a afectação de mais do que um bem jurídico. Ex.: roubo latrocínio, que atinge o património e a vida (402.º e ss. do CP).

4. Quanto à natureza dos crimes militares

Os crimes militares podem ser de dois tipos, os próprios e os impróprios:

4.1. Crime militar próprio

Crime militar próprio - é aquele que só possui tipificação no âmbito militar, como é o caso de deserção. Se um civil praticar referida conduta, haverá facto penalmente atípico.

4.2. Crime militar impróprio

Crime militar impróprio - é aquele que está previsto na legislação penal militar, mas possui tipificação também como crime não militar. Se um cidadão civil praticar a conduta, há crime; se o agente for militar, há crime previsto na legislação especial. São exemplos o furto e o homicídio

5. Grupos de tipos e figuras típicas de estrutura especial

5.1. Crimes fundamentais, qualificados e privilegiados

Crimes fundamentais - são aqueles que contém, o tipo objectivo de ilícito na sua forma mais simples, constituem, por assim, dizer, o mínimo denominador comum da forma deletiva, conformam o tipo base cujos os elementos são pressupostos nos tipos qualificados e privilegiados. São exemplos: **os homicídios** (acção de matar é o ilícito-típico fundamental) **e os furtos, roubo e coacção.** Por outras palavras, **crimes fundamentais, qualificados e privilegiados**: os que agravam a pena em função de um certo resultado que deriva do tipo principal. A sua estrutura comporta dois nexos causais: o primeiro, doloso; o segundo, negligente.

Os crimes Privilegiados – são aqueles que visam a diminuição de pena imposta a conduta do agente. Contudo, não se trata de elementos típicos, mas de causas de diminuição de pena. Ex.: tais causas privilegiadas são as seguintes: estado de intensa emoção, compaixão, desespero ou outro motivo relevante que diminua

consideravelmente a sua culpa, a pena aplicável é especialmente atenuada (artigos 163.º e 362.º n.º 3 do CP).

5.2. Crimes instantâneos

Os crimes instantâneos ou de execução instantânea – são aqueles em que a lesão do bem jurídico esgota-se num único momento. A execução ocorre por força de um único acto.

5.3. Crimes duradouros (ou permanentes)

Os crimes duradouros – são aqueles cuja consumação se protrai no tempo, isto é, se prolonga. A fase da consumação persiste enquanto desejar o agente. O sujeito activo do delito consegue prolongar no tempo a fase de consumação do delito. É o caso da extorsão mediante sequestro.

5.4. Crimes habituais

O crime habitual - é a reiteração da mesma conduta reprovável, de forma a constituir um estilo ou hábito de vida do agente.

5.5. Crime continuado

Diz-se que há crime continuado – quando a realização plúrima do mesmo tipo de crime ou de vários tipos de crime que fundamentalmente ofendam o mesmo bem jurídico, executada por forma essencialmente homogénea e no quadro da solicitação de uma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do agente (art. 29.º do CP).

5.6. Crimes de empreendimento

O crime de empreendimento – também chamado crime de atentado, são aqueles em que se verifica uma equiparação típica entre tentativa e resultado. (para estes crimes não é válida a atenuação especial da pena prevista para a tentativa, nem o facto de haver desistência).

5.7. Crimes intrauneus

Crimes intrauneus - são aqueles tipos específicos, em que a sua força constitutiva exigem qualidades especiais quer do agente quer da vítima. Ex.: O particípio.

5.8. Crimes extraneus

Crimes extraneus - são aqueles tipos comuns ou seja que não exigem qualidades quer do agente ou da vitima para os realizar, portanto podem ser cometidos por qualquer pessoa. Ex.: homicídio próprio.

5.9. Crimes agravado pelo resultado

Conforme foi já foi dito, os crimes qualificados pelo resultado - são os que agravam a pena em função de um certo resultado que deriva do tipo principal. A sua estrutura comporta dois nexos causais: o primeiro doloso e o segundo negligente.

5.9.1. O *versari in re illicita*

Princípio *versari in re illicita* ou princípio do crime agravado pelo resultado – quem pratica um ilícito, responde pelas consequências, mesmo casuais que dele promanem.

5.9.2. O crime preterintencional

O crime *preterdoloso* ou preterintencional - yé aquele em que a acção causa um resultado mais grave não pretendido pelo agente.

O sujeito quer um *minus* e a sua conduta produz um *majus*. Por outras palavras, é aquele em que resultado vai além da intenção do agente.

IV. IMPUTABILIDADE

1. Noção e classificação

Imputar significa meter na conta de alguém. O agente com a sua conduta se violar os valores ou os interesses penalmente protegido, pelos actos causados será imputado em sua conta subjectiva ou objectivamente.

I.2. Imputabilidade subjectiva

A imputabilidade subjectiva é aquela prevista no art. 11.º do CP, que consiste no dolo e na negligência, portanto já foi devidamente ultrapassada.

I.2. Imputabilidade objectiva

I.2.1. Sentido do problema

Quando temos um crime de resultado, temos de conseguir imputar objectivamente esse resultado à conduta do agente. Atenção: faz-se a imputação objectiva do resultado à conduta do agente e não da conduta ao agente.

Como é que se se pode ou não imputar objectivamente o resultado à conduta do agente? Em primeiro lugar temos de saber se aquele resultado foi causado por aquela acção. Portanto, a primeira coisa a provar se à uma relação de causa-efeito ou relação causal entre a conduta e a alteração no mundo exterior no caso o resultado. Mas, em direito penal, não basta provar a relação de causalidade, temos de ir mais longe, temos que conseguir atribuir o resultado à conduta do agente sobre o prisma de uma justa punição.

No fundo, é saber se aquele resultado pertence ao universo de resultados que a norma quer impedir com a proibição e isto implica que aquele resultado seja, em última análise, controlado ou controlável pelo agente. Notar que, não estamos a falar no controlo da acção, mas do controlo do resultado.

Para chegar a conclusão desejada e justada, em sede da imputação objectiva, faz-se recurso; a teoria da causalidade ou teoria da *conditio sine quo non*, teoria da adequação e a teoria do risco.

I.2.1.1. **Primeiro degrau: a categoria da causalidade ou teoria da *conditio sine quo non***

A teoria que vamos analisar é a teoria da *conditio sine quo non* ou teoria das condições equivalentes. Esta é a teoria mais antiga usada em direito penal, para imputar o resultado à conduta do agente.

A premissa básica desta teoria é a de que, a causa de um resultado é toda a condição, sem a qual o evento não teria tido lugar. Significa que todas as condições, que de alguma forma contribuíram para que o resultado se tivesse produzido, são causais em relação a ele e devem ser considerados equivalentes entre si, sendo apta qualquer delas a

produzir o resultado típico. Teria o juiz de suprimir mentalmente cada uma dela, até atingir a condição sem a qual o resultado não se tivesse produzido.

I.2.1.2. Segundo degrau: causalidade jurídica sob forma da teoria da adequação

Evoluindo a partir da *conditio sine qua non*, afastando diversas condições naturais ou mesmo legais de verificação do resultado, foi concebida a Teoria da adequação ou da causalidade adequada.

Esta teoria surge da necessidade de evitar injustiças derivadas da aplicação da *conditio sine qua non* aos crimes agravados pelo resultado.

Assim, não serão relevantes todas as condições, mas só aquelas que, segundo as máximas da experiência e a normalidade do acontecer – e, portanto, segundo o que é, em geral, previsível – são idóneas para produzir o resultado; assim se deve interpretar.

O legislador optou, em termos básicos, por empregar a teoria da causalidade adequada à imputação objectiva do resultado ao evento. Ou seja, aplica-se esta teoria depois de chegarmos à conclusão de que existe uma relação causal. Na realidade, é um processo de três teorias para que se possa atribuir o resultado à conduta do tipo.

A teoria da adequação sofreu vários desenvolvimentos e até mesmo correcções após a sua formulação inicial, pelo que vamos estudar apenas à última, por se apresentar mais perfeita. Segundo esta teoria, para se atribuir o resultado à conduta realiza-se através de um juízo de *prognose póstuma;* tal significa que o intérprete, ou juiz, se deve deslocar mentalmente para o passado, para o momento em que foi praticada a conduta e ponderar, enquanto observador objectivo, se, dadas as regras gerais da experiência e o normal acontecer dos factos, a acção justificada, teria como consequência a produção do evento. Se entender que a produção do resultado era imprevisível ou que, sendo previsível, era improvável ou de verificação rara, a imputação não deverá ter lugar.

Ou seja, usa-se o critério do homem médio na posição do agente e pergunta-se se lhe era previsível aquele resultado de acordo com aquele processo causal. Utiliza-se a expressão homem médio porque este homem, está munido do conhecimento das leis causais que no momento da conduta eram conhecidas. Isto é, este homem conhece as regras da experiência que naquele momento são conhecidas, mas na posição do agente.

Exemplos de escola:

A dispara sobre o **B,** mas este não morre. Vem uma ambulância para transportar o **B** para o hospital, mas antes de chegar ao hospital, há um acidente na estrada e o **B** morre por causa do desastre da ambulância. Podemos continuar a atribuir a morte do **B** ao **A**? O resultado é imputável objectivamente à conduta do **A**? Atribuir a morte é completamente diferente do que atribuir a tentativa de morte. Podemos dizer que só a tentativa é que é imputável ao **A** e a morte ao condutor da ambulância? Imaginemos ainda um outro cenário, em que o **A** dispara sobre **B**, o **B** vai para o hospital na ambulância, mas não é recebido a tempo pelos médicos, morrendo no corredor. *Quid juris?* Há alguma diferença entre a primeira hipótese e esta?**"**

Nestes casos, há uma relação causal: se tirarmos a acção daquele que deu o tiro, desaparece o resultado (teoria das condições equivalente). E segundo a teoria da adequação? É possível ao agente prever o resultado morte, mas não segundo aquele processo causal. Portanto, a teoria da adequação já resolve estes problemas, afastando a imputação objectiva por falta de preenchimento deste requisito.

Vejamos outro exemplo. Nos anos 60/70, um conjunto de mulheres grávidas que tinham certas perturbações nervosas, tomaram um medicamento que tinha talidomida, uma substância tipicamente prescrita para quem sofria dessas perturbações. Só mais tarde quando começaram a dar à luz é que se percebeu que os bebés nasciam com malformações. A dúvida que se colocou foi se se podia atribuir essas malformações ao médico que prescreveu o medicamento.

O médico médio, colocado na posição do médico que prescreveu conseguia prever aquele resultado? Não. O médico médio só está munido dos conhecimentos que existiam naquela altura em que fez a prescrição, isto é, o *ex ante.* Só depois é que se percebeu essa consequência e, portanto, não era previsível nem aquele resultado nem aquele processo causal. Aplicando a teoria das condições equivalentes havia causalidade? Sim, porque se retirasses o medicamento, não havia aquele resultado.

Contudo, apesar de existir esta relação causal, não podemos imputar o resultado à conduta do médico, pela razão exposta.

Desta forma compreendemos que **a teoria da adequação ajudou a resolver casos que não estavam a ser resolvidos correctamente** mediante a aplicação exclusiva da teoria da *condition sine qua non*. Contudo, também tem as suas falhas, uma vez que foram encontrados **quatro grupos de casos que a teoria da adequação não consegue resolver satisfatoriamente,** e foi por isso que surgiu a teoria do risco.

I.2.1.3. Terceiro degrau: a conexão do risco ou teoria do risco

De acordo com a teoria do risco, o resultado pode ser imputado à conduta do agente quando o **agente cria, aumenta ou não diminui um risco proibido** e esse risco concretiza-se no resultado, havendo uma conexão entre o risco criado e o resultado obtido.

a) Requisitos

1. Criação de um risco não permitido

Iniciando o agente, através da sua conduta, um processo lesivo do bem jurídico em apreço, que antes não se encontrava verificado ou presente no contexto fáctico e que, assim, apenas por meio da sua acção passa a existir, observa-se a criação de um perigo, sendo que "a imputação ao tipo objectivo pressupõe que, no resultado, se realize precisamente o perigo criado pelo autor.

2. Concretização de um risco não permitido no resultado típico

Sucede muitas vezes que, na situação, já está criado, antes da autuação do agente, um risco que ameaça o bem jurídico protegido. Não obstante, o resultado será ainda imputável ao agente se este, com a sua conduta, aumentou ou potenciou o risco já existente, piorando, em consequência, a situação do bem jurídico ameaçado.

3. A produção de resultados não cobertos pelo fim e âmbito de produção da norma

Ainda no âmbito dos seus requisitos necessários para a afirmação da imputação objectiva entre uma acção e um resultado, demonstra-se necessário que o evento lesivo em análise se encontre dentro do fim de protecção e incluído no âmbito da norma jurídica em apreço, ou seja, que o resultado produzido seja precisamente aquele que a norma invocada pretendia, face à política criminal existente e implantada evitar[137].

Em resumo:

Os factores dependentes da teoria a imputação pelo risco são:

i. Que o agente tenha criado um risco não permitido;
ii. Que o agente tenha aumentado ou não diminuído um risco já existente;
iii. Que esse risco tenha conduzido à produção do resultado concreto. Se tal não se verificar, a imputação é excluída.

3. A questão da causalidade virtual

Verifica-se a existência de uma causa virtual ou hipotética em relação a um resultado "quando existe um processo lesivo que produziria o resultado, se não fosse a interposição de um outro processo lesivo que efectivamente a produziu", tal como enunciado pela Prª. ANA PRATA[138].

Deste modo, a causa virtual nunca se chega a concretizar como o efectivo evento causador do resultado verificado, tendo, no entanto, de acordo com análise dos factos ocorridos, a hipotética capacidade para tal, observando-se assim um concurso de factores causais que é, na verdade, apenas virtual, e já não real, uma vez que as várias causas não se concretizam de forma conjunta ou combinada na produção material do resultado verificado[139].

4. Casos de comportamento lícito alternativo

Aos casos deste grupo temos de aplicar um critério complementar à teoria do risco. De acordo com este critério, deve-se afastar a imputação objectiva quando se demonstre que caso o agente tivesse actuado licitamente, mesmo assim o resultado ter-se-ia

[137] Inês De Ornelas Fouto Varela, *A Imputação Objetiva Em Direito Penal Alguns Problemas*, Lisboa, 2018, p. 59.

[138] Inês De Ornelas Fouto Varela, Ob., Cit., p. 64.

[139] ibidem

produzido nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar. Há exemplos académicos a considerar.

O exemplo dos pêlos de cabra é um caso verídico de um fabricante chinês de pincéis com pêlos de cabra. O produtor dos pêlos de cabra, que estava a ser julgado pelo tribunal, esqueceu-se de passar os pêlos pelo processo de desinfecção obrigatório, tendo-os entregue ao fabricante dos pincéis. Dois ou três trabalhadores, recebendo esse material, apanharam uma infecção e morreram. A dúvida era sobre se se podia atribuir aquele resultado à conduta do agente, o produtor dos pêlos. Isto porque se veio a provar que mesmo que tivesse havido o processo de desinfecção, a bactéria que matou os funcionários não teria desaparecido dos pêlos.

Assim sendo, **seria injusto punir o agente porque na realidade o seu comportamento foi irrelevante para o processo causal que conduziu ao resultado**. Notar que, neste caso também a teoria das condições equivalentes resolvia de forma satisfatória o problema uma vez que se eliminarmos a conduta do agente, o resultado se mantém nas mesmas condições de tempo, modo e lugar.

SECÇÃO III
ILICITUDE

1. Noção de ilicitude

Para concluirmos que no caso concreto foi praticado um crime, não basta provar a existência da acção e da tipicidade, é necessário que este mesmo comportamento seja ilícito.

Tal como dizia EDUARDO CORREIA o crime não é só a negação de valores, mas a negação de certos valores – os valores jurídico-criminais[140]. Em termos simples a ilicitude é contrariedade do facto com o ordenamento jurídico.

1. Causas da exclusão da ilicitude

1.1. Princípio geral das causas de justificação da ilicitude (princípio da unidade da ordem jurídica)

A verificação de uma causa de justificação tem como efeito o afastamento ou exclusão da ilicitude de um dado facto típico.

No que respeita às circunstâncias excludentes do ilícito, o artigo 30.º n.º 1, do CP, começa por definir um princípio com incidência marcante e específica na ilicitude penal. Trata-se do princípio da unidade da ordem jurídica. Segundo o qual a ilicitude penal pode ser afastada ou excluída pela ordem jurídica considerada na sua totalidade ou no seu conjunto[141]. Significa que, as causas de justificação não têm que ter natureza penal, antes podem emanar de um outro ramo do direito.

2. Elementos da causa da exclusão da ilicitude

O **artigo 30.º n.º 2, do CP,** prevê as seguintes causas de exclusão da ilicitude: (**Legítima defesa; Exercício de um direito; Cumprimento de um dever imposto por lei ou por ordem legítima de autoridade e Consentimento do titular do interesse jurídico lesado**). Ao lado destas podem ainda considerar-se outras causas da exclusão da licitude não previstas na lei penal, resultantes da ordem jurídica na sua totalidade, como sejam: (**acção directa, o direito de correcção ou o uso legítimo da coacção estatal**) e as causas de justificação supralegais. Por esta razão fala-se que enumeração

[140] Correia, Eduardo; Ob. Cit., p.273.

[141] Comentário do relatório de fundamentação do CP, p.14.

das causas que o **artigo 31.º n.º 2, do CP,** estabelece não são taxativa é simplesmente exemplificativa.

2.1. Legítima defesa

2.1.1. Noção legal

O art. 31.º al. a), do CP, descreve a legítima defesa como o facto praticado como meio necessário para repelir a agressão actual e ilícita de interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro.

2.1.2. Pressupostos

O prof. CAVALEIRO FERREIRA resolveu dividir os elementos desta figura entre pressupostos e requisitos. Os pressupostos são as condições sem as quais não se verifica a causa de justificação.

São pressupostos da legítima defesa: **agressão jurídico-penalmente relevante, agressão actual ou eminente e agressão ilícita.**

2.1.2.1. Uma agressão tem de ser, desde logo, uma acção jurídico-penalmente relevante

Agressão jurídico-penalmente relevante - significa que tem de ameaçar interesses juridicamente relevantes do agente ou de terceiro**.**

O facto de ser uma acção jurídico-penalmente relevante faz com que não seja possível a legitima defesa contra animais, contra fenómenos naturais ou contra os sonâmbulos. Ter em atenção que, se for contra um animal que está, a ser usado como meio de agressão por outra pessoa já será lícito, visto que estamos mesmo perante uma agressão humana[142].

2.1.2.2. Agressão tem de ser actual ou eminente

A agressão há-de ser, também, actual ou iminente. Agressão **actual** é aquela já está em curso quando do momento de repulsa à lesão. **Iminente** é a que está prestes a acontecer,

[142] Além dessa acção, é preciso que haja uma possibilidade efectiva de lesão do bem jurídico. Isso significa que não é possível legítima defesa se houver uma tentativa impossível, ou seja, uma tentativa que não se pode concretizar porque o objecto não existe ou o meio é inidóneo.

que ainda não se iniciou, mas que vai se iniciar a qualquer instante, não se justificando mais o retardo na repulsa àquela agressão iminentemente vindoura.

2.1.2.3. Agressão ilícita

Por último agressão tem de ser ilícita, isto significa que a acção jurídico-penalmente relevante da qual o agente se quer defender não pode estar justificada. Não podemos ter legítima defesa contra legítima defesa.

Mas não se pode confundir ilicitude com violência. Uma agressão pode ser ilícita e não ser violenta, como será o caso do **A** que vê o **B** a furtar a carteira ao **C** e o empurra. Aqui há uma agressão ilícita do **B**, e o **A** reage em legitima defesa de terceiro, mesmo que o **B** não seja violento, o **C** pode até nem se aperceber de que está a ser assaltado. Ainda há que notar que também não é necessário que a agressão seja culposa. Isto significa que pode haver legítima defesa mesmo se o agressor for inimputável.

2.1.3. Requisitos

Os requisitos são os elementos intrínsecos de uma causa de justificação que caracterizam o comportamento do agente e por isso fixam os limites à causa de justificação.

São requisitos da legítima defesa são: **meio de defesa necessário, proporcionalidade entre o bem jurídico lesado e o bem jurídico prejudicado, inexistência de provocação pré-ordenada e o *animus difendendi.***

2.1.3.1. Meio de defesa necessário

Para este requisito estar preenchido, **não pode ser possível recorrer aos dispositivos normais do Estado, porque se puder, o meio não é necessário**. Além disso, **tem de ser um meio eficaz, além de eficaz, tem de ser o menos gravoso de entre todos aqueles que o agente tiver ao seu alcance e/ou o único possível**.

É claro que é muito difícil num caso concreto chegar à conclusão que o meio utilizado foi o menos gravoso. Para isso é necessário fazer um **juízo de prognose póstuma**: colocar um homem médio na posição do agente e perguntar, se aquele era o meio menos gravoso de todos os possíveis. Esse homem médio estará munido de todos os conhecimentos que o agente tinha no momento da actuação.

Em sede desta discussão, nós perfilhamos da mesma opinião com o Prof. GERMANO M. SILVA, **o meio necessário é aquele que está disponível no momento, da agressão, s**ignifica que a avaliação da necessidade de meio, não é auferida em função da qualidade do instrumento mas sim, do resultado da sua utilização. Quer isto dizer que, o uso de arma de fogo poder-se-á mostrar menos gravoso do que o uso de uma arma branca, na medida em que aquela pode causar apenas a imobilização do agressor com uma ofensa à integridade física simples, e a arma branca pode vir a causar a morte do mesmo. **Portanto, a qualidade do instrumento não é determinante para a análise da necessidade de meio mostrando-se relevante sim, o resultado que se alcançou com o seu uso**[143].

2.1.3.2. Proporcionalidade entre o bem jurídico lesado e o bem jurídico prejudicado

Além da necessidade do meio, exige-se que haja uma proporcionalidade entre o bem jurídico lesado e o bem jurídico prejudicado, isto é, tem de haver uma proporcionalidade entre a agressão e a defesa.

Vejamos o caso do ladrão das maçãs.

Um jovem furtou maçãs do pomar do vizinho que é paraplégico. O vizinho telefonou à polícia que foi ao terreno e impediu o furto. Porém, o rapaz continuou a voltar consecutivamente ao pomar. O senhor falou com os restantes vizinhos, com os pais do jovem e até comprou um cão, mas o rapaz continuou sempre a furtar as maçãs. Esgotadas todas estas hipóteses, o vizinho disparou contra o rapaz. *Quid juris?*

O Prof. F. DIAS fala-nos noutra figura para justificar este limite da proporcionalidade. Como se disse, a legítima defesa tem como princípio fundamentador **o direito de defesa que o agente deve ter face a uma agressão ilícita**. Ora, o que este autor nos vem dizer é que esse direito de legítima defesa **é um direito subjectivo** como outro qualquer e como tal está **limitado pela figura do abuso do direito**, **artigo 334º CC**[144].

[143] Cf. SILVA, Germano Marques da - **Direito Penal Português – Parte Geral II**, Teoria do Crime – Vol II. 1ª ed. Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo, 1998. 354p. ISBN: 9789722219020. P. 95.

[144] Já para as professoras Ana Bárbara Sousa Brito e **professora Fernanda Palma,** entendem que **para exigirmos a proporcionalidade, basta recorrermos ao fundamento da legítima defesa que para ela é a dignidade da pessoa humana**. No caso do ladrão das maçãs, estaria a ser posta em causa a dignidade do ladrão. **A proporcionalidade exige que só se actue quando a lesão é insuportável**. O furto de maçãs

2.1.3.3. Inexistência de provocação pré-ordenada

A inexistência de provocação pré-ordenada, significa dizer que, se houver uma agressão que foi dirigida com o objectivo de obter do provocado uma reacção agressiva e dessa forma o provocador colocar-se na situação de defendente, não se pode considerar que haja legítima defesa.

2.1.3.4. *Animus difendendi*

O último requisito é o ***animus difendendi*** que, para a maior parte da doutrina, é composto por um elemento intelectual e um elemento volitivo. Para haver legítima defesa **é preciso provar que o agente tinha conhecimento da agressão actual e ilícita** (**elemento intelectual**) **e tinha vontade de repudiar essa agressão** (**elemento volitivo**). Este elemento não é compatível com uma motivação negativa por parte do agente que actuou em legítima defesa.

2.2. Exercício de um direito ou direito de necessidade

O direito de necessidade ou estado de necessidade também tem pressupostos e requisitos, conforme a clara o art. 32.º al. b) do CP.

2.2.1. Pressupostos

Os pressupostos são: que haja um perigo; actual, real, que ameace interesse juridicamente protegidos do agente ou de terceiro.

a) Que haja um perigo

Vimos que na legítima defesa, a causa do perigo tem de ser uma agressão humana jurídico-penalmente relevante. Contrariamente, no direito de necessidade não há essa exigência, pode ser a acção do sonâmbulo, de animais ou de um fenómeno natural. O que tem de haver é um perigo, isto é, possibilidade de dano a um bem jurídico.

não é insuportável, então o vizinho paraplégico não podia actuar daquela forma.

Imaginemos que uma pessoa vê alguém furtar o seu carro, está longe, está num sítio onde não há mais ninguém, e a única hipótese de evitar perder o carro é disparar uma arma. Perder o carro não é uma lesão insuportável, mas levar um tiro é, então não pode haver legitima defesa nesta situação.

b) Perigo actual ou iminente

Que esse perigo seja **actual ou iminente,** no sentido de que, em termos temporais, o perigo se encontra muito próximo da lesão.

c) Perigo real

O terceiro pressuposto, que o perigo seja real tem que ver com o facto de terem de se verificar certos elementos. Se não for real, é porque o agente está em erro sobre os pressupostos de facto de uma causa de exclusão da ilicitude.

d) Que ameace interesse juridicamente protegidos do agente ou de terceiro

Para além, de ser um perigo actual e real, exige é que esse ameace interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro. Novamente se diz que esta causa de justificação abrange também os perigos para bens jurídicos de outrem.

Os requisitos são:

O facto praticado ser o meio adequado para afastar o perigo, a não provocação voluntária pelo agente da situação de perigo, haver sensível superioridade do interesse a salvaguardar face ao interessa lesado, a razoabilidade da imposição do sacrifício e elemento subjectivo.

a) O facto praticado ser o meio adequado para afastar o perigo

O facto praticado ser o meio adequado para afastar o perigo, tem de responder de forma socialmente aceitável à situação.

Exemplos:

Uma decisão do supremo italiano. Um homem foi condenado em primeira instância por tentativa de crime de roubo no valor de 4,07€. Entretanto veio a provar-se que ele roubava para comer e já tinha vários antecedentes do mesmo género. O Supremo veio dizer que **este homem actuou em estado de necessidade, porque tinha necessidade de se alimentar e não tinha outra forma de o fazer**.

Outro exemplo é um caso académico. Imaginemos que uma determinada pessoa precisa de um medicamento para se salvar porque tem uma doença crónica. Esse sujeito já

tentou ter acesso ao medicamento pelos meios legais, mas não conseguiu. Se este homem for a uma farmácia e furtar o medicamento, a acção dele está ou não justificada? Este meio é socialmente adequado? **Se ele efectivamente já fez uso de todos os meios ao seu alcance e não conseguiu, ele actua em estado de necessidade**.

b) A não provocação voluntária pelo agente da situação de perigo

A maior parte da doutrina entende que, este requisito significa que quando a situação de perigo foi dolosamente criada pelo agente para o colocar numa situação de perigo e dessa forma poder actuar ao abrigo do direito de necessidade, não se pode aplicar o direito de necessidade. Este requisito é equivalente ao que vimos na legítima defesa a propósito na provocação pré-ordenada.

c) Haver sensível superioridade do interesse a salvaguardar face ao interesse lesado e a razoabilidade da imposição do sacrifício

Ainda sobre o requisito da sensível superioridade do interesse, há uma questão relevante, o princípio da igualdade entre vidas, que tem que ver com o conflito de vida contra vida. Sobre este tema, importa ter em conta a fábula do homem gordo[145].

d) **Elemento subjectivo**

Tem de a ver com o conhecimento de estado de necessidade.

[145] Imaginemos um homem gordo que está preso numa caverna com mais 11 pessoas. A única forma de escapar é através de um pequeno buraco. O homem gordo mete-se no buraco para ser o primeiro a sair, mas fica entalado. Podem as outras pessoas fazer explodir o homem gordo para conseguirem sair? Faz sentido sacrificar um para salvar os outros? Podemos dizer que não faz sentido morrerem todos só para não explodir o homem gordo que vai morrer na mesma?
Uma parte da doutrina acha que não se pode aplicar legitima defesa porque o homem gordo não agrediu ninguém, nem se pode aplicar o direito de necessidade porque não há um interesse sensivelmente superior nem é razoável impor o sacrifício, mas pode-se aplicar a figura do **estado de necessidade defensivo** que seria uma **causa de extinção supralegal híbrida: entre a legítima defesa e o direito de necessidade.** Assim sendo temos duas opções: ou consideramos esta figura híbrida e excluímos a culpa, ou consideramos que é um caso de estado de necessidade desculpante, cabendo no **artigo 36.º do CP,** que também afasta a culpa. De uma forma ou outra, a actuação dos restantes presos na caverna não seria dolosa.

2.3. Cumprimento de um dever imposto por lei ou por ordem legítima de autoridade

O pressuposto do conflito de deveres como causa de exclusão da ilicitude é a existência de um conflito no cumprimento de deveres jurídicos ou de ordens legítimas, de natureza idêntica (art. 32.º al. c) e 33.º CP).

Imaginemos que dois doentes estão com perigo idêntico de morrer e precisam os dois de ser ligados a uma máquina, mas só há uma máquina. O médico tem de escolher um. Neste caso, é claramente uma situação em que há um conflito de deveres e o cumprimento de um implica que não se possa cumprir o outro.

Contudo, o legislador exige alguns requisitos como sejam: que **seja cumprido um dever de valor igual ou superior àquele que não se cumpre, ou seja, o dever sacrificado é inferior ou igual àquele que é salvaguardado**, **bem como a cessão do dever de obediência a ordem de superior hierárquico a subordinado quando o cumprimento da ordem conduzir à prática de qualquer crime (art. 33.º n.º 2).**

2.4. Consentimento do lesado

2.4.1. Noção

Pela etimologia, o consentimento significa o acto livre e consciente do titular do bem jurídico penalmente lesado ou posto em perigo de lesão, de ser capaz em anuir ou concordar de modo inquestionável com a lesão ou perigo de lesão sobre o bem jurídico disponível do qual é único titular ou agente expressamente autorizado a dispor legalmente por ele, (art. 32.º al. d) e 34.º CP).

2.4.2. Consentimento vs acordo

Pese embora não podemos confundir consentimento e acordo tal como ensina CARLOTA VILAÇA BASTOS SILVA citando F. DIAS (na esteira de COSTA ANDRADE), o acordo, não só exclui a lesão, como faz com que a conduta corra no mesmo sentido da tutela do bem jurídico, contribuindo para uma «mais perfeita realização» deste. Segundo o entendimento de COSTA ANDRADE, uma vez que o bem jurídico protegido nestes crimes representa uma expressão da liberdade pessoal «que só

na intersubjectividade encontra a forma autêntica de actualização», o *Acordo* traduz a realização ideal desse bem, isto é, «assegura a continuidade entre a autonomia pessoal e o bem jurídico protegido e, reflexamente, a congruência entre a autonomia e o programa sistémico-social de tutela penal». Verifica-se, assim, por força do consentimento da pessoa a quem a conduta é dirigida, uma conformidade entre o comportamento e o sentido da tutela do bem jurídico – o que o torna desvalioso é a falta de vontade do titular do bem (elemento integrante do tipo)[146].

2.4.3. Pressupostos

Os pressupostos para considerar o consentimento do ofendido como uma causa de exclusão da ilicitude, são os seguintes:

a) **A existência de bens jurídicos livremente disponíveis**;
b) A **idade ser superior a 16 anos e o discernimento necessário de quem consente**;
c) **A não ofensa aos bons costumes pelo facto consentido (e não pelo próprio consentimento).**

Quanto a este último, entra muito aqui a questão da integridade física, isto é, se uma pessoa consentir que oura lhe corte o braço está a ir contra os bons costumes e por isso esse comportamento não deve ser aceite ao abrigo desta causa de exclusão da ilicitude.

Neste sentido é fundamental o artigo 165.º do CP, que apresenta como critério a irreversibilidade da lesão sendo que, à partida, sempre que resultar da actuação do agente um dano irreversível para o consentido, tem-se a acção como ilícita.

2.4.4. Requisitos

Por sua vez, esta figura exige os seguintes requisitos:

a) Que **o consentimento seja expresso por qualquer meio;**
b) Que traduza vontade séria livre e esclarecida;
c) Elemento subjectivo.

[146] Carlota Vilaça Bastos Silva, *O Consentimento Do Ofendido Na Dogmática Jurídico-Penal*, Porto, 2014, p. 13-14.

Sobre o primeiro requisito importa ter em conta o consentimento presumido, previsto pelo artigo 35.º. Esta figura apenas pode ser aplicada quando, no momento em que o agente actua, era de considerar que o lesado daria o seu consentimento, caso tivesse conhecimento do facto.

2.4.5. Modalidades do consentimento como causa de exclusão da ilicitude

2.4.5.1.1.1. Consentimento real ou eficaz

Diz-se consentimento real ou eficaz, por uma lado, aquele em que há-de traduzir numa vontade séria, livre e esclarecida do titular do interesse juridicamente protegido, por outro lado, por ser prestado por quem tiver mais 16 anos e possuir o discernimento necessário para avaliar o seu sentido e alcance no momento em que presta.

2.4.5.1.1.2. Consentimento presumido

O consentimento presumido é o que seria emitido pelo ofendido, se ele estivesse ciente das circunstâncias que agridem ou ameaçam seu direito e tivesse condições de decidir[147] (art. 35.º do CP). **A** procede a uma intervenção médica no paciente **B**, que se encontra inconsciente, sendo que o adiamento da decisão pode trazer graves consequências para a sua saúde.

C danifica a porta da casa de **D** a fim de entrar e fechar uma torneira que se encontra aberta e está a causar uma inundação.

E abre a correspondência dirigida a **F**, pois o conhecimento do seu conteúdo afigura-se urgente.

Estas situações são reconduzíveis à categoria do "consentimento presumido". Dispõe o n.º 2 do art. 35.º do CP, que "há consentimento presumido quando a situação em que o agente actua permitir razoavelmente supor que o titular do interesse juridicamente protegido teria eficazmente consentido no facto, se conhecesse as circunstâncias em que este é praticado".

[147] Sheyla Cristina da Silva Starling, *O Consentimento Do Ofendido Na Teoria Do Delito*, Belo Horizonte 2014, p. 84.

SECÇÃO IV
CULPA

1. Noção

A culpa se traduz num **juízo de censura dirigido ao agente pela prática do facto**. Esta é a grande diferença entre culpa e ilicitude: na ilicitude o juízo de desvalor recai sobre o comportamento com todos os seus elementos, objectivos e subjectivos, enquanto, que a culpa é um juízo de censura que se dirige ao agente que pratica o facto.

Porque é que se faz esse juízo de censura ao agente? **Este juízo de censura faz-se ao agente pelo facto de tendo ele a possibilidade de se determinar e motivar pelo direito, não o fez.**

A palavra **censura** está necessariamente relacionada com a moral, mas é uma moral normativa, determinada pelo direito. Por isso, em determinadas situações, apesar de o agente ter a possibilidade de se motivar pelo direito mesmo assim, não lhe era exigível que o fizesse, por razões aceites pelo directo.

2. Elementos da culpa

Para analisar a culpa. Há quem averigúe, em primeiro lugar, se estão presentes os chamados **elementos da culpa** que são: o agente ter **capacidade da culpa** (o mesmo que dizer que é imputável) e o agente ter **consciência da ilicitude** do seu acto.

2.1. Capacidade da culpa

A capacidade de culpabilidade é formada por um elemento intelectual (a compreensão do injusto do facto) e um volitivo (decidir-se de acordo com esta compreensão). Apenas a soma do conhecimento e da vontade constitui a capacidade de culpabilidade. Decerto, se falta um dos elementos, por menoridade ou por estados mentais anormais, o autor não é capaz de culpabilidade[148].

[148] Marco Aurélio Florêncio Filho, A Culpabilidade No Direito Penal: Estruturação Dogmática Das Teorias Da Culpabilidade E Os Limites Ao Poder De Punir Do Estado- Revista Académica, Vol. 86, Nº1, 2014, p. 226.

2.2. Consciência da ilicitude

A consciência de ilicitude consiste no conhecimento dos elementos objectivos e subjectivos do tipo pelo agente.

3. Causas de exclusão da culpa em sentido amplo

Tal como a ilicitude, a culpa deve ser analisada pela técnica negativa da exclusão. Isto significa que temos de averiguar se se verifica ou não alguma causa de exclusão da culpa e, se se verificar, afasta-se a culpa. Em sentido amplo temos: a **inimputabilidade** quer em razão da idade (**artigo 17.º do CP**), quer em razão da anomalia psíquica (**artigo 18.º do CP**) e o erro não censurável sobre a ilicitude (artigo 15.º n.º 1, do CP).

3.1. Inimputabilidade razão da idade

A primeira razão para um agente seja, considerado inimputável é **em razão da idade.** No **artigo 17.º do CP,** lemos que os menores de 16 anos são inimputáveis, isto significa que, só poderá ter responsabilidade criminal quem, no momento da prática do facto, tenha idade superior a 16 anos. Por outras palavras, **só a partir dos 16 anos é que o agente é susceptível de sofrer um juízo de culpa**.

3.2. Inimputabilidade razão da anomalia psíquica

A segunda inimputabilidade é **em razão de anomalia psíquica** e está prevista no **artigo 18º.,** do CP, o agente tem de sofrer uma anomalia psíquica, ou seja, tem de sofrer qualquer transtorno independentemente de ser congénito ou adquirido. Estás anomalias abrangem as psicoses, ou seja, um defeito corporal ou orgânico que pode ser exógeno ou endógeno.

Exógeno quando é provocado por intoxicações, é endógeno quando, se trata de um caso de esquizofrenia ou outras perturbações psíquicas grave. Outrossim, há os casos de **oligofrenia**, isto é, **casos de fraqueza intelectual, congénita ou não**. É o caso da **idiotia,** em que o indivíduo não atinge o desenvolvimento mental de uma criança de 6 anos, e também da **imbecilidade**, próprio de quem não atinge o desenvolvimento típico da puberdade. Cabem aqui também as chamadas **perturbações da personalidade ou**

desvios do comportamento social que não tenham fundamento orgânico corporal e aqui cabem todas as **psicopatias**, como o *borderline*[149].

Não se pode confundir a psicose com a psicopatia, contudo são ambas anomalias psíquicas. A diferença é que a psicose tem uma origem orgânica/corporal, ao passo que a psicopatia não.

3.3. Erro não censurável sobre a ilicitude

Para haver culpa, é necessário que o agente seja capaz de culpa e tenha consciência da ilicitude do seu acto. Assim, sendo, quando o agente estiver em erro sobre a ilicitude, há a possibilidade de excluir a culpa. Interessa então saber quando é que isso acontece. Há dois tipos de erro sobre a ilicitude: directo e indirecto[150].

[149] **Não basta provar que o agente tem uma anomalia psíquica, tem de se provar que** no momento da prática do facto, por força da anomalia psíquica, **o agente ou não tinha sequer capacidade para valorar o facto que estava a praticar ou,** apesar de ter capacidade de valoração, **não tinha capacidade volitiva**, isto é, de se motivar pelo direito. É isto que caracteriza o psicopata em série, o *serial killer*, já que ele sabe perfeitamente o que está a fazer, tem capacidade de valorar o mal, mas não se motiva.

Ainda quanto à anomalia psíquica, importa fazer uma distinção. Por um lado, temos os **casos em que a anomalia é provocada pelo agente sem qualquer intenção de praticar um crime** e aqui estamos a pensar nas situações em que, por exemplo, o agente toma uma droga que gera alucinações e agressividade, mas não tem qualquer intenção de praticar um crime, pelo que será considerado inimputável. Será inimputável quanto ao crime praticado (ofensas à integridade física, por exemplo), contudo poderá ser punida pelo **crime de embriaguez ou anomalia.**

Mesmo que se prove que no momento não tinha capacidade para valorar o ato, portanto era inimputável, **o que importa é o momento em que ele decide embriagar-se**. É nesse momento que importa aferir se tinha culpa ou não e nesse momento ele tinha.

A **negligência na aceitação** é uma figura próxima, mas distinta. Será o caso em que o A vai a alta velocidade ao pé de uma escola, vê o sinal de aproximação de escola, e continua a alta velocidade, acabando por atropelar uma criancinha. Mesmo que não seja imputável no momento em que atropela, o momento relevante é o anterior em que ele decide ignorar o sinal. O mesmo se diz do caso do condutor que adormece ao volante depois de já estar a conduzir há demasiadas horas.

[150] No erro directo sobre a ilicitude, o erro recai sobre proibições cujo conhecimento é dispensável à tomada da consciência da ilicitude do ato. São proibições que recaem sobre comportamento que têm já uma carga valorativa forte. São os casos previstos nos artigos 14.º e 15.º. No erro indirecto sobre a ilicitude, o agente está em erro sobre a existência de uma causa de justificação ou sobre os limites de uma causa de justificação. Aqui o que acontece é que o agente pensa que existe uma causa de exclusão de ilicitude do seu comportamento e afinal não existe. No nº2 artigo 14º lemos que também o erro sobre um estado de coisas que, a existir, excluiria a ilicitude do facto ou a culpa do agente, leva à exclusão do dolo.

4. Causas exclusão da culpa em sentido estrito

Causas de exclusão da culpa em sentido estrito são: o estado de legitima defesa desculpante (artigo 36.º do CP), Estado de necessidade desculpante (artigo 37.º do CP), Conflito de deveres desculpantes (artigo 38.º do CP). Há ainda outras causas de exclusão da culpa "típicas" em sentido estrito que resultam da ordem jurídica, nomeadamente da parte especial do código penal. Vamos analisar cada uma delas.

4.1. Estado de necessidade desculpante – artigo 36.º do CP.

O exemplo paradigmático é o da tábua de carnéades, em que estão duas pessoas em cima de uma tábua que só aguenta com uma, pelo que, para sobreviver, a pessoa mais forte atira a outra.

Verificam-se aqui todos os pressupostos do estado de necessidade desculpante exigidos pelo **artigo 32.º al. b), do CP, perigo actual que põe em perigo um bem jurídico elementar do agente**, como a vida, a integridade física, a honra ou a liberdade do agente ou de terceiro; esse **perigo não é removível de outro modo;** e **não é razoável exigir do agente que adopte outro tipo de comportamento**, o que demonstra que o direito penal não exige que as pessoas sejam heróis; por fim, também é necessário que o **agente conheça a situação de perigo.**

4.2. Estado de legítima defesa desculpante ou excesso de defesa em caso de medo, susto ou perturbação não censuráveis (artigo 36.º do CP)

Não é todo o excesso de defesa que é causa de exclusão da culpa, é só aquele que for por medo, susto ou perturbação não censurável. Entra aqui a tal questão da avaliação moral da culpa. O excesso pode ser intensivo ou extensivo. O **excesso intensivo** é quando a pessoa utiliza meios superiores aos necessários para a defesa, ou quando não há proporcionalidade entre a defesa e a ofensa. O **excesso extensivo** é quando alguém se defende de uma agressão que deixou de ser actual[151].

4.3. Conflito de deveres desculpantes (artigo 38.º do CP)

[151] Para o agente actuar ao abrigo desta causa de exclusão da culpa, **os estados emocionais que estão por trás do excesso têm de ser asténicos**, isto é, têm de resultar de uma **tensão emocional inconsciente** como o medo ou o susto. Já se falarmos no ódio, na raiva ou vingança são estados emocionais estéticos, pelo que a autuação já não será aceite pela sociedade, logo não se pode afastar a culpa.

Segundo o **artigo 38.º do CP,** ocorre uma causa de exclusão da culpa quando - **alguém cumpre uma ordem sem saber que ela conduz à prática de um crime e**, além disso, **não era evidente que essa ordem conduzia à prática de um crime.**

Imaginemos que um funcionário falsifica um documento porque o seu superior o manda, mas não é evidente que essa actuação é uma falsificação. Ele não sabe que está a praticar um crime, logo não é uma actuação culposa.

O problema da *action libera in causa*

Por outro lado, temos os casos em que o agente deliberadamente se coloca em certa posição. Será o caso de alguém que se embriaga para ter coragem de praticar um crime, consubstanciando uma acção livre na causa, prevista no artigo 18.º n.º 2. A maior parte da doutrina entende que quando o legislador prevê que a pessoa se coloque na situação com intenção de praticar o facto, exige dolo directo ou necessário quanto ao facto praticado. Portanto, nos termos deste artigo e número, a imputabilidade não é excluída quando a anomalia psíquica tiver sido provocada pelo agente com a intenção de praticar o facto.

SECÇÃO V
PUNIBILIDADE

I. Algumas reflexões introdutórias

Depois de se chegar à conclusão de há um facto típico, ilícito e culposo, por norma, esse facto também será punível. O que pode eventualmente acontecer é que, naquele caso em concreto, não se verifique uma condição de punibilidade em sentido amplo. Só nesses casos é que devemos analisar autonomamente a categoria da punibilidade.

O contrário por norma, sempre que tivermos um facto típico, ilícito e culposo, quase de certeza ele será punível. Neste sentido a punibilidade tem sido definida como consequência jurídica imposta ao agente pelo facto praticado com sua conduta. De realçar ainda que por vezes, o legislador exige certas condições de punibilidade; se exigir, há que ver se elas se verificam ou não[152].

1. Condições objectivas de punibilidade

[152] Ana Bárbara Sousa Brito., Teoria do Crime, 2018-2019, p. 120.

Condições objectivas de punibilidade, pressupõe analisar os determinados tipos de crime e para além, de ter de haver um facto típico, ilícito e culposo, o legislador exige que se verifiquem certas circunstâncias extrínsecas para que o facto possa ser punível. Essas circunstâncias nada, têm a ver com o tipo de ilícito ou o tipo de culpa**.**

Exemplo: na tentativa, para se punir, é preciso que a pena aplicável ao crime consumado seja superior a 3 anos. Esta circunstância nada, tem a ver com a ilicitude ou a culpa; é apenas uma circunstância que o legislador resolveu exigir para que a tentativa tivesse dignidade penal. Se alguém tentar um crime cuja pena não seja superior a 3 anos, essa tentativa não é digna de sofrer pena. Por isso, uma condição objectiva da punibilidade da tentativa é ao crime consumado ser aplicável uma pena superior a 3 anos.

2. O Causas de isenção da pena

Para além das condições objectivas de punibilidade, cabem nas condições de punibilidade em sentido amplo as chamadas causas pessoais de isenção ou levantamento da pena (a desistência, a tentativa, e o arrependimento activo). Estas são condições que ocorrem após a prática do facto e que impedem a sua punibilidade.

São pessoais porque só se aplicam àquela pessoa. Entretanto não iremos aqui tratar destas condições que melhor serão analisadas no ponto seguinte. Acresce o Prof. F. DIAS, que a punibilidade apresenta as seguintes categorias: dignidade penal do facto e a carência da pena - p. 672-679.

CAPÍTULO III

A PREPARAÇÃO E A TENTATIVA

SECÇÃO I

OS ESTÁDIOS DE REALIZAÇÃO DO CRIME (*ITER CRIMINIS*)

I. Algumas reflexões introdutórias

Sob a designação genérica tradicional de *formas do crime*, abordam-se as questões da tentativa, da comparticipação em sentido amplo – autoria, cumplicidade, encobrimento e do concurso de crimes. Quanto a nós seguiremos de perto as lições do Prof. F. DIAS – Penal: Tomo I-Parte Geral-Questões Fundamentais a Doutrina Geral do Crime, p- 681-687. Segundo o este autor o caminho do crime passa por quatro fases: resolução criminosa ou cogitação (*cogitatio*), actos preparatórios ou preparação criminosa

(*conatus remotus*), actos executórios (*conatus proximus*), consumação e a determinação (*meta optata*). Para outros, o exaurimento seria a última etapa.

1. Noção

Desde os momentos iniciais, quando o delito está apenas na mente do sujeito, até sua consumação, quando o crime se concretiza inteiramente, passa-se por todo um caminho, por um itinerário, composto de várias etapas ou fases — o chamado *iter criminis* (ou "caminho" do crime).

2. Fases da realização do crime (*iter criminis*)

2.1. A resolução criminosa

A resolução criminosa é a primeira fase da realização do crime - consiste na mera decisão de realização de um tipo de ilícito objectivo, independentemente de um começo de realização efectiva. Esta fase não é punível. A esta conclusão conduz o princípio indiscutido *cogitationes nemo patitur.*

Por outras palavras, A cogitação corresponde à fase puramente mental. Trata-se do **momento interno** da infracção. Só há crime na esfera psíquica, na mente do sujeito, que ainda não exteriorizou nenhum acto. Essa fase é totalmente irrelevante para o Direito Penal.

2.2. Os actos predatórios

Os actos preparatórios verificam-se quando a ideia passa da esfera mental e se materializa mediante condutas voltadas ao cometimento do crime.

O Prof. F. DIAS os divide em actos predatórios formal e actos preparatórios material.

2.2.1. Actos preparatórios formal

São aqueles que antecedem temporalmente e segundo a natureza das coisas a execução de um ilícito-típico - impõe-se logo na medida em que os actos preparatórios não se encontram, descritos ou referidos na generalidade dos tipos legais e não constituem por isso, pontos de apoio possíveis de uma responsabilidade penal. A quem chama de actos preparatórios simples- como sendo os actos do dia-a-dia e, geralmente não são puníveis (art. 19.º nº 1 e 2).

Ex.: comprar uma casadeira, comprar uma faca, comprar uma caixa de fósforo, gasolina e veneno de rato.

2.2.2. Actos preparatórios materiais

Estes definem-se em função da violação do bem jurídico, do ataque ao ordenamento social que a ordem jurídica quer prevenir. A quem em vez de dizer actos preparatórios material, acha melhor designa-lo de actos preparatórios autónomos – como sendo aqueles que de per si, constituírem crimes autónomos. Ex.: os crimes previstos no **CAPÍTULO II - Crimes de Falsificação de Moeda, Valores Selados e Títulos de Crédito**, previstos na parte especial do CP, isto é, nos artigos 255.º ao 265.º. nos do referido capítulo, quem preparar a execução dos crimes descritos capítulo *supra*, adquirindo, tendo em seu poder ou introduzindo em território angolano equipamentos ou materiais adequados e destinados ao fabrico ou à falsificação de moeda, valores selados ou títulos de crédito é punido com a pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 360 dias.

Actos preparatórios propriamente ditos (actos preparatórios como tais)

Ademais, a lei prevê em certos casos a punição dos actos preparatórios, não como crimes autónomos, mas como actos preparatórios propriamente ditos ou na linguagem do Prof. F.DIAS, actos preparatórios como tais[153] - abrangendo os actos preparatórios dos crimes previstos nos artigos 316.º a 318.º, 320.º e 321.º, 323.º, 325.º e 329.º a 331.º). No mesmo sentido diz o mesmo autor que, esta solução só se torna política-criminalmente aceitável sob dois pressupostos, que tais actos apontam já como alto grau de probabilidade para a realização do tipo de ilícito; e que se verifique a necessidade de uma intervenção penal especifica um estádio particularmente precoce do *iter criminis*[154].

Para punir os actos preparatórios enquanto tais implica por seu turno, duas perspectivas: primeiro que a tentativa dos actos preparatórios, é sempre punível, nos crimes de falsificação de moeda, valores selados e títulos de crédito, descritos no presente capítulo, conforme descreve o art. 265.º, do CP. Segundo de forma a evitar a violação do princípio *ne bis in idem,* o acto preparatório como tal punível, não deve voltar a considerar-se punível como acto preparatório autónomo[155].

[153] Jorge Figueiredo Dias, Ob., Cit., p.683.
[154] Jorge Figueiredo Dias, Ob., Cit., p.682-684.
[155] Ibidem

2.3. Fase dos actos de execução (tentativa)

Tentativa é a realização incompleta do comportamento típico de um determinado tipo de crime previsto na lei. A tentativa é de igual modo, tida como a realização dolosa parcial de um tipo de ilícito objectivo. Ela representa uma violação do ordenamento social jurídico-penalmente, relevante por meio da intranquilidade em que coloca bens jurídico-penais.

Dito de outro modo, há tentativa quando o agente praticar, com dolo, actos de execução de um crime, sem que este chegue a consumar-se, por circunstâncias alheia a sua vontade (art. 20.º CP).

2.4. A consumação e a terminação (exaurimento)

A consumação é a realização integral dos elementos do tipo de crime. Há consumação do crime quando este já está cometido, já não se trata da prática dos actos preparatórios nem de tentativa da prática do crime. Quando o agente chega à consumação alcança a meta. Se for para além, dessa meta será o exaurimento. Se ficar aquém poderá haver tentativa ou simples actos preparatórios.

F. DIAS, divide a consumação em formal e material[156].

a) Consumação formal

Verifica-se logo que o comportamento doloso preenche a totalidade do conteúdo dos elementos do tipo objectivo do ilícito.

b) Consumação material, determinação ou conclusão

Dá-se apenas com a realização completa do conteúdo do ilícito em vista do qual foi erigida a incriminação, desde que o agente tenha actuado com dolo de realizar.

SECÇÃO II

A TENTATIVA

I. Fundamento da punibilidade da tentativa

A tentativa como fase inacabada do *iter criminis* é menos grave que o crime consumado, pois, pelo menos o desvalor do resultado será sempre menor na tentativa. Por isso, a generalidade dos sistemas estabelece que a punibilidade da tentativa tem, se

[156] Jorge Figueiredo Dias, Ob., Cit., p.685.

mostrado uma das situações mas controversas na doutrina, com particular intensidade que defrontam as concepções objectivas e subjectiva do crime consumado.

1. As teorias objectivas

FEUERBACH é de opinião de que, o fundamento de punibilidade a tentativa é eminentemente objectiva. Ele definiu a tentativa como uma acção externa dirigida intencionalmente à realização do crime que deve ser objectivamente perigosa[157]. Esta teoria deve ser recusada, por força do art. 21.º n.º 1, do CP, considerando como elemento essencial da figura da tentativa a decisão de cometer um crime.

2. As teorias subjectivas

As teorias subjectivistas colocam como fundamento da punibilidade da tentativa a vontade delituosa. Tal como do resto, sucede com as concepções subjectivistas do próprio crime, o ilícito jurídico-penal considera-se constituído pela violação da norma tal, mais rigoroso, pelo comportamento através do qual o agente, vistas as coisas da sua perspectiva, viola uma norma proibida ou impositiva[158]. Esta teoria deve ser recusada, por força do art. 21.º n.º 3, do CP, pois, essa põem correctamente em evidência a imprescindibilidade, muitas hipóteses, o recurso ao plano do agente e, por aqui ao mundo das suas representações.

3. As teorias da impressão ou mista

A teoria da impressão ou intermediária rigorosamente aditiva combina os pontos de vista das duas primeiras teorias, mas introduzindo em todo o caso na controvérsia uma ideia nova que é a dignidade penal do facto tentado. Significa que, por um lado, é punível a exteriorização manifestada em contrário da norma pelo comportamento, por outro lado, a punibilidade do acto dirigido à realização do tipo só será afirmada se ele se revelar como uma intervenção significativa no ordenamento jurídico. (…[159]).

Assim, é punível nos termos do CP no art. 21.º, se ao crime consumado respectivo corresponder pena superior a 3 anos de prisão, mas especialmente atenuada (art. 21.º, nº 2 e 73.º). Uma vez que quando o agente pratica os actos de execução de um crime que

[157] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit., p. 688-689.

[158] Ibidem

[159] Jorge Figueiredo Dias, Ob., Cit., p.691.

decidiu cometer, ele já viola a norma jurídica de comportamento que está na base do ilícito consumado. A realização dolosa parcial de um tipo de ilícito objectivo já representa uma violação do ordenamento jurídico que é jurídico-penalmente relevante.

II. Os elementos da tentativa

De acordo com a noção legal de tentativa vertida no art. 20.º n.º 1, do CP, segundo o qual, só há tentativa quando o agente pratica actos de execução de um crime que decidiu cometer, sem que este chegue a consumar-se. Nos termos do mesmo artigo os actos de execução precedem a decisão do crime, e ambos são anteriores à não consumação. Significa que a tentativa é constituída por três elementos como sejam: **os actos de execução, a decisão de cometer o facto** e **não consumação** (do crime que o agente decidiu cometer).

1. A decisão de cometer o facto

A referência à decisão de cometer um crime significa que na tentativa é necessária a verificação da intenção directa e dolosa por parte do agente. Desta premissa, podem levantar-se duas questões: a primeira é a de saber se a tentativa é ou não punível a título de negligência; a segunda, a de saber se a tentativa é ou não compatível com o dolo eventual. Ambas as questões se ligam com o que já foi avançado antes numa primeira aproximação à tentativa: então referiu-se que a tentativa representa o inverso da negligência, por um lado, e que não há tentativa sem dolo, por outro. Cumpre assim avançar, mais um pouco neste específico tema das relações entre tentativa, dolo e negligência[160].

Portanto, à decisão de cometer o crime pertence a totalidade das exigências típicas subjectivas, isto é, o dolo eventualmente a negligência (art. 11.º CP). A decisão de cometer um crime não se reconduzem a um qualquer elemento externo mas antes a dados e relações pura ou predominantemente internos, como sejam: as intenções (*vide.* art. 392.º, do CP), os motivos e os impulsos afectivos, por exemplo, art. 149.º al. a) do CP), ou as características da atitude interna, art. 148.º al. d) e o art. 149.º al. a) do CP.

2. Os actos de execução

[160] Vítor de Jesus Ribas Pereira. Da punibilidade da tentativa, Coimbra, 2019, p. 59.

Consiste no início da prática de um crime que não chegou a consumar-se. Os actos de execução relevantes são os definidos nos termos do n.º 2, do art. 20.º, *a)* os que preencherem um elemento constitutivo de um tipo de crime; *b)* os que forem idóneos à produção do resultado típico; *c)* os que, segundo a experiência comum e salvo circunstâncias imprevisíveis, forem de natureza a fazer esperar que se lhe sigam actos das espécies indicadas nas alíneas anteriores.

Da redacção deste preceito percebe-se que as alíneas em referência não indicam uma alternativa de pluralidade de critérios mas devem, em conjunção umas com as outras, servir para a definição de actos de execução no caso concreto.

Portanto, os actos de execução representam as condutas do agente que exteriorizam a sua decisão de cometer o crime, e que não constituem actos preparatórios, os quais, como se viu, em regra não são puníveis.

3. A não – consumação (do crime que o agente decidiu cometer).

Consiste no não preenchimento dos elementos objectivos e subjectivos do tipo.

III. Formas da tentativa

1. Tentativa, tentativa acabada e a frustração

Na tentativa o agente não consegue, por circunstâncias alheias à sua vontade, prosseguir na execução do crime (ex.: o sujeito entra na residência da vítima e, quando começa a se apoderar dos bens, ouve um barulho que o assusta, fazendo-o fugir). Na tentativa acabada (perfeita) - o agente percorre todo o *iter criminis* que estava à sua disposição, mas, ainda assim, por circunstâncias alheias à sua vontade, não consuma o crime[161] (ex.: o sujeito descarrega a arma na vítima, que sobrevive e é socorrida a tempo por terceiros). Assim, a diferença entre estas figuras, assentará na punição, enquanto, que a punição da tentativa seria excluída pela desistência, o conceito da frustração não comportaria um tal elemento negativo[162].

2. A chamada tentativa impossível

O código penal de 2020, não usa a expressão impossível, mas sim, a expressão manifesta. Nos termos do artigo 21.º n.º 2, a tentativa diz-se manifesta quando, à

[161] Grandão Ramos, Ob., Cit., p. 189.

[162] Eduardo Correia. Ob., Cit., p. 232.

ineptidão do meio empregado pelo agente; *b)* a inexistência do objecto essencial à consumação do crime, para além, das previstas no referido artigo a doutrina acolhe uma outra figura a dita tentativa irreal ou supersticiosa.

2.1. Consequências

2.1.1. A impunibilidade da tentativa dita irreal ou supersticiosa

Tentativa supersticiosa é aquela em o agente tenta alcançar a sua finalidade delituosa através de meios sobrenaturais (ex.: rezas, feitiçarias, invocação dos deuses ou dos mortos, formulas magicas e etc.), neste termos a inaptidão do meio é absolutamente manifesta.

2.1.2. Ineptidão do meio empregado pelo agente

A inaptidão do meio consiste na falsa representação do agente, para este o meio é idóneo, mas essas representações são claramente erróneas para a generalidade das pessoas[163]. A ineficácia do meio pode ser absoluta ou relativa.

- A ineficácia ou idoneidade do meio é absoluta quando o resultado, quer em concreto, quer em absoluto nunca poderia ser atingido, com o meio usado. Por exemplo a utilização de açúcar ou farinha em vez de veneno, para cometer o crime de homicídio qualificado em razão dos meios.

- **A** idoneidade do meio é relativa quando o resultado não tinha sido atingido em concreto, ou seja o meio utilizado foi insuficiente para causar o resultado pretendido.

2.1.3. A inexistência do objecto essencial à consumação do crime

Falta ou inexistência do objecto essencial à consumação do crime — o objecto é absolutamente impróprio para a realização do crime visado. Há crime impossível, por exemplo, nas manobras abortivas em mulher que não está grávida; no disparo de arma de fogo, com *animus necandi*, em cadáver.

3. Tentativa impossível e crime putativo

Conforme foi dito a tentativa impossível, irá se verificar na medida em que existir uma idoneidade dos meios e a inexistência ou carência dos objectos, excluindo desta a forma

[163] Jorge de Figueiredo dias, Ob., Cit., p. 718.

a sua punibilidade. Ocorre o delito putativo ou imaginário, ou erroneamente suposto, quando o agente considera erroneamente que a conduta realizada por ele constitui crime, quando, na verdade, é um facto atípico. Só existe na imaginação do sujeito.

SECÇÃO III
A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA TENTATIVA

1. A desistência da tentativa inacabada: o abandono da prossecução do crime

A tentativa inacabada dá-se naqueles casos em a lei exige que o agente deixe de prosseguir a execução do crime, ou seja, o agente deve abandonar o crime (art. 22.º n.º 1), estabelece neste moldes uma ligação intrínseca com a figura da **desistência,** bem como, com a figura **tentativa dita fracassada,** segundo o qual dá-se, naquelas situações em que o agente renuncia a execução do facto e crê que a consumação já não pode ser alcançada[164].

2. A desistência da tentativa acabada: o impedimento da consumação

A desistência da tentativa acabada: o impedimento da consumação – sucede naqueles casos em a execução do delito foi levado até ao limite. Por isso não basta o abandono do plano, mas tem o agente que voluntariamente impedir a consumação, através de uma actividade própria, eventualmente com auxílio de terceiro (de um procurador, médico, polícia, ou um bombeiro). Nos termos do art. 22.º n.º 2, o agente não é punível se ele se esforçar[165] seriamente para impedir a consumação.

3. A "desistência" em caso de consumação

Toda exposição anterior foi levada a cabo na base de que a desistência só releva se o delito não tiver consumado. Se há consumação é porque não há tentativa. Segundo explica F. DIAS, que esta forma de pensar esta completamente ultrapassada. Porque a consumação, conforme escrevemos pode ser formal e material, para dizer que, na

[164] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit,. p. 737-730.

[165] Os esforços no sentido da lei, não são evidentemente meros propósitos de salvação ou sequer preocupações ou cuidados mais ou menos piedosos com a sorte do bem jurídico: eles existem apenas, na teleologia da lei, quando se passa afirmar que criaram na perspectiva do agente, uma oportunidade de salvação do bem jurídico. Não basta porém, que se tenham verificado esforços, sendo ainda indispensável que eles sejam sérios. São **sérios** quando o agente intenta levar acabo tudo aquilo que subjectivamente pensa que teria de fazer ou pode fazer para evitar a consumação.

consumação formal há sim a possibilidade de desistência, não há possibilidade da desistência nos casos de verificação da consumação material, termino ou conclusão.

4. A desistência em casos especiais

III.1. A desistência parcial

A desistência parcial dá-se naqueles casos em que o agente, já na fase da execução de um crime renuncia voluntariamente à consumação de uma circunstância qualificadora. Mas consuma o delito fundamental.

Ex.: **A** quanto tenta realizar um roubo qualificado, traz consigo uma arma, tomado de um sentimento inesperado, porém decide não usar e lança-a fora, levando todavia acabo o furto intencionado[166]. A doutrina dominante considera relevante a desistência da qualificação até à consumação do delito fundamental.

III.2. A Desistência nos crimes agravados pelo resultado

Em início de conversa, o que se pretende é saber se é ou não relevante a desistência voluntária no crime agravado pelo resultado, isto é, quando a produção do evento agravante já teve lugar, enquanto a realização do crime fundamental não ultrapassou ainda o estádio da tentativa[167].

EX.: **A** decide praticar um roubo usando uma arma de fogo que, em todo o caso, se propõe disparar unicamente, em caso de resistência, para assustar a vítima **C**, disparando para o ar e o chão. A vítima resiste e, por negligência, a arma de **A** dispara e mata **C**. face a este resultado não querido **A** abandona o processo de subtracção.

Em resposta a esta questão a jurisprudência Alemão inclina-se na admissibilidade da desistência relativamente ao crime fundamental. Para F. DIAS, tentativa é atenuada para o crime fundamental.

5. A voluntariedade da desistência

Nos termos do art. 22.º n.º 1, a desistência voluntária dá-se quando o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução do crime ou impedir a consumação ou ainda quando, não obstante a consumação, impede a verificação do resultado que a lei quer

[166] Jorge de Figueiredo Dias. Ob., Cit., p. 745.
[167] Jorge de Figueiredo Dias. Ob., Cit., p. 746.

evitar. Difere-se da tentativa, na medida em que na tentativa o agente não logra consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Na tentativa, o agente quer, mas não pode, ao passo que, na desistência voluntária o agente pode, mas não quer.

Em resumo:

Desistência e arrependimento são figuras distintas: a desistência pressupõe que tenha o agente, meios para prosseguir na execução, ou seja, ele ainda não esgotou o *iter criminis* posto à sua disposição. **Ex.:** sua arma possui outros projécteis, mas ele desiste de dispará-los.

No arrependimento eficaz: subentende-se que o sujeito já tenha esgotado todos os meios disponíveis e que, após terminar todos os actos executórios (mas sem consumar o facto), prática alguma conduta positiva, tendente a evitar a consumação. **Ex.:** o sujeito descarregou sua arma e, diante da vítima agonizando, arrepende-se e a socorre.

Conceito de arrependimento posterior: trata-se da reparação do dano causado ou da restituição da coisa subtraída nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que por acto voluntário do agente, até o recebimento da denúncia ou da queixa.

SECÇÃO IV
A COMPARTICIPAÇÃO NOS CRIMES DOLOSOS DE ACÇÃO

I. A delimitação entre autoria e participação

Em direito penal fala-se de formas de autoria e formas de participação. Há três formas de autoria: autoria imediata, autoria mediata e co-autoria. Quanto às formas de participação, há que realçar que só há participação se houver autoria. É por isso que se fala na acessoriedade da participação. Ou seja, se não houver autores, não pode haver participantes. Mas abaixo as duas figuras serão devidamente discriminadas.

1. Os modelos e as concepções básicas

As teorias abaixo subsequentes visam propor e sugerir elementos diferenciadores entre autores e participantes.

1.1. A teoria formal objectiva

A teoria formal objectiva diz que só pode ser autor, aquele que executa o facto por si mesmo. Esta teoria revela-se insuficiente porque não abarca a autoria mediata, que iremos definir.

1.2. A teoria subjectiva

A teoria subjectiva veio propor que a distinção entre autor e participante, pudesse ser feita com base no elemento subjectivo. Assim, sendo seria autor quem actuasse com *animus de auctoris*, *animus* de autor, e seria participante quem actuasse com *animus socii*, *animus* de participante. Esta teoria levou a alguns absurdos, nomeadamente o famoso caso russo em que o tribunal alemão condenou como cúmplice o espião que, a mando da URSS, matou dois conterrâneos seus na Alemanha. Segundo esta teoria, considerou-se que esse agente era apenas participante porque actuou a mando de outrem e não tinha *animus* de autor.

1.3. A teoria do "domínio do facto

Actualmente vigora a teoria do domínio do facto, encabeçada por ROXIN. De acordo com esta teoria, autor é o agente que tem o **"se"** e o **"como"** da realização do facto típico. É autor quem controla o processo causal que leva ao resultado típico e por isso, o facto surge como obra da sua vontade e, numa vertente objectiva, como fruto de uma contribuição para o acontecimento com determinado peso e significado objectivo.

Toda a doutrina está de acordo que, esta é a teoria que se aplica a todos os crimes dolosos comuns, mas depois há certa divergência acerca da aplicação aos crimes dolosos específicos ou de dever.

O Prof. F. DIAS não concorda e diz que mesmo nos crimes específicos não basta a violação do dever do titular para se falar em autoria, é necessário que haja domínio do facto.

2. As concretas formas da autoria

2.1. A autoria imediata

Na autoria imediata o autor tem domínio do facto através do domínio da acção. Isto significa que é ele próprio que executa acção (art. 24.º al. a), do CP).

2.2. A autoria mediata

Na autoria mediata o autor tem domínio do facto através do domínio da vontade. Ou seja, o autor não executa a acção, mas domina a vontade do executante. É quando o autor utiliza outrem como instrumento da sua vontade (art. 24.º al. b), do CP).

2.3. Autoria paralela

Autoria paralela sucede, naqueles casos em que duas ou mais pessoas praticam um facto típico ilícito, idóneo para produzir o evento, sem que tenha havido acordo entre eles e mesmo, sem que qualquer deles tenha conhecimento da actuação do outro.

e) Punibilidade da autoria paralela

Distingue-se da co-autoria, nesta há acordo prévio entre os agentes. Em caso de punição de autoria paralela é sempre necessário distinguir, relativamente a produção do resulta querido, se este se produziu ou não, em caso afirmativo, se foi consequência de actuação de um ou de ambos.

Se o resultado querido não se produziu os agentes respondem por tentativa, só se naquele tipo a tentativa for punível. Se entre os agentes apenas a conduta de um produziu o resultado, este é punido pelo crime consumado o restante dos agentes por tentativa (art. 27.º do CP).

2.4. O instrumento (homem-da-frente) actua atipicamente "O aliciamento"

O instrumento (homem-da-frente) actua atipicamente – sucede nos casos quando o facto é praticado por intermédio de outrem. Quando esse, outrem (o chamado **autor imediato ou autor material ou autor directo**) é utilizado como instrumento da vontade do chamado autor mediato. Como é que se obtém esse domínio da vontade? Para a maior parte da doutrina, obtém-se das seguintes formas:

- Por erro, desde que esse erro exclua o dolo ou a culpa do executor[168];

[168] Na **autoria mediata por erro o autor mediato induz o autor imediato, material ou directo em erro ou explora um erro já existente**. A e B são caçadores. A diz ao B que o que está atrás da árvore é um veado quando sabe perfeitamente que é C. Nesta situação, o A induziu o B em erro sobre os elementos do facto típico e dessa forma conseguiu dominar a sua vontade. É um caso de autoria mediata por erro. **Consequências? Exclui-se o dolo do autor material.** Assim sendo, o autor material pode ser punido

- Por coacção, e tem de ser uma coacção que exceda a culpa do executor[169];

- Por domínio da organização ou domínio da vontade no quadro de um aparelho organizado de poder; por utilização de inimputáveis[170].

3. A co-autoria

3.1. Conceito e âmbito da co-autoria

A terceira forma de autoria é a co-autoria. O Prof. F. DIAS, referiu expressamente como entre as formas de autoria, a lei terá querido afastar dúvidas que pudessem provir da

pelo crime na forma negligente, se houver preenchimento dos requisitos da negligência, enquanto que o autor mediato será punido pelo crime doloso.

Este exemplo é um caso de erro sobre o objecto, mas há outros exemplos de erro. Imaginemos que o A diz ao B para disparar contra C porque este último estaria com uma arma apontada para D, seu filho. O B dispara, mas o C não estava a apontar qualquer arma. Aqui é um erro sobre uma causa de exclusão da ilicitude porque o agente acha que está a agir em legítima defesa de terceiro. Neste caso, o A, autor mediato, vai ser punido por homicídio doloso e o B, autor directo, pode vir a ser punido por homicídio negligente.

Outro exemplo de erro é o erro sobre a ilicitude. Imaginemos uma adaptação do já referido caso da dinamarquesa que vem a Portugal, pensa fazer um aborto na 13ª semana e a sua vizinha que é advogada diz-lhe que pode abortar. Nesse caso, a dinamarquesa fez tudo o que estava ao seu alcance para conhecer as nossas normas, pelo que ao abortar, age sob erro. Assim sendo, a advogada vai ser punida pelo crime de aborto por autoria mediata porque conseguiu dominar a vontade da dinamarquesa. E a dinamarquesa não vai ser punida. Não há sequer negligência porque ela não representou nem podia representar a realização do facto típico.

[169] Na **autoria mediata por coacção que exclua a culpa do executor** (estado de necessidade desculpante) o **autor mediato consegue o domínio do facto através do domínio do elemento volitivo da decisão do autor material.** Ou seja, o autor mediato domina a formação da vontade do autor imediato, material ou directo. A aponta uma pistola à cabeça do B dizendo-lhe "ou disparas contra o C ou disparo contra ti". O B dispara. Qual é a sua responsabilidade criminal? Ele não é punido porque não tem culpa. É equivalente ao caso da tábua de Carneádes. Não se podia exigir que tivesse outro comportamento naquela situação.

Vejamos outro exemplo. A, B e C são alpinistas e estão a subir uma montanha por essa mesma ordem na vertical. O A virasse para o B e diz "ou cortas a corda ao C, ou eu cordo a corda dos dois". O B corta a corda do C. Nesse caso, o A é o autor mediato que novamente domina o elemento volitivo do autor mediato, excluindo a culpa deste.

[170] Na **autoria mediata por domínio da organização ou por fungibilidade do instrumento no âmbito de aparelhos organizados de poder,** os exemplos paradigmáticos são os casos da máfia. **São situações em que temos uma organização estruturada hierarquicamente com uma forte disciplina interna em que o modo de funcionamento dos seus elementos é quase mecânico**. Isto é, eles reagem às ordens do

circunstância, nestes casos o co-autor não domina o facto nem por si mesmo, nem por intermédio de outro (nenhum se serve do outro como instrumento), mas sim em conjunto com o outro ou outros.

Normalmente exigem-se dois elementos essenciais para que se considere uma situação como co-autoria: tem de haver execução conjunta e tem de haver uma decisão conjunta. Vamos ver cada um deles.

3.1.1. A decisão conjunta

É o elemento subjectivo – para se falar em co-autoria tem de haver um acordo em sentido amplo e esse acordo pode ser prévio, antes de se executar o facto, mas também pode ocorrer durante a execução, que são os casos de acção concertada, que implicam uma espécie de consciência recíproca de se estar a colaborar na realização do facto.

Além disso, este acordo **pode ser expresso ou tácito**. A razão da exigência deste elemento compreende-se, porque só através dele se pode justificar, quem responde pela

---

chefe porque sabem que caso não cumpram, outro praticará. A maior parte da doutrina defende que as actividades destas organizações têm de se situar fora do quadro da ordem jurídica. **Aqui não retiramos a responsabilidade ao autor material** como fizemos com o alpinista**, vamos é punir também aquele que dá a ordem**: o chefe dessa organização é o autor mediato de todos os crimes que a organização praticar.

Para o professor Figueiredo Dias, nestes casos só haverá autoria mediata se o autor imediato estiver sob coacção ou sob erro. Outra parte da doutrina, nomeadamente Roxin, defende que se o agente tiver sob erro ou coacção não a forma de autoria mediata que se utiliza não é o domínio da organização, mas o erro ou a coacção.

Passemos agora para a **autoria mediata por utilização de inimputáveis**. Pode-se ser inimputável em razão da idade ou de anomalia psíquica. Quando se utiliza inimputáveis, diz-se que o **autor mediato tem o domínio ético-social do facto.**

Contudo há uma discussão da doutrina. Há uma parte da doutrina que só considera autoria mediata nestes casos se se provar que além do domínio ético-social existe o domínio da vontade do autor imediato. Por outras palavras, **há uma parte da doutrina que considera que, para ser autoria mediata, o autor mediato também domina o elemento intelectual ou volitivo do inimputável**. Isto significa que para esta parte da doutrina se alguém utilizar um jovem para praticar um crime e se se provar que esse jovem tem capacidade para se motivar pelo direito, não há razão nenhuma para se considerar que há autoria mediata. **É por isso que o *Roxin* não autonomiza esta figura face à autoria mediata por erro ou coacção.** Se se considerar este requisito mais apertado e chegar à conclusão que não há autoria mediata, então aquele que utiliza o menor vai ser punido por instigação e passará a ser comparticipante em vez de autor.

totalidade do delito, o agente que por si levou a cabo apenas uma parte da execução típica ou todos eles? Para melhor compreensão ilustra-se o seguinte exemplo.

A e **B** combinam os dois dar uma sova em **C.** Está é a combinação. O **B** sem dizer nada ao **A** leva uma pistola e durante a sova pega na pistola e mata o **C**. *Quid juris*? Quanto à sova **A** e **B** são os dois punidos em co-autoria. E quanto à morte[171]?

3.1.2. A execução conjunta do facto

É o elemento objectivo – para haver co-autoria para além, da decisão conjunta, tem de haver também uma execução conjunta. Este segundo elemento gera várias questões. Da letra do artigo 24.º do CP, colhemos que cada um dos co-autores, tem de ter o domínio da sua parte na execução, isto é, tem de ter o domínio do seu contributo na execução.

A isto tudo importa acrescentar, como diz o Prof. F. DIAS, que o essencial é a ideia segundo a qual o princípio do domínio do facto se combina com a exigência de uma **repartição de tarefas**, que assinala a cada comparticipante contributos para o facto que, podendo situar-se fora do tipo legal de crime, tornam a execução do facto dependente daquela mesma repartição. Atentemos no exemplo de JESCHECK: quando, fruto de uma decisão conjunta, num assalto a um banco **A** fica ao volante do automóvel para permitir a fuga, **B** desliga o alarme, **C** armado assegura a saída, **D** ameaça os clientes e os empregados com uma outra arma, enquanto **E** esvazia as caixas e os cofres. Elementos típicos do roubo são preenchidos apenas por **D** e **E**, se bem que todos são co-autores: nenhum destes necessita de preencher na própria pessoa a totalidade dos elementos típicos do crime para que possa ser considerado co-autor.

3.2. A punição da co-autoria

Do exemplo *supra,* cada co-autor é punido na moldura penal prevista para o facto decidido e executado conjuntamente, tal como se houvesse cometido sozinho (art. 24.º, do CP).

II. COMPARTICIPAÇÃO CRIMINOSA

[171] Respondendo agora à questão, quanto à morte do C, o A é punido por homicídio como autor, enquanto que o B só será punido se pudesse ter previsto o excesso, mas apenas como autor paralelo a título de negligência. Aqui entra uma figura que já vimos, o conceito de autoria nos crimes negligentes que é um conceito extensivo (nos crimes negligentes é autor todo aquele que contribui causalmente para o resultado).

1. Formas de comparticipação

Como já foi referido, as formas de participação são **a instigação e a cumplicidade**. Lembrar ainda o princípio da acessoriedade da participação porque só se pode punir o participante se houver autor, isto é, só pode haver participação se houver autoria. Quanto ao encobrimento, era regulado no Código Penal de 1886 como uma forma de comparticipação no crime.

I.2. A instigação

A instigação vem prevista no art. do **artigo 24.º al. d), do CP,** sob a epígrafe de autoria, onde se lê que "é punível como autor **quem, dolosamente determinar outra pessoa à prática do facto, desde que haja execução ou começo de execução."** Ora, isto significa que vamos considerar o instigador autor?

O **professor F. DIAS** defende que **a instigação é uma forma de autoria porque o instigador possui, através do domínio da decisão, o domínio do facto**.

Porém, **a maior parte da doutrina,** entende que não é pelo facto de a figura da instigação vir prevista nesta norma que o instigador é autor porque o que esta, disposição nos diz é que, **o instigador deve ser punido como autor, mas não é autor, até porque o fundamento da punibilidade do instigador é diferente do fundamento da punibilidade do autor**. O instigador ser punido como autor é diferente de o instigador ser autor. Como já se disse, o fundamento da punibilidade do autor é ele ter o domínio do facto, ter o domínio do "**se"** e do **"como".** Ora, o instigador não tem esse domínio. O fundamento da punibilidade do instigador é ele determinar outro a praticar o crime.

I.2.1. Elementos da instigação

Normalmente a instigação divide-se em **dois elementos objectivos,** que por sua vez têm sob elementos. O primeiro é a determinação de outrem a executar dolosamente do crime e o segundo é o duplo dolo do instigador. Vejamos.

a) Determinação de outrem a executar dolosamente do crime

Que **o instigador produza, crie no executor a decisão de realizar o facto**. Isto significa que para haver instigação não basta que se influencie a decisão do executor ou

que se sugira ou reforce a decisão do executor. Na instigação, o instigador faz nascer no executor a vontade de executar o crime.

b) Duplo dolo do instigador

1. Tem de haver duplo dolo por parte do executor. Apesar de a decisão ter sido provocada pelo instigador, o executor pratica dolosamente o crime.

2. Tem de haver execução do facto, nem que seja sob a forma de tentativa. Isto porque no direito penal não se pune intenções. Ou seja, se alguém determinar outrem à prática de um crime, mas este nunca sequer iniciar a execução, não há qualquer punição, já que não há qualquer acção jurídico-penalmente relevante.

Imaginemos que o A determinou o B a matar C mediante um pagamento. O B confundiu o C e acabou por matar o D. *Quid juris?* A maior parte da doutrina defende que este erro sobre o objecto deve valer como uma ***aberratio ictus* para o homem de trás**, o instigador. O executor material vai ser punido por homicídio doloso. Quanto à morte do D, o A vai ser punido como autor paralelo por negligência.

E se o A pede ao B para matar o C a tiro, mas o B erra na pontaria e acerta no D? Aqui já será um caso de ***aberratio ictus* do executor**.

I.2. Cumplicidade

I.2.1. Noção legal de cúmplice

A outra forma de participação é a cumplicidade, que vem prevista no artigo 25.º do CP, onde lê-se no n.º 1, que "é punível como cúmplice quem, fora dos casos previstos no artigo anterior no caso o 24.º, prestar, directa e dolosamente, auxílio material ou moral à prática por outrem de um facto doloso".

I.2.2. Elementos

Exige três elementos objectivos e um subjectivos

I.2.2.1. Elementos objectivos

Contributo directo do cúmplice para facilitar ou preparar a execução; causalidade em relação ao resultado tal como se produziu; e dolo por parte do autor material.

a) Primeiro elemento objectivo

Tem de haver contributo directo do cúmplice para facilitar ou preparar a execução e esse contributo pode ser material ou moral.

- **Contributo material** - fala-se em cumplicidade material, mas não pode ser um contributo material ao ponto de tomar parte directa na execução[172].

- **Contributo moral** - fala-se em cumplicidade moral, mas não pode ser um contributo essencial ao ponto de ser determinante da vontade do executor, o que seria instigação.

b) Segundo elemento objectivo

Tem de haver causalidade em relação ao resultado, tal como se produziu, só há cumplicidade se o contributo for causal em relação ao resultado.

Exemplo:

Se o A empresta a arma, mas essa arma não é utilizada, o contributo já não é causal, logo o A não pode ser punido como cúmplice. Tem de haver uma execução ou pelo menos um começo de execução (tentativa).

c) Terceiro elemento objectivo

Tem de haver dolo por parte do autor material do executor – isto significa que, aquele que pratica o crime tem de o praticar na forma dolosa.

I.2.2.2. Elementos subjectivos

Elemento subjectivo - consiste no duplo dolo por parte do cúmplice.

a) Elemento subjectivo

[172] Um exemplo de contributo material seria o do A que empresta uma arma que vai ser utilizada num assalto que sabe que o B vai fazer. Caso interessante e de fronteira é se o A for a única pessoa capaz de fazer um mapa para chegar ao sítio do assalto porque aí discute-se se há cumplicidade material ou co-autoria. Um contributo moral seria se o B dissesse ao A que estava a pensar assaltar um banco e o A dissesse algo como “aconselho-te vivamente a realizar esse crime”.

Tem de **ter duplo dolo: dolo de auxílio e dolo quanto ao ilícito praticado – o cúmplice tem de querer contribuir para o crime e querer que o crime seja praticado**. Se o assaltante apanha um táxi para chegar ao local no assalto e nada diz ao taxista, este não pode ser punido como cúmplice porque não tem qualquer dolo de auxílio e muito menos quanto ao ilícito praticado.

I.2.3. Punibilidade na cumplicidade

A punição da cumplicidade significa sempre um alargamento da punibilidade a comportamentos que de outro modo ficariam impunes, que se fundamenta na participação do agente no facto de outrem, o autor, cuja ilicitude pressupõe nos termos no art. 26.º do CP (teoria da participação no ilícito).

– A acessoriedade exigida para a punibilidade da cumplicidade traduz-se na chamada **acessoriedade limitada (**F. DIAS), pressupõe que o facto do autor seja típico e ilícito, afastando-se assim da teoria da hiper-acessoriedade exige que o autor seja concretamente punido, bem como na chamada acessoriedade mínima, de acordo com o qual bastaria que o facto do autor fosse formalmente típico.

– Exige-se ainda que o facto do autor tenha atingido pelo menos o estádio da tentativa.

– Por outro lado, a cumplicidade só é possível enquanto o facto do autor não se encontrar consumado.

I. ENCOBRIMENTO

Nos termos dos art.ˢ a 19.º, 23.º e 24.º, do C. Penal de 1886, o encobrimento encontre-se previsto como uma forma de comparticipação em sentido amplo, admitindo, assim, de forma criticável, a comparticipação *post-factum*, esta não corresponde verdadeiramente à participarão no facto de outrem, pois quando tal participação tem lugar já o crime alheio se consumou.

1. O encobrimento no novo código penal

A generalidade dos sistemas penais modernos exclui o encobrimento do regime da comparticipação, prevendo-o na Parte Especial como infracção autónoma, os chamados (**crime de Receptação art. 435.º** e **crime de Favorecimento Pessoal art. 351.º todos do CP**).

CATÍTULO III
CRIMES NEGLIGENTES DE ACÇÃO

I. Algumas reflexões introdutórias

Tradicionalmente a dogmática jurídico-penal preocupava-se quase exclusivamente com o crime de comissão por acção dolosa. Tanto os crimes negligentes como os crimes de omissão ocupavam um papel secundário na doutrina penal.

Esta situação começou a alterar-se com a revolução industrial a partir do século XIX[173], colocando tanto os crimes negligentes como os crimes de omissão não como secundários na doutrina penal, mas como uma forma básica tipicamente cunhadas de aparecimento do crime ao mesmo nível com o crime doloso por comissão. Desta feita, entende o Prof. GRANDÃO RAMOS, que a ordem impõe a todos os cidadãos o dever de agir de maneira a não lesar, a não prejudicar os interesses penalmente tutelados[174].

1. Noção

A negligência é a ausência de precaução ou indiferença em relação ao acto realizado. Por outras palavras, a negligência consiste na violação do dever de cuidado, em agir sem o cuidado que as circunstâncias exigem e de que o agente é capaz.

Neste sentido, encontramos EDUARDO CORREIA, que, numa primeira análise, refere a negligência como a "omissão de um dever objectivo de cuidado ou diligência"[175], em seguida o autor, explica melhor a sua ideia, no sentido de ser "a omissão de um dever de cuidado, adequado a evitar a realização de um tipo legal de crime, que se traduz num dever de previsão ou de justa previsão daquela realização, e que o agente (segundo as circunstâncias concretas do caso e as suas capacidades

[173] Américo Paita de Carvalho, Ob., Cit., p. 523.

[174] Grandão Ramos, Ob., Cit., p. 164.

[175] Eduardo Correia, *Direito Criminal, Vol. I, cit.*, p. 421

pessoais) podia ter cumprido. Infelizmente recusamos essa posição, porque negligência e uma coisa e omissão é outra, ou seja, são conceitos autónomos e totalmente distintos.

Legalmente a omissão tem como regime jurídico o art. 8.º do CP, e a negligência o art. 13.º do CP, este preceito começa no seu proemio por conceber a negligência de modo unitário, para em segundo plano distinguir duas formas de negligência, que também já ficou devidamente esclarecida nos lindes deste material.

I. Elementos do ilícito negligente

Os elementos do ilícito negligente, consiste essencialmente, numa divisão em tipo de ilícito negligente e culpa negligente.

1. O tipo de ilícito negligente

1.1. O tipo de ilícito negligente como violação de um dever de cuidado

O ilícito negligente concretiza-se na violação do cuidado a que, segundo as circunstâncias o agente está obrigado, ou seja, implica a violação, por parte do agente, do cuidado que sobre ele juridicamente impende[176].

Acrescentamos, ainda, com base em TAIPA DE CARVALHO que, o ilícito negligente é formado pela acção violadora do dever objectivo de cuidado (desvalor da acção) e pela ocorrência do resultado típico (desvalor do resultado[177]). No fundo, "é necessário que o resultado possa ser objectivamente imputado à acção descuidadamente praticada.

1.2. Violação do dever de cuidado e imputação objectiva. Crimes negligentes de resultado e de mera actividade

Segundo F. DIAS, os crimes negligentes de mera actividade - consistem na violação de um dever de cuidado no sentido de o agente dever prever e evitar a violação a realização de um facto típico ilícito[178].

Ainda na perspectiva do mesmo autor, no que toca aos crimes negligentes de resultado, acentuou que a violação do dever de cuidado não é ela mesma, um puro critério da

[176] Jorge de Figueiredo Dias – *Direito Penal: Parte Geral, Tomo I*, Coimbra Editora, 2ª ed., 2007, p. 868.

[177] Américo Taipa de Carvalho, *ob.cit.*, p. 525 .

[178] Figueiredo Dias, *Direito Penal…, Tomo I, cit.*, p. 869.

imputação objectiva específico dos factos negligentes, antes sim, um momento do próprio conteúdo de toda a norma de comportamento[179].

1.3. Critérios concretizadores do cuidado devido

Quando se fala de violação de cuidado devido como elemento do tipo de ilícito negligente quer-se designar, a violação de exigências de comportamentos em geral obrigatórios cujo, o cumprimento o direito requer, na situação concreta respectiva, para evitar realizações não dolosas de um tipo objectivo de ilícito[180].

Entretanto, falar do critério concretizador do cuidado devido é saber se o dever de cuidado assume um carácter geral ou um carácter individual. A posição seguida pela doutrina lusitana aponta para o carácter geral.

1.3.1. Intervenção de critérios individualizadores do dever de cuidado

O critério definidor do tipo de ilícito negligente é um critério puramente objectivo, generalizador que não entra nunca em conta com as capacidades pessoais do agente concreto; se estas se situarem abaixo das do homem médio, nem por isso a realização do facto deixará de imputar-se à violação do dever de cuidado[181]. (…)

3.1.1. Fontes concretizadoras do dever de cuidado, sua função e alcance

3.1.2. As fontes normativas

São aquelas que derivam de leis e regulamentos, sejam elas individuas ou contidas em ordens ou prescrições da autoridade competente, digam respeito a matéria jurídica de carácter penal ou de qualquer outra natureza. Outra fonte de aferição das normas dos deveres objectivos de cuidado é constituído, pelas normas de escritas, profissionais e do trafego, correntes em certos domínios de actividade[182].

[179] Ibidem

[180] Figueiredo Dias, *Direito Penal…, Tomo I, cit.,* p. 870.

[181] Ibidem

[182] Figueiredo Dias, *Direito Penal…, Tomo I, cit.,* p. 876

3.1.3. A função indiciária

A violação das normas de cuidado constitui por excelência um indício de uma contrariedade ao dever de cuidado tipicamente relevante, mas não pode em caso algum fundamenta-la que definitivamente provenha ela de uma norma jurídica ou de norma escrita não jurídica ou da aplicação do critério da figura padrão.

4. O tipo de culpa negligente

4.1. Noção

O tipo de culpa negligente - pode definir-se como a atitude ético-pessoal de descuidado ou leviandade do agente face ao bem jurídico lesado ou posto em perigo pela acção praticada sem o cuidado exigível[183].

4.2. Pressupostos da culpa negligente

Como pressupostos específicos da culpa negligente temos: a previsibilidade objectiva, previsibilidade subjectiva o Prof. F. DIAS chama de capacidade pessoais.

4.2.1. Previsibilidade subjectiva (capacidade pessoais)

Previsibilidade subjectiva, significa a possibilidade de o agente, segundo as suas capacidades individuais e as circunstâncias concretas em que acção é praticada, ter previsto os perigos ou os riscos da sua acção.

3.1.1. Possibilidade de o agente ter cumprido o dever objectivo de cuidado

Depois de abordarmos este primeiro pressuposto, passamos à análise do segundo, consiste na possibilidade de o agente ter cumprido o dever objectivo de cuidado[184].

Neste, antes de mais, importa atender que, caso o agente não se encontre em condições de realizar os cuidados impostos, devido, p. ex., ao facto de não ter os conhecimentos, não dominar as técnicas, não ter a destreza, “necessários para evitar que os riscos da sua

[183] Américo Paita de Carvalho, Ob., Cit., p. 525.

[184] Américo Taipa de Carvalho, *ob. cit.*, p. 531 e 532

acção se concretizassem em resultados desvaliosos", este "não poderá, em princípio, ser considerado culpado.

Contudo, dissemos "em princípio", porque o agente pode ser declarado como culpado, relativamente àquelas circunstâncias, a título de negligência, embora se conclua que ele "não tinha capacidade ou possibilidade de ter posto em acção os cuidados necessários" para impedir os efeitos negativos da acção que efectivamente executou[185].

No fundo, a culpa negligente afirma-se sempre que o agente pratica uma acção relativamente à qual representa ou tem a possibilidade de representar os riscos que envolve, sabendo ou devendo saber que não se encontrava em condições de cumprir as exigências de cuidado impostas, devido às suas incapacidades: não ter os conhecimentos, não dominar as técnicas, não ter a destreza necessárias (culpa por assunção).

5. Os tipos justificadores

5.1. Os concretos tipos justificadores

Segundo o critério geral, também o facto de negligência pode encontrar-se coberto de legítima defesa e consentimento presumido (nomeadamente no campo da actividade médica).

6. Problema da negligência grosseira

Ora, a negligência grosseira situa-se, antes de mais, no plano do tipo de ilícito negligente, o que faz dela uma espécie qualificada do mesmo.

[185] Ibidem

O legislador regula a negligência grosseira como "uma espécie mais grave ou especialmente qualificada da culpa negligente. Nas palavras de F. DIAS, o legislador regula-a como a espécie mais severa[186].

Uma deliberação acerca da verificação ou não verificação desta espécie de negligência está sujeita ao contexto do caso real, ou seja, tem que atender ao agente e ao tipo de ilícito negligente cometido.

Além disto, o tribunal deve considerar, também, os seguintes elementos: "**a especial relevância do bem jurídico lesado ou posto em perigo pela acção descuidada; a intensidade acrescida do perigo, ou seja, o forte risco de produção do resultado; o especial dever de cuidado", tendo em conta "o estatuto, a profissão ou as funções do agente"[187]**.

Contudo, esta terá que se situar, também, no plano da culpa de forma a evidenciar-se na "agravação modificativa da pena ou da "agravação" dentro do limite máximo da pena legal do crime negligente, uma vez que o "carácter qualificado ou grosseiro da negligência" tem igualmente que demonstrar uma "acrescida atitude ético-pessoal de leviandade do agente", "uma potenciada culpa negligente.

Para terminar, convém notar que a negligência, na sua vertente grosseira, deve ter influência para efeitos de determinação da medida da pena e o art. 71.º n.º 2, al[s]. a) e b) do CP, demonstra-o ao regulamentar que o tribunal tem que tomar em atenção o "grau de ilicitude do facto", o "grau de violação dos deveres impostos ao agente" e a "intensidade da negligência.

CATÍTULO IV
CRIMES DOLOSOS DE OMISSÃO

I. Algumas reflexões introdutórias

Quanto tratamos as formas básicas de realização típica refere-se que, o tipo tanto pode ser realizado através da prática de uma acção proibida, como através de omissão de um

[186] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit., p. 902 .

[187] 59Américo Taipa de Carvalho, *ob. cit.*, p. 536

comportamento juridicamente exigido. No mesmo sentido o Prof. F. DIAS diz que, a omissão é pois, ao lado da acção, uma das formas de realização típica[188] (art. 8.º do CP).

1. Noção

A omissão será uma abstenção da actividade que o agente poderia e deveria ter levado a cabo, por forma a evitar a ofensa do bem jurídico tutelado, é um *non facere* penalmente relevante. **O essencial para haver omissão - será *o não* ter agido da forma imposta pela lei e por essa falta de acção, ofender ou colocar em perigo de lesão o bem jurídico.**

Por outras palavras, omissão é o comportamento voluntário negativo e, digo mais, é a falta de acção no comportamento[189] do dever. Ou ainda, é abstenção da actividade que o agente deveria e poderia realizar.

É assim, que nos termos do art. 208.º do Código Penal, se prevê o crime de omissão de auxílio. Comete este crime quem, por si ou por interposta pessoa, não preste - apesar de o poder fazer – auxílio ou ajuda, tendente a remover a situação de perigo para **a vida, a integridade física ou a liberdade,** em que outra pessoa se encontre. Será o caso de alguém que se depare com um acidente de estrada de que tenham resultado feridos e que não diligencie pelo socorro dos mesmos, podendo fazê-lo, ainda que por meio de um simples telefonema.

Neste crime, a lei não alarga a previsão a outros bens jurídicos, nomeadamente de natureza patrimonial, por outro lado, não exige a verificação de qualquer resultado derivado da conduta omissiva do agente, ou seja, o crime consuma-se independentemente de vir, ou não, a verificar-se dano, para algum daqueles bens jurídicos - a morte, a ofensa à integridade física ou a privação da liberdade – bastando-se com a situação de grave perigo de lesão desses bens; trata-se, pois, de um crime de mera actividade.

[188] Jorge de Figueiredo Dias, Ob., Cit., p. 905

[189] Esta conduta humana, conduta negativa, surge porque o agente não realizou uma determinada acção que lhe era imposta e com tal abstenção coloca um bem jurídico tutelado em perigo, ou chega efectivamente a lesá-lo. A omissão refere-se sempre a um dever jurídico de agir. Através da acção faz-se o que a lei proíbe (viola-se uma proibição), através da omissão, não se faz o que a lei impõe que seja feito (viola-se uma norma perceptiva, que impõe um comportamento activo).

2. Diferença entre crimes comissivos e crimes omissivos

O crime é sempre uma acção humana, um facto voluntário, dominado e dominável pela vontade, tal acção ou facto voluntário, pode consistir tanto num comportamento positivo - uma acção, como num comportamento negativo - uma omissão, ou seja, quando o agente não leva a cabo a acção esperada[190].

Assim, a omissão que naturalisticamente é um nada, um *non faccere*, um não agir e no sentido comum o contrário de acção, a verdade é que não deixa de constituir uma realidade que supõe uma valoração e que constitui uma conduta do agente, dependente da vontade deste, que pode ter relevância penal.

A Lei penal, porém, prevê a propósito dos crimes de resultado, os chamados crimes de omissão impura ou imprópria, em que se tratará de comissão por omissão, estabelecendo no art. 8.º n.º 2, que, porém, a verificação de um resultado por omissão só é punível quando, segundo o sentido do texto da Lei, a produção por omissão equivaler à produção por acção e sobre o omitente recair um dever jurídico que pessoalmente o obrigue a evitar esse resultado.

3. Pressupostos

Os pressupostos da omissão vêm previstos nos termos do art. 8.º do CP:

No n.º 1, contém em si a primeira limitação, ou seja, que se trate de um crime de resultado, como referido.

A segunda restrição à formulação ampla do n.º 1, contém-se no n.º 2, do art. 8.º, o qual limita a comissão de um resultado por omissão, aos casos em que "sobre o omitente **recair um dever jurídico** que pessoalmente o obrigue a evitar esse resultado".

Isto é, se um pai deixar afogar um filho, apesar de saber nadar e não poder salvá-lo, o mesmo poderá ser condenado pela prática, por omissão, do crime de homicídio, uma vez que este é um crime de resultado e os pais têm o dever imposto pelo direito civil de zelar pelos filhos.

4. Objecto dos crimes dolosos de omissão

[190] Marisa Sofia Marra Todo Bom, *Crimes De Omissão: A Sua Admissibilidade Na Instigação*, Coimbra, 2015, 6.

Juridicamente, o dever é a uma situação passiva que determina para uma pessoa a necessidade de ter determinado comportamento, significa que o **dever de agir** consiste numa exigência imposta por lei para evitar o resultado típico. Enquanto, que os crimes negligentes têm como objecto o dever de cuidado.

5. Fontes do dever de agir

As fontes do dever de agir são: a lei, o contrato e a situação de ingerência.

a) A lei

Dá-se nos casos em que o dever de agir se funda na Lei. A lei aqui referida não é simplesmente a lei jurídico-penal, bem como os regulamentos, decretos e os decretos-lei.

Dito por outras palavras, o dever legal: entende-se como sendo aquele que, alguém tenha por lei obrigação de cuidado, protecção ou vigilância. É o caso dos pais em relação aos filhos menores. Se deixarem de alimentá-los, podem responder pelo homicídio, no caso, omissivo impróprio, art. 247.º, do CP.

b) Contrato

O contrato aplica-se aquelas pessoas encarregadas de vigiar idosos ou crianças.

Uma parte da doutrina preferi o designativo**, dever de garante ou contratual:** é o sujeito que, de alguma forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. É o exemplo do salva-vidas de um clube, que, por vínculo de trabalho, se obriga a salvar uma criança que se afoga e pode responder pelo resultado morte, caso se abstenha de agir, 209.º, do CP.

c) Situação de ingerência

É o caso de alguém criar o perigo e se verificar o resultado por omissão, não remover.

Veja-se o exemplo de alguém, dolo de ofensas corporais atinge, outro com um soco e este bate com a cabeça e começa a sangrar. Em vez de o levar ao hospital ou de chamar a ambulância o agente nada faz e a vítima acaba por falecer.

Ainda que o soco não seja causa adequada da morte – pelo que não seria homicídio por acção – foi o agente quem criou o perigo, pelo que estava obrigado a removê-lo; situação de ingerência.

6. Tipos incriminadores de crime de omissão por comissão

6.1. Noção

Crime omissivo conforme já fizemos referência é aquele que é praticado por meio de um comportamento negativo, uma abstenção, um não fazer.

6.2. Classificação dos crimes Comissivos

Os crimes omissivos por comissão classificam em:

a) Crimes omissivos próprios ou puros

Crimes omissivos próprios - são aqueles previstos no tipo incriminador. Ou seja, o comportamento negativo está descrito no núcleo do tipo incriminador. Por outras palavras, o dever jurídico de agir, naquela situação, decorre do próprio tipo penal. Exemplo: é o crime de omissão de socorro, previsto no art. 208.º do CP.

b) Crimes omissivos impróprios ou impuros

Crimes omissivos impróprios, também chamados de comissivo por omissão – são aqueles cujo dever jurídico de agir decorre de uma cláusula geral, que, no código penal angolano, está previsto no art. 8.º, n.º 3 e em inúmeros crimes previstos na parte especial do CP. Clarificando o dever jurídico abrange determinadas situações jurídicas e se refere a qualquer crime comissivo. O sujeito tem o dever de evitar o resultado naturalístico. Por isso, tais delitos são chamados comissivos por omissão.

São crimes naturalmente comissivos (praticados por um comportamento positivo, uma acção), como é o caso do homicídio, mas que podem ser praticados por uma conduta omissiva, no caso de o sujeito ter o dever jurídico de agir previsto na cláusula geral.

CATÍTULO V

CRIMES AGRAVADOS PELO RESULTADO

1. Noção

Os crimes agravados pelo resultado podem ser definidos como aqueles tipos legais de crime, cuja pena aplicável é agravada por causa da ocorrência de um determinado resultado, podendo este ser típico ou atípico[191].

2. Características

A característica fundamental dos crimes agravados pelo resultado é a existência de um resultado, resultado esse que agrava a pena[192].

Ora, este resultado agravante pode ser, como já referimos, típico ou atípico, regulado num outro tipo legal, como p. ex., a morte ou a ofensa grave da integridade física, ou então pode acontecer que não se encontre presente em nenhum tipo legal, como p. ex., a gravidez ou o suicídio[193].

3. Requisitos

Nas palavras do Prof. EDUARDO CORREIA, crimes agravados pelo resultado, podemos assinalar quarto requisitos a saber:

a) A presença de um crime fundamental;
b) A presença de um resultado agravante;
c) A presença de uma peculiar agravação da pena, que abranja o crime fundamental e o resultado agravante e que, pela lógica, deve ultrapassar o que teria lugar através do concurso de crimes;
d) Nexo de causalidade, ou seja, tem que existir um nexo que conecte a conduta ao resultado agravante.

Crimes agravados pelo resultado *vs.* Crimes preterintencionais

[191] Juliana Pereira Loureiro, Crimes Negligentes: *unidade versus pluralidade: o problema face aos crimes rodoviários, na medida respeitante à conjugação com o art. 291º do Código Penal, agravado pelo resultado,* Porto, 2014. P. 31

[192] Helena Moniz, *Agravação.* Citada por Juliana Pereira Loureiro, Ob., Cit., p. 31

[193] Ibidem

Como é sabido o crime preterintencional - Crime *preterdoloso* ou preterintencional é aquele em que a acção causa um resultado mais grave não pretendido pelo agente. O sujeito quer um *minus* e a sua conduta produz um *majus*. Dito por outra forma, é aquele em que resultado vai além da intenção do agente.

A figura dos crimes agravados pelo resultado é mais ampla do que a figura dos crimes preterintencionais, isto verifica-se pelo facto de estes serem uma das categorias daqueles, como já analisámos.

No entanto, a doutrina equiparava e parece, ainda hoje, equiparar estas duas figuras. Isto porque consideram que elas têm uma composição semelhante, a saber: "uma homogeneidade dos bens lesados; (…) e uma relação de causalidade entre aquela conduta dolosa e o resultado agravante[194].

Daqui, retiramos uma certa proximidade entre as ditas figuras, mas, obviamente que apresentam diferenças.

Os crimes preterintencionais têm, um elemento particular que consiste num perigo (normal) tipicamente inerente a uma conduta base.

Os crimes agravados pelo resultado são "mais do que uma figura una", são, acima de tudo, "uma figura complexa", na medida em que são compreendidos, nas palavras de HELENA MONIZ, como uma conjugação entre um crime fundamental e um resultado agravante.

Visto isto, é importante diferenciar as combinações dos crimes agravados pelo resultado daquelas combinações em que não há um crime base, a conduta fundamental não é jurídico-penalmente considerada como crime, embora o agente a tenha realizado dolosamente. No entanto, o que acontece é que se daí advier um resultado agravante, que será, assim, causado a título de negligência, a situação muda, passando a justificar-se a responsabilização para efeitos penais.

Isto mostra que, neste caso, o resultado agravante não é somente o causador da agravação como é, também, alicerce da punição. Diferentemente, nos crimes agravados pelo resultado, "a pena aplicada ao facto é que é agravada em função da produção do resultado".

[194] Juliana Pereira Loureiro, Ob., Cit., p. 32-33

CATÍTULO VI

CONCURSO DE CRIMES

Questões prévias

Esta matéria será melhor discutida a nível do 5.º ano na cadeira de direito penal II, por agora iremos apenas, introduzir algumas noções essenciais, com vista à situar o estudante sobre o concurso de crimes e as figuras afins.

1. Noção e o problema da unidade ou pluralidade jurídica

Quando **duas ou mais pessoas** praticam um crime surge o "concurso de agentes" é o que falamos aquando da discussão sobre a autoria. Quando **um sujeito**, mediante unidade ou pluralidade de acções ou de omissões, pratica dois ou mais delitos, surge o concurso de crimes ou de penas (*concursus delictorum*)[195].

O art. 28.º n.º 1, do CP consagra o seguinte: "O número de crimes determina-se pelo número de tipos de crime efectivamente preenchidos, ou pelo número de vezes que o mesmo tipo de crime for realizado pela conduta do agente".

Podemos afirmar que, esta disposição prevê um critério teleológico ou normativo que permite diferenciar entre a unidade e a pluralidade de infracções.

No entanto, o conteúdo deste artigo, levanta muita controvérsia na doutrina portuguesa, ou seja, o conteúdo previsto no art. 28.º, do nosso código penal, é o mesmo que vem previsto no art. 30.º do código penal português. Os doutrinadores portugueses, como é o caso de Faria Costa, Gomes da Silva, Beleza dos Santos, Maia Gonçalves, Cavaleiro de Ferreira, Figueiredo Dias e entre outros. Dentre eles alguns não concordam com este critério nem com a equiparação do concurso ideal ao concurso real, sustentando que o mesmo artigo deveria ser mais claro e explicitando as regras da consumação e da especialidade.

Já Cavaleiro de Ferreira considera que o n.º 1 do art. 30.º do CP português, não pondera a unidade ou a pluralidade de condutas para explicar o concurso de crimes, ou seja, para este autor, o que aquela disposição defende é que um concurso de crimes ocorre quando

[195] Damásio de Jesus, Direito penal, volume 1: parte geral / Damásio de 32. Ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 641.

o **agente executa mais do que um crime**, **quer haja uma só conduta, quer haja várias**[196]**.**

Por sua vez, F. DIAS parece mais convincente ao dizer que, a questão da unidade ou pluralidade de crimes, determinantes são os tipos de crime infringidos pela conduta do agente e não as acções propriamente ditas, ou seja, o critério adoptado por este autor é o da "unidade ou pluralidade de sentidos sociais de ilicitude do comportamento global".

Isto porque, para este autor, "o que se tem de contar são sentidos da vida jurídico-penalmente relevantes que vivem no comportamento global" e, portanto, "é a unidade ou pluralidade de sentidos de ilicitude típica, existente no comportamento global do agente (…), que decide em definitivo da unidade ou pluralidade de factos puníveis e, nesta acepção, de crimes[197].

Quanto o nosso entendimento vai no mesmo sentido com o do Prof. F. DIAS, em causa não está as acções do agente se foi uma ou várias, mais sim, os tipos de crime infringidos pela conduta ou o número de vezes que o mesmo tipo de crime for realizado pela agente.

2. Modalidades do curso de crimes

2.1. O concurso de crimes efectivo, real ou ideal

Concurso efectivo consiste na violação de varias normas jurídico-penais, devido a prática pelo agente de diferentes crimes. O concurso efectivo pode ser real (puro ou próprio) ou ideal – é real se forem praticados os diferentes factos.

Isto verifica-se exemplificativamente:

Se o agente faz mais de um disparo e com eles ofende mais de uma pessoa.

Outro exemplo: há concurso efectivo entre os crimes de coacção sexual e violação sexual, uma situação em que tendo em conta a diversidade de resoluções criminosas e a coacção sexual.

[196] José de Faria Costa, *ob. cit.*, p. 32.
[197] 106Figueiredo Dias, *Direito Penal…*, *Tomo I*, *cit.*, p. 988-989.

É ideal – se for praticado um só acto que viole mais de uma norma. Ex.: se o agente faz deflagrar um engenho explosivo, ferindo mais de uma pessoa atingidas, um facto naturalístico corresponde mais de uma acção.

É frequente na doutrina a divisão de concurso real em concurso homogéneos e heterogéneos.

Concurso homogéneos – consiste na prática pelo agente de dois ou mais crimes da mesma espécie.

Concurso heterogéneos – consiste na pratica pelo agente de dois ou mais crimes de espécies diferentes.

2.2. O concurso de crimes aparente ou ideal impuro ou impróprio

Diz-se concurso aparente se as normas violadas só na aparência não aplicáveis cumulativamente, mais na verdade ou se aplica uma ou outra, ou seja, havendo entre as normas incriminadoras uma relação de especialidade, aplica-se a norma incriminadora especial. Nos restantes casos, aplica-se a norma incriminadora que estabelecer pena mais grave (art. 28.º n.º 3 al. a) e b)).

3. Concurso de crimes e o crime continuado

Nos termos do n.º 1, do art. 29.º, diz que "Constitui um só crime continuado a realização plúrima do mesmo tipo de crime ou de vários tipos de crime que fundamentalmente ofendam o mesmo bem jurídico, executada por forma essencialmente homogénea e no quadro da solicitação de uma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do agente".

3.1. Elementos do crime continuado

A respeito dos elementos da continuação criminosa, existem três concepções fundamentais e são elas (1) **a concepção objectivista**, (2) **a concepção subjectivista e a** (3) **concepção objectivo-subjectiva ou mista**, tendo em conta a delimitação do nosso estudo, não iremos discutir aqui sobre esta temática. *Vide*. MARIANA MATEUS

FIDALGO SIMÕES - O CRIME CONTINUADO" - *A problemática da sua (in) aplicabilidade aos bens pessoalíssimos-p, 51.*

De entre os elementos de natureza objectiva, incluímos os elementos da realização plúrima do mesmo tipo ou de vários tipos legais de crime; **a identidade do bem jurídico protegido; a homogeneidade de execução**, **a existência de uma circunstância externa.** No âmbito dos elementos de natureza subjectiva, **abarcamos a existência de culpa diminuta**[198].

Vejamos, então, pormenorizadamente, cada um destes elementos com o intuito de obstar a uma aplicação da figura da continuação criminosa quer demasiado ampla, quer demasiado estrita.

1. **Realização plúrima do mesmo tipo de crime ou de vários tipos de crime**

Todavia, como resulta expressamente do teor literal daquele preceito legal, não é exigível que o agente cometa, por diversas vezes, o mesmo tipo legal de crime, podendo, pois, preencher diferentes tipos legais de crime com a sua conduta. Como se mostra legalmente evidente, como sustentáculo do crime continuado, poderá estar quer uma situação de concurso homogéneo, quer uma situação de concurso heterogéneo: se o agente preenche diversas vezes o mesmo tipo legal de crime e se verificam os demais pressupostos do crime continuado, este designa-se por crime continuado homogéneo; se o agente preenche com a sua conduta diversos tipos legais de crimes, o crime continuado diz-se heterogéneo[199].

O mencionado preenchimento de vários tipos de crime pode verificar-se quer por acção, quer por omissão, quer o agente actue com dolo ou negligência, sendo que a nossa posição quanto a esta última referência será melhor compreendida.

2. **Identidade do bem jurídico protegido**

Para que se possa concluir pela existência de uma continuação criminosa não basta que se verifique uma situação de concurso de crimes. Assim, para além da diversidade de crimes cometidos pelo agente, é necessário que os tipos legais de crime violados tenham em vista a protecção de um bem jurídico que é, no seu âmago, o mesmo.

[198] Mariana Mateus Fidalgo Simões , *O CRIME CONTINUADO" - A problemática da sua (in) aplicabilidade aos bens pessoalíssimos*, Coimbra, 2014, p, 53.
[199] Ibidem

Por conseguinte, consideramos sustentável a possibilidade de se verificar uma continuação criminosa entre os crimes de furto e dano, previstos e punidos pelos artigos 392.º e 410.º do CP, respectivamente, atenta a identidade do bem jurídico violado:

3. Homogeneidade de execução

Homogeneidade de execução, dá-se quando a conduta do agente for levada a cabo com emprego dos mesmos meios ou, por outras palavras, se o agente actuar do mesmo modo.

Todavia, se conduta do agente for levada a cabo com emprego dos mesmos meios ou, se o agente actuar do mesmo modo, tal indiciará uma menor culpa do agente, embora, *a contrário*, a sua ausência não possa ditar, desde logo, a exclusão da figura do crime continuado.

HENRIQUES EIRAS E GUILHERMINA FORTES são de opinião que a execução dos crimes por forma homogénea não se verificará em caso de comissão por acção e omissão, bem como entre crimes dolosos e negligentes[200].

4. A existência de uma circunstância externa capaz de diminuir sensivelmente a culpa do agente

Circunstância externa será uma causa exterior ao agente e não endógena, por ele concebida ou devida à sua personalidade, reveladora de especial propensão para a prática de crimes. Seria os casos das drogas.

A circunstância externa geradora de uma culpa diminuída deve ser invulgar, pois se se apresentar como comum ou corriqueira, o agente não seria por ela surpreendido, devendo providenciar no sentido de adequar a sua conduta de acordo com o Direito.

Basicamente, saber se uma circunstância externa poderá fundar um juízo de censurabilidade diminuta da conduta implica indagar se o Homem médio, colocado na posição do real e concreto agente, se deixaria influenciar por ela ou se, pelo contrário, seria expectável o oferecimento de resistência à tentação de delinquir[201].

---

[200] Henriques Eiras; Guilhermina Fortes, *Dicionário de Direito Penal e Processo Penal*, 3ª Ed., Lisboa, 2010, p.179;

[201] Mariana Mateus Fidalgo Simões, Ob., Cit., citando *in* CORREIA, Eduardo, *A Teoria do Concurso…*, *cit.*, p. 216-217.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, Aiken Renkel - Resumo de Direito, 2.º Ed., Lubango, 2020-2021.

ARAÚJO, Raul Carlos Vasques -introdução ao direito constitucional angolano, 2.º ed.,- editora Luanda, 2018.

ASCENSÃO, José de Oliveira - O Direito - Introdução e Teoria Geral, 10.º ed., Coimbra, 1997.

AMARAL, Diogo Freitas do - Curso de Direito Administrativo, Vol. I, Coimbra, 1989

BECCARIA, Cesare - dos delitos e das penas. 3ª ed. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006

BITENCOURT, Cezar Roberto - Falência da pena de prisão, Causas e alternativas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

BRITO, Ana Bárbara Sousa., Teoria do Crime, 2018-2019.

BRANDÃO, Nuno Fernando da Rocha Almeida - Crimes E Contra-Ordenações: Da Cisão À Convergência Material, Coimbra, 2013.

BOM, Marisa Sofia Marra Todo - Crimes De Omissão: A Sua Admissibilidade Na Instigação, Coimbra, 2015.

CORREIA, Eduardo - *Direito Criminal*, 2 vols., Coimbra, 1971;

CARVALHO, Américo Paita de, direito penal parte geral, 2.º ed., Coimbra, 2011

COSTA, José de Faria - Noções Fundamentais de Direito Penal, 3.º Ed., Coimbra, 2011.

CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. I, 3.ª edição revista, Coimbra:, 2007.

DIAS, Jorge de Figueiredo - O movimento da descriminalização e o ilícito de mera ordenação social, Jornadas de Direito Criminal.

DIAS, Jorge de Figueiredo - Direito Penal II, As Consequências Jurídicas do Crime, Coimbra: 1993.

DIAS, Jorge de Figueiredo - Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Coimbra, 2007

EIRAS, Henriques e FORTES, Guilherme - Dicionário de Direito Penal e Processo Penal, 3.º Ed., Lisboa, 2010.

ESTEFAM, André - parte geral do direito penal, vol 7, São Paulo, 2018.

ESTEFAM, André; Gonçalves, Victor Eduardo Rios - Direito penal esquematizado*:* parte geral, 5. ed. – São Paulo, Saraiva, 2016.

FERREIRA, Manuel Cavaleiro de - Lições de Direito Penal, vol. I Lisboa, 1992.

FILHO, Marco Aurélio Florêncio - A Culpabilidade No Direito Penal: Estruturação Dogmática Das Teorias Da Culpabilidade E Os Limites Ao Poder De Punir Do Estado, Revista Académica, Vol. 86, Nº1, 2014.

JÓNATAS E. M; Machado; PAULO N. Costa E ESTEVES. C. Hilario – direito constitucional angolano – 2º ed., 2013.

Jesus, Damásio de - Direito penal, volume 1 : parte geral , 32. ed., São Paulo, 2011.

LATAS, António João; DUARTE, Jorge Dias; PATTO, Pedro Vaz - direito penal e processual penal, Tomo I, Ed. 2007.

LOUREIRO, Juliana Pereira Crimes Negligentes - unidade versus pluralidade: o problema face aos crimes rodoviários, na medida respeitante à conjugação com o art. 291º do Código Penal, agravado pelo resultado, Porto, 2014.

MENDES, João de Castro - Introdução ao Estudo do Direito, Lisboa 1984.

VENOSA, Silvio de Salvo - Introdução Ao Estudo do Direito, 2.º Ed., São Paulo, 2009.

NUCCI, Guilherme de Souza - Manual de Direito Penal, Parte geral e parte especial, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

QUEMBA, Celestino Bangula - Contraordenações, Contravenções e Transgressões Administrativas: Um Olhar Ao Ordenamento Jurídico Angolano.

RAMOS, Vasco Grandão - Direito Penal, Apontamentos, Luanda 2002.

Relatório de fundamentação do código penal, 2018.

RAMOS, Vasco Grandão; *Estudo das Penas*, Luanda: 2001.

SÁ, Pereira Victor De; LAFAYETTE, Alexandre - Código Penal Português- Anotado e Comentado-Legislação Conexa e Complementar, 2.º Ed., Lisboa, 2014.

VARELA, Inês De Ornelas Fouto - A Imputação Objetiva Em Direito Penal.

SILVA, Carlota Vilaça Bastos - O Consentimento Do Ofendido Na Dogmática Jurídico-Penal, Porto, 2014.

STARLING, Sheyla Cristina da Silva - O Consentimento Do Ofendido Na Teoria Do Delito, Belo Horizonte, 2014.

SILVA, Germano Marques da - Direito Penal Português-Introdução a Teoria da Lei Penal, Ed. 3.º., Loures: 2010.

SIMÕES, Mariana Mateus Fidalgo - O CRIME CONTINUADO" - A problemática da sua (in) aplicabilidade aos bens pessoalíssimos, Coimbra, 2014.

TELES, Ney Moura - Direito Penal, Parte geral. v. 1, 2ª ed. São Paulo, 2006.

VARELA, Bartolomeu Lino - Manual de Introdução ao Direito, 2ª ed., Praia, 2008.